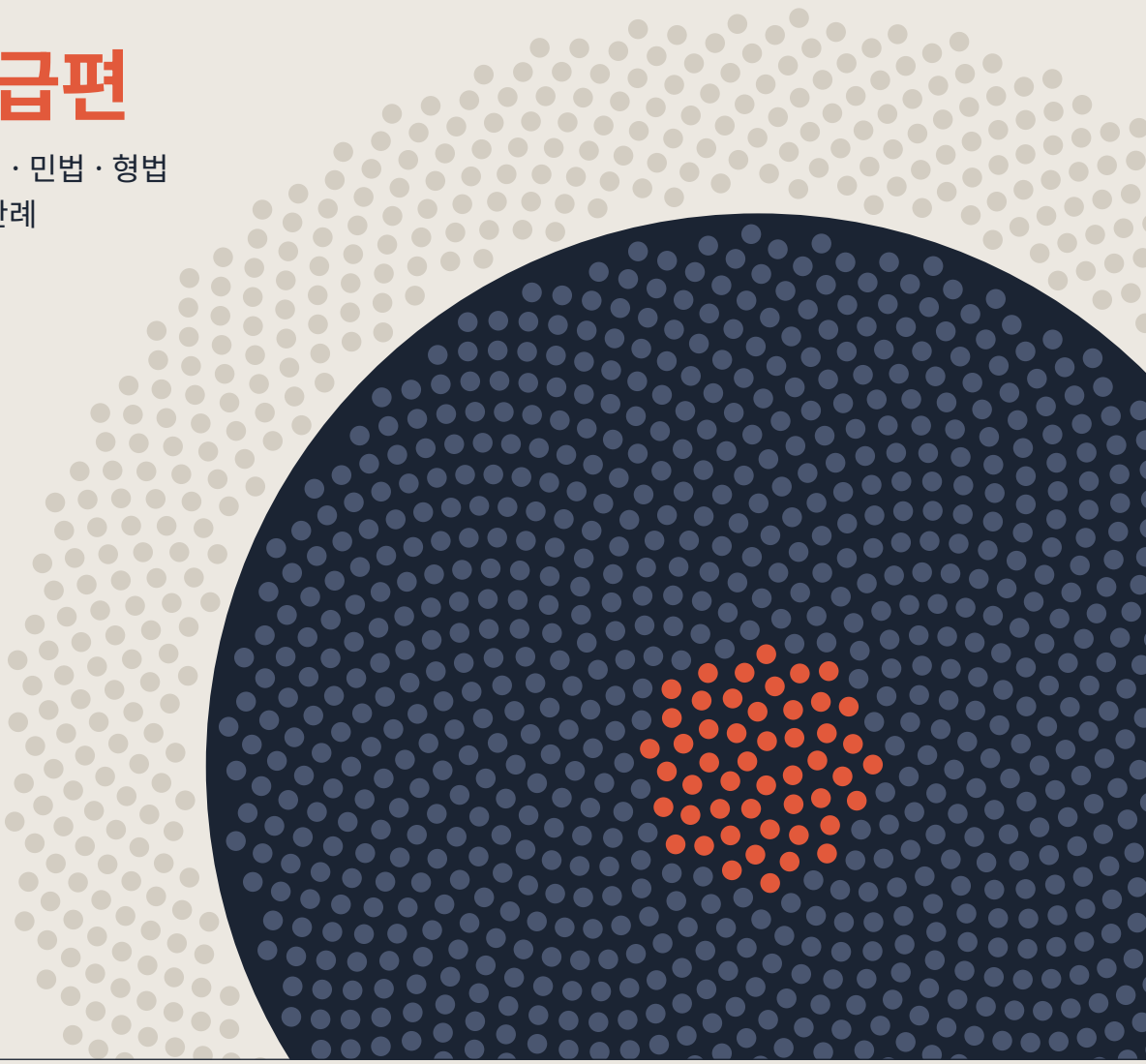
2026

대한민국

표준판례

5급편

헌법 · 민법 · 형법
50판례



저자 김민규
감수 김미현, 신현하, 박상영, 한정현, 이규한, 박준한, 정헌욱, 김영진, 박병재, 박서경, 최성완

저자

김민규

KAIST 문술미래전략대학원 겸직교수

전 서울고등법원 국선전담변호사 선발 면접위원

전 법무부 법조인 선발·양성 TF 위원

전 대한변호사협회 법학경시대회 TF 위원장

감수

김미현

서울대학교 법학과 수석 졸업

제50회 사법시험 합격

제52회 행정고등고시 합격

신현하

고려대학교 미래교육원 강사

박상영

서울대학교 일반대학원 법학과 재학

고려대학교 도산법연구센터 연구원

KCI 등재 학술지에 논문 11편 게재

제4회 법학경시대회 대상

한정현

KAIST 화학과 졸업

제1회 법학경시대회 대상

이규한

안산단원경찰서 경제범죄수사팀

제3회 법학경시대회 대상

박준한

제6회 법학경시대회 대상

정헌욱

연세대학교 정치외교학과 졸업

인하대학교 법학전문대학원 재학

제8회 법학경시대회 대상(변호사공제재단 이사장상)

김영진

KAIST 산업및시스템공학과 재학

제8회 법학경시대회 대상(대한변협법률구조재단 이사장상)

박병재

서울대학교 경영학과 차석 졸업

제7회 법학경시대회 최우수상

박서경

KAIST 전기및전자공학부 졸업

제8회 법학경시대회 최우수상·판례왕

최성완

KAIST 산업및시스템공학과 재학

머리말

AI 시대, 효율적이고 과학적인 법학 교육

법학은 왜 이렇게 어려울까. KAIST에서 제자들을 가르치며 이 질문과 자주 마주했다. 뛰어난 지적 능력을 갖추고 누구보다 성실한 학생들도 법학 앞에서는 길을 잃곤 했다. 노력이 모자라서가 아니었다. 낯선 개념과 방대한 분량 앞에서 무엇을 먼저 배우고 어떻게 연결해야 하는지 알려 주지 않는 공부 방식에 원인이 있었다. 학생에게 더 열심히 하라고 말하기 전에, 가르치는 사람이 더 나은 길을 내야 한다고 생각했다.

법학을 시작하면 흔히 이런 조언을 듣는다. 이해가 안 되어도 꾹 참고 한 바퀴, 두 바퀴 돌리다 보면 보인다는 것이다. 근거가 없는 말은 아니다. 민법은 제1조의 관습법에서 시작하지만, 관습법에 관한 판례를 제대로 읽으려면 물권편의 지상권과 취득시효, 상속편의 제사용 재산까지 알아야 한다. 앞을 이해하려면 뒤를 알아야 하니, 처음부터 끝까지 한 번 읽어서는 보이지 않는다.

그래서 2,000쪽에 이르는 교과서를 몇 번이고 돌린다. 그러나 첫 바퀴는 상당 부분을 이해하지 못한 채 지나가기 쉽고, 몇 달씩 걸리는 바퀴를 거듭해도 도는 길은 같은 높이의 같은 원이다. 무엇이 기초이고 무엇이 중요한지도 학습자가 스스로 가려내야 한다. 그 짐을 혼자 지기 어려운 학생들은 핵심을 추려 주고 진도를 정해 주는 학원과 강의에 기댄다. 우리 법학 공부가 50년 전의 회독·암기 관행에서 크게 벗어나지 못한 사이, 시간과 비용은 늘고 스스로 공부하는 힘은 자라기 어려워졌다.

수학과 과학은 이 문제를 다르게 푼다. 초등학생에게 수학 전체를 담은 두꺼운 책을 주고 여러 번 읽으라고 하지 않는다. 학년마다 그 나이에 맞는 깊이로 여러 영역을 두루 배우고, 학년이 오르면 같은 주제로 돌아와 한 걸음 더 들어간다. 함수는 초등학교의 규칙 찾기에서 시작해 중학교의 일차함수와 이차함수를 거쳐 고등학교의 미분과 적분으로 이어진다. 힘과 운동도 관찰에서 개념으로, 다시 법칙과 식으로 올라간다. 교육심리학자 제롬 브루너가 제안한 나선형 교육과정이다.

회독이 같은 운동장을 여러 바퀴 도는 일이라면, 나선형 학습은 산을 돌아 오르는 길이다. 같은 풍경을 거듭 만나지만, 돌 때마다 더 높은 곳에서 내려다본다. 법학도 그렇게 배워야 한다. 처음에는 법 전체를 작은 지도로 보고, 단계가 오를 때마다 같은 지도를 더 촘촘하게 다시 그리는 것이다.

작은 지도에는 자주 다니는 길부터 그린다. 『VOCA 22000』 같은 두꺼운 단어장을 처음부터 거듭 읽기보다 『우선순위 영단어』처럼 자주 쓰이는 단어부터 익히는 편이 빠르다. 『강희자전』에는 47,035자가 실려 있지만, 중국 교육부의 2007년 조사에서는 매체에 쓰인 한자 가운데 빈도가 높은 964자가 전체 한자 출현의 90%를 차지했다. 그래서 한자는 '불 화(火)', '물 수(水)'부터 배운다. 소수의 핵심이 결과의 큰 몫을 차지한다는 파레토 법칙처럼, 법학도 여러 문제에 되풀이하여 쓰이는 기본 법리부터 익혀야 한다.

『대한민국 표준판례』는 이 두 원칙, 곧 나선형과 우선순위를 책으로 옮긴 것이다. 한자 급수 시험처럼 5급의 50판례에서 시작하여 4급까지 150판례, 3급까지 300판례, 2급까지 500판례, 1급까지 1,000판례, 특급까지 1,800판례로 학습 범위를 넓힌다. 다만 중요한 순서로만 자르면 지도의 한쪽만 그려진다. 민법만 해도 중요도 순으로 25건을 자르면 총칙이 절반을 넘고 법정채권은 한 건도 들지 않는다. 그래서 급수마다 영역의 크기에 비례하여 판례를 골랐다. 5급의 50판례만으로도 헌법의 총강에서 헌법재판까지, 민법의 총칙에서 가족법까지, 형법의 총론과 각론을 한 바퀴 돌고, 급수가 오를 때마다 어느 영역도 뒤처지지 않고 지도 전체가 고르게 촘촘해진다.

같은 조문으로도 거듭 돌아온다. 5급의 50판례가 다룬 50개 조문 가운데 46개 조문은 4급에서 1급 사이에 새 판례로 다시 나온다. 한 조문 안에서도 기초가 되는 판례를 먼저, 예외와 적용을 다룬 판례를 나중에 만나도록 순서를 정했다. 민법 제1조라면 5급에서는 종중 구성원의 자격을 다룬 판결로 관습법이 무엇이고 언제 효력을 잃는지를 익히고, 분묘기지권의 지료와 제사주재자에 관한 판례는 물권과 상속을 세 바퀴 돈 뒤인 2급에서 만난다.

워크북은 앞 급수에서 배운 판례까지 함께 묻는다. 급수가 오를수록 찾는 단서를 줄여, 처음에는 조문을, 다음에는 법과 장만 알려 주고, 마지막에는 단서 없이 스스로 떠올리게 한다. 학습 연구에서도 같은 글을 거듭 읽는 것은 효과가 낮은 공부법으로, 책을 덮고 떠올리는 인출 연습과 간격을 둔 복습은 효과가 높은 공부법으로 꼽힌다. 몇 번 읽었는지보다 무엇을 스스로 설명하고 적용할 수 있는지가 실력이다.

이 공부법은 AI 시대에 더 중요해진다. AI가 자료를 찾고 설명을 대신해 주어도, 무엇을 물을지 정하고 답의 근거와 적용 범위를 판단하는 일은 사람의 몫이다. 탄탄한 기초가 있어야 AI의 답을 검증할 수 있다.

판례의 선정과 배치에도 같은 원칙을 적용했다. 기출의 빈도와 최근성, 여러 시험에 두루 나오는 정도를 정량적으로 분석하고, 법리의 중요성과 기초성, 개념 사이의 연결과 학습 난도를 함께 따졌다. 각 권의 판례는 조문 순서로 배열하여 법률의 문언과 구체적인 사건의 판단을 함께 읽도록 했다. 5급편부터 1급편까지는 그 급수에서 새로 익힐 판례를 담고, 과목판은 같은 1,000판례를 헌법·민법·형법의 흐름 속에서 다시 읽게 한다. 특급편은 여기에 800판례를 더하여 누적 1,800판례로 탐구를 넓힌다.

분석의 바탕은 2000년부터 2026년까지 치러진 법학 관련 시험의 기출 전 문항이다. 사법시험은 2000년 시험부터 분석했고, 변호사시험은 제1회부터 2026년에 시행된 제15회까지 전 회차를 분석했다. 분석한 시험은 사법시험, 변호사시험, 법원행정고등고시, 법무사시험, 변리사시험, 세무사시험, 감정평가사시험, 공인노무사시험, 가맹거래사시험, 행정사시험, 공인중개사시험, 주택관리사보시험, 일반경비지도사시험, 기계경비지도사시험, 법원공무원 9급 공개경쟁채용시험, 법원공무원 5급 승진시험, 국가공무원 5급 공개경쟁채용시험, 국가공무원 5급 승진시험, 외교관후보자 선발시험, 국가공무원 7급 공개경쟁채용시험, 지역인재 7급 수습직원 선발시험, 국가공무원 9급 공개경쟁채용시험, 입법고시, 국회 8급 공개경쟁채용시험, 국회 9급 공개경쟁채용시험, 지방공무원 7급 공개경쟁임용시험, 서울특별시 7급 공개경쟁임용시험, 선거관리위원회 7급 공개경쟁채용시험, 경찰공무원 공개경쟁채용시험, 경찰공무원 경력경쟁채용시험, 경찰간부후보생 선발시험, 경찰공무원 승진시험, 경찰대학 편입학시험, 해양경찰공무원 공개경쟁채용시험, 해양경찰공무원 경력경쟁채용시험, 해양경찰간부후보생 선발시험, 해양경찰공무원 승진시험, 소방간부후보생 선발시험, 군무원 5급 채용시험, 군무원 7급 채용시험, 군무원 9급 채용시험, 비상대비업무담당자 선발시험, 전직시험이다.

본문에는 판례마다 최근 5년의 기출을 표시하여 지금의 출제 흐름을 바로 확인할 수 있게 했다. 표시가 없는 판례도 기본 법리를 이해하는 데 필요한 학습 범위다. 판례는 2026년 8월 31일을 기준으로 했다. 국가법령정보센터(law.go.kr)에 수록된 판례, 기출 해설과 교과서에 나오는 판례, 대법원 판례공보에 실린 판례를 모두 분석하여 선정에 반영했고, 기준일까지의 최신 판례도 담았다. 넓게 살핀 판례를 학습의 중요도와 순서에 따라 추려, 핵심에서 출발하여 단계적으로 넓혀 가도록 구성했다.

이 책의 바탕에는 법학경시대회와 전국 자기주도 학습법 공모전으로 맺어진 수상자 공동체가 있다. 대회에는 고등학생부터 직장인과 평생학습자까지 국내외 71개 학교의 학습자가 참가했다. 참가자들은 대회를 준비하며 조문과 판례를 찾아 읽고, 공모전에서 자신의 공부법을 나누었다. 그 만남은 『헌법은 우리 이야기다』, 『우리 손으로 쓴 변호사시험 기출해설집』, 『쉽게 풀어쓴 민법 조문』의 공동 집필과 KCI 등재 학술지 논문, 후배를 위한 멘토링, 야학 봉사와 자기소개서 무료 첨삭으로 이어졌다. 『헌법은 우리 이야기다』는 8개 대학의 여덟 명이 함께 썼는데, 그중 여섯 명이 법학 비전공자다.

수상자들이 만든 민법위키 '하랑재'(lawinus.org)는 조문·해설·판례를 연결하고, 기출 OX와 빈칸 문제, 자판 연습으로 스스로 공부하게 돕는다. 나아가 학습자의 응답에 따라 설명과 확인문제, 복습 계획을 연결하는 '개인 교과서'도 구현했다. 책에서 배운 법리를 원문과 대조하고, 자신의 말로 설명하며, 부족한 부분을 다시 익히는 도구다. 이 책과 민법위키는 배움의 경험을 다음 학습자와 나누는 공동체의 결실이다.

이러한 실천을 바탕으로 법학교육 기술에 관한 여섯 건의 특허를 출원했다. 학습평가의 오류 정정과 법리 변경 대응, 법학 콘텐츠의 생성과 검증, 맞춤형 복습과 학습량 조절, 판례집의 편성과 개정 반영, 판례별 기출 이력의 검증과 표시, 누적 급수에 따른 학습 범위 배정에 관한 기술이다. 원문의 조건과 예외를 지키고 잘못된 평가를 바로잡으며, 공통 학습 범위 안에서 개인의 배움을 돕도록 설계했다.

나는 이 학생들이 자랑스럽다. 낯선 분야에 도전해 자신의 성취를 이루고, 그 경험을 책과 연구와 학습 도구로 나누는 모습이 자랑스럽다. 누구나 자기 자리에서 법학을 시작하고 스스로 배우며 성장할 수 있는 길을 만드는 것은 나의 오랜 꿈이었다. '불 화, 물 수'에서 시작한 작은 배움이 깊은 이해와 창의적인 문제 해결로 이어지고, 마침내 다른 사람의 배움을 돕는 지식이 되기를 바란다. 그 길을 제자들과 함께 만들고 있다는 것이 내게는 무엇보다 큰 기쁨이다.

학습법을 다듬는 과정에서는 제50회 사법시험과 제52회 행정고등고시에 합격한 김미현 변호사에게 많은 도움을 받았다. 깊이 감사드린다. 함께 집필하고 감수하며 책을 다듬어 준 모든 분께도 고마운 마음을 전한다.

2026년 9월

저자·감수진을 대표하여 김민규

일러두기

급수 판례는 5급 50 ⊂ 4급 150 ⊂ 3급 300 ⊂ 2급 500 ⊂ 1급 1,000으로 쌓인다. 안쪽 급수의 판례는 바깥 급수에 그대로 들어간다. 급수편 다섯 권은 각 급수에서 새로 더해지는 판례(50·100·150·200·500면)를, 과목판 세 권은 1급까지의 1,000면을 과목별로, 특급편은 1,000면에 더하는 800면을 싣는다. 이 책은 5급의 50면을 헌법·민법·형법 차례로 싣는다. 면 번호는 5-001부터 붙는다.

조문과 판례 판례는 대표 조문을 기준으로 법전의 편·장·절·조 순서로 찾을 수 있다. 조문과 판례의 판단을 함께 읽으며 법률의 문언이 구체적인 사건에 어떻게 적용되는지 살핀다.

기출 2022~2026년 시행 시험에서 해당 판례의 판단을 물은 시험명과 연도를 판례 표시 아래에 적었다. 표시가 없는 판례도 학습범위에 포함된다.

판단 읽기 〔재판관 ○○○ 등 4인의 기각의견〕 과 같은 표시는 해당 재판관들의 의견을 뜻한다. '범위'는 법리를 일반화할 때의 주의점이며, '현행'은 선고 뒤 법령·판례의 변화를 설명한다.

함께 찾기 '함께 읽기'는 이 판례와 쟁점이 가까운 판례의 번호다. 판결이 서로 인용한 판례와 같은 조문의 판례를 가까운 것부터 적었다. 해설 속 사건번호 뒤의 (→ 번호)도 그 판례가 실린 면이다. 판례를 읽은 뒤 확인 문항을 풀고 하단의 답과 이유를 대조한다.

면 번호 3-057은 3급편 57면, 특-123은 특급편 123면, 헌 045·민 180·형 072는 과목판 헌법·민법·형법의 면이다. 함께 읽기와 찾아보기는 이 번호로 가리킨다.

법령 조문 상자의 문언은 2026. 9. 현재 시행 중인 법령이다. 판례가 적용한 옛 조문과 다를 수 있으므로 '현행' 표시를 함께 본다.

찾아보기 책 끝에 사건번호 찾아보기와 핵심어 찾아보기를 둔다. 5급의 면을 모았다. 사건번호를 알면 사건번호 찾아보기를, 쟁점만 알면 핵심어 찾아보기를 이용한다.

차례

헌법

대한민국헌법

제1장 총강

제8조
득표율 미달 정당의 등록취소 — 정당설립의 자유 침해 **5-001**

제2장 국민의 권리와 의무

제10조
착상 전 초기배아 — 기본권 주체성 부정 **5-002**

제11조
제대군인 가산점 — 평등권·공무담임권 침해 **5-003**

제17조
교원노조 가입현황 공개 — 개인정보자기결정권 침해 **5-004**

제19조
국가보안법상 불고지죄 — 양심의 자유 침해 아님 **5-005**

제21조
외교기관 인근 집회의 전면금지 — 집회의 자유 침해 **5-006**

제34조
최저생계비 고시 — 인간다운 생활을 할 권리 침해 아님 **5-007**

제3장 국회

제45조
국회의원 면책특권 — 보도자료 사전 배포도 직무부수행위 **5-008**

제10장 헌법개정

제130조
관습헌법인 수도 서울 — 법률로 이전하면 국민투표권 침해 **5-009**

헌법재판소법

제4장 특별심판절차

제5절 헌법소원심판

제68조 청구 사유
조약 체결행위 — 헌법소원의 대상인 공권력의 행사 **5-010**

민법

민법

제1편 총칙

제1장 통칙

제1조 법원
관습법의 효력 — 변화한 법질서에 맞지 않으면 부정된다 **5-011**

제3장 법인

제1절 총칙

제35조 법인의 불법행위능력
비법인사단의 불법행위책임 — 악의·중과실 피해자에게는 없다 **5-012**

제5장 법률행위

제2절 의사표시

제108조 통정한 허위의 의사표시
통정허위표시와 채권자취소권 — 취소 대상이 되어도 무효 **5-013**

제109조 착오로 인한 의사표시
착오와 하자담보책임 — 담보책임이 있어도 취소할 수 있다 **5-014**

제3절 대리

제126조 권한을 넘은 표현대리
표현대리와 과실상계 — 본인의 책임을 경감할 수 없다 **5-015**

제7장 소멸시효

제168조 소멸시효의 중단사유
대항요건 없는 채권양수인의 소 — 소멸시효가 중단된다 **5-016**

제2편 물권

제1장 총칙

제186조 부동산물권변동의 효력
공유지분의 포기 — 등기하여야 물권변동의 효력이 생긴다 **5-017**

제2장 점유권

제197조 점유의 태양
타인 토지를 산 매수인의 점유 — 자주점유 추정은 유지된다 **5-018**

제3장 소유권

제2절 소유권의 취득

제245조 점유로 인한 부동산소유권의 취득기간
2차 점유취득시효 — 도중에 바뀐 명의자에게도 주장 가능 **5-019**

제3절 공동소유

제275조 물건의 총유
교회 재산의 처분 — 규약이 없으면 교인총회의 결의로 **5-020**

제7장 유치권

제324조 유치권자의 선관의무
유치권자의 거주 — 보존에 필요한 사용이나 이득은 반환 **5-021**

제9장 저당권

제366조 법정지상권
공동저당과 재축 건물 — 법정지상권은 성립하지 않는다 **5-022**

제3편 채권

제1장 총칙

제2절 채권의 효력

제398조 배상액의 예정
손해배상액의 예정 — 귀책사유 없음을 증명하면 면책된다 **5-023**

제406조 채권자취소권
구체화 전 재산분할청구권의 포기 — 채권자취소 대상 아님 **5-024**

제3절 수인의 채권자 및 채무자

제428조 보증채무의 내용
주채무의 시효소멸과 보증인 — 보증채무도 소멸한다 **5-025**

제430조 목적, 형태상의 부종성
보증채권만의 양도 — 주채권과 분리하면 효력이 없다 **5-026**

제6절 채권의 소멸

제477조 법정변제충당
법정변제충당과 물상보증 — 변제이익에 차이가 없다 **5-027**

제2장 계약

제1절 총칙

제536조 동시이행의 항변권
중도금 지체 중 잔금기일 도래 — 등기의무와 동시이행 **5-028**

제539조 제삼자를 위한 계약
중첩적 채무인수 — 수익의 의사표시는 효력요건이 아니다 **5-029**

제548조 해제의 효과, 원상회복의무
해제에 따른 원상회복 — 과실상계로 줄일 수 없다 **5-030**

제3절 매매

제565조 해약금
해약금과 이행의 착수 — 대금 청구 소송은 착수가 아니다 **5-031**

제3장 사무관리

제734조 사무관리의 내용
사무관리의 성립 — 자기 이익이 섞여도 타인을 위한 의사 **5-032**

제4편 친족

제1장 총칙

제772조 양자와의 친계와 촌수
조부모의 손자녀 입양 — 복리에 맞으면 허가할 수 있다 **5-033**

제3장 혼인

제5절 이혼

제839조의2 재산분할청구권
채무초과 부부의 재산분할 — 채무 분담도 정할 수 있다 **5-034**

제5편 상속

제1장 상속

제4절 상속의 승인 및 포기

제1028조 한정승인의 효과
한정승인자의 저당권 설정 — 상속채권자가 우선하지 못한다 **5-035**

형법

형법

제1편 총칙

제1장 형법의 적용범위

제1조 범죄의 성립과 처벌
판례 변경과 처벌 — 형벌불소급의 원칙에 반하지 않는다 **5-036**

제2장 죄

제2절 미수범

제25조 미수범
준강도의 기수·미수 — 절도행위의 기수 여부로 가린다 **5-037**

제27조 불능범
준강간의 불능미수 — 대상의 착오라도 위험성 있으면 처벌 **5-038**

제3절 공범

제34조 간접정범, 특수한 교사, 방조에 대한 형의 가중
공문서위조의 간접정범 — 공무원이 속아 작성했다면 불성립 **5-039**

제3장 형

제2절 형의 양정

제52조 자수, 자복
자수의 시기 — 체포 전이면 지명수배 뒤에도 자수다 **5-040**

제2편 각칙

제10장 위증과 증거인멸의 죄

제152조 위증, 모해위증
증언거부권 불고지와 위증 — 사실상 장애 있으면 불성립 **5-041**

제11장 무고의 죄

제156조 무고
피무고자의 승낙 — 무고죄 성립에 영향 없다 **5-042**

제20장 문서에 관한 죄

제231조 사문서등의 위조·변조
허무인·사망자 명의의 문서 — 사문서위조죄 성립 **5-043**

제232조의2 사전자기록위작·변작
사전자기록 위작 — 권한을 남용한 허위 입력도 포함 **5-044**

제26장 과실치사상의 죄

제268조 업무상과실·중과실 치사상
업무상 과실 — 몰래 드나든 손님까지 통제할 의무는 없다 **5-045**

제30장 협박의 죄

제283조 협박, 존속협박
협박죄의 기수 — 상대방의 현실적 공포심은 필요 없다 **5-046**

제32장 강간과 추행의 죄

제298조 강제추행
강제추행의 간접정범 — 피해자를 도구로 삼아도 성립 **5-047**

제36장 주거침입의 죄

제319조 주거침입, 퇴거불응

공동거주자 승낙 출입 — 부재자 의사에 반해도 침입 아님 **5-048**

제38장 절도와 강도의 죄

제329조 절도

불법영득의사 — 소유자에게 이익이 되어도 부정되지 않는다 **5-049**

제40장 횡령과 배임의 죄

제355조 횡령, 배임

법인이 진 사무와 배임 — 대표기관이 배임죄의 주체 **5-050**

제8조
①정당의 설립은 자유이며, 복수정당제는 보장된다.

득표율 미달 정당의 등록취소 — 정당설립의 자유 침해

헌재 2014. 1. 28. 2012헌마431 정당법 제41조 제4항 위헌확인

최근 5년 기출 **2025** 국가직 5급 · 법원직 9급 · 법원행시 · 외교관후보자 선발시험 · 지역인재 7급 | **2024** 국회직 9급 | **2023** 경찰 | **2022** 경찰 · 국회직 9급

사실 청구인인 세 정당은 2012. 4. 11. 제19대 국회의원선거에 참여하였으나 의석을 얻지 못하고 유효투표총수의 100분의 2 이상도 득표하지 못하였다. 중앙선거관리위원회는 정당법 제44조 제1항 제3호에 따라 이들의 등록을 취소하였고, 이들은 정당법 제41조 제4항에 따라 종전 명칭도 일정 기간 쓸 수 없게 되었다. 청구인들은 명칭사용금지조항에 대하여 헌법소원심판을 청구하였고, 등록취소처분 취소소송을 맡은 법원은 등록취소조항에 대하여 위헌법률심판을 제청하였다.

쟁점 **국회의원선거에서 의석을 얻지 못하고 유효투표총수의 100분의 2 이상을 득표하지 못한 정당의 등록을 취소하면 정당설립의 자유를 침해할까?**

판단 헌법 제8조 제1항 전단은 단지 정당설립의 자유만을 명시적으로 규정하고 있지만, 정당의 설립만이 보장될 뿐 설립된 정당이 언제든지 해산될 수 있거나 정당의 활동이 임의로 제한될 수 있다면 정당설립의 자유는 사실상 아무런 의미가 없게 되므로, 정당설립의 자유는 당연히 정당존속의 자유와 정당활동의 자유를 포함하는 것이다. … 그러나 정당등록의 취소는 정당의 존속 자체를 박탈하여 모든 형태의 정당활동을 불가능하게 하므로, 그에 대한 입법은 필요최소한의 범위에서 엄격한 기준에 따라 이루어져야 한다. 그런데 일정기간 동안 공직선거에 참여할 기회를 수 회 부여하고 그 결과에 따라 등록취소 여부를 결정하는 등 덜 기본권 제한적인 방법을 상정할 수 있고, … 정당등록취소조항은 침해의 최소성 요건을 갖추지 못하였다. … 따라서 정당등록취소조항은 과잉금지원칙에 위반되어 청구인들의 정당설립의 자유를 침해한다. — 결정요지 1·3

해설 헌법 제8조 제1항은 국민 누구나 원칙적으로 국가의 간섭 없이 정당을 설립할 권리를 기본권으로 보장하고 복수정당제를 제도적으로 보장한다. 정당설립의 자유에는 정당존속의 자유, 정당활동의 자유, 원하는 명칭을 사용할 자유가 포함되며, 이를 제한하는 법률은 헌법 제37조 제2항에 따른 엄격한 비례심사를 받는다. 등록취소조항은 정치적 의사형성에 참여할 의사나 능력이 없는 정당을 배제하려는 한도에서 목적의 정당성과 수단의 적합성이 인정된다. 그러나 단 한 번의 국회의원선거 결과로 정당의 존속 자체를 박탈하므로 침해의 최소성과 법익의 균형성을 갖추지 못하였다. 등록취소된 정당의 명칭 사용을 금지한 조항도 등록취소조항을 전제로 하므로 같은 이유로 위헌이다.

확인 정당설립의 자유는 정당을 새로 설립할 자유만을 뜻하므로, 이미 등록된 정당의 등록을 취소하는 것은 정당설립의 자유에 대한 제한이 아니다. **(O · X)**

핵심어 정당설립의 자유·정당존속의 자유·복수정당제·정당등록취소·엄격한 비례심사
함께 읽기 3-001 · 특-006 · 특-005 · 3-002
확인 답 X — 정당설립의 자유는 당연히 정당존속의 자유와 정당활동의 자유를 포함하므로 등록취소는 정당설립의 자유를 제한한다.

제10조 모든 국민은 인간으로서의 존엄과 가치를 가지며, 행복을 추구할 권리를 가진다. 국가는 개인이 가지는 불가침의 기본적 인권을 확인하고 이를 보장할 의무를 진다.

착상 전 초기배아 — 기본권 주체성 부정

헌재 2010. 5. 27. 2005헌마346 생명윤리 및 안전에 관한 법률 제13조 제1항 등 위헌확인

최근 5년 기출 **2026** 경찰간부후보생 | **2025** 비상대비 · 소방간부후보생 | **2024** 경찰 승진시험 · 국회직 5급 | **2023** 경찰 | **2022** 해양경찰

사실 청구인 배아들은 부부인 두 청구인이 임신을 목적으로 제공한 정자와 난자를 체외 인공수정하여 생성한 배아 가운데, 아내의 체내에 이식되지 않고 의료기관에 보존되어 있던 배아이다. 이 배아들과 부부, 그리고 의사·교수 등 다른 청구인들은 잔여배아의 보존기간과 폐기, 연구목적 이용 등을 정한 생명윤리 및 안전에 관한 법률 조항들이 기본권을 침해한다며 헌법소원심판을 청구하였다.

쟁점 **수정은 되었지만 아직 모체에 착상되지 않은 초기배아도 기본권의 주체가 될 수 있을까?**

판단 출생 전 형성 중의 생명에 대해서 헌법적 보호의 필요성이 크고 일정한 경우 그 기본권 주체성이 긍정된다고 하더라도, 어느 시점부터 기본권 주체성이 인정되는지, 또 어떤 기본권에 대해 기본권 주체성이 인정되는지는 생명의 근원에 대한 생물학적 인식을 비롯한 자연과학·기술 발전의 성과와 그에 터 잡은 헌법의 해석으로부터 도출되는 규범적 요청을 고려하여 판단하여야 할 것이다. … 초기배아는 수정이 된 배아라는 점에서 형성 중인 생명의 첫걸음을 떼었다고 볼 여지가 있기는 하나 아직 모체에 착상되거나 원시선이 나타나지 않은 이상 현재의 자연과학적 인식 수준에서 독립된 인간과 배아 간의 개체적 연속성을 확정하기 어렵다고 봄이 일반적이라는 점, … 등을 종합적으로 고려할 때, 기본권 주체성을 인정하기 어렵다. — 결정요지 가.

해설 출생 전 형성 중의 생명도 일정한 경우 기본권 주체성이 긍정될 수 있으나, 그 시점과 범위는 자연과학·기술 발전의 성과와 그에 터 잡은 헌법해석의 규범적 요청을 고려하여 정한다. 헌법재판소는 착상 전이고 원시선도 나타나지 않은 초기배아의 기본권 주체성을 부정하였다. 독립된 인간과의 개체적 연속성을 확정하기 어렵고, 모태에 수용되어야 비로소 성장가능성을 기대할 수 있으며, 인간으로 취급하여야 한다는 사회적 승인도 없다는 것이다. 그래서 청구인 배아들의 청구인적격은 인정되지 않았으나, 초기배아에 대하여도 국가의 보호의무는 인정된다. 한편 배아생성자의 배아에 대한 결정권은 헌법 제10조에서 도출되는 일반적 인격권의 한 유형이지만, 잔여배아를 5년간 보존한 뒤 폐기하도록 한 조항은 이를 침해하지 않는다고 보았다.

확인 수정된 배아는 형성 중인 생명의 첫걸음을 뗀 것이므로 모체에 착상되기 전이라도 기본권 주체성이 인정된다. **(O · X)**

핵심어 기본권 주체성·초기배아·청구인적격·국가의 보호의무·배아생성자의 결정권

함께 읽기 1-008 · 3-003 · 1-005 · 1-006 · 특-010 · 4-002 · 2-004 · 1-007 · 특-008 · 특-007 · 특-009 · 2-005 외 1

확인 답 X — 모체에 착상되거나 원시선이 나타나지 않은 초기배아는 독립된 인간과의 개체적 연속성을 확정하기 어려워 기본권 주체성을 인정하기 어렵다.

제11조
①모든 국민은 법 앞에 평등하다. 누구든지 성별·종교 또는 사회적 신분에 의하여 정치적·경제적·사회적·문화적 생활의 모든 영역에 있어서 차별을 받지 아니한다.
②사회적 특수계급의 제도는 인정되지 아니하며, 어떠한 형태로도 이를 창설할 수 없다.
③훈장등의 영전은 이를 받은 자에게만 효력이 있고, 어떠한 특권도 이에 따르지 아니한다.

제대군인 가산점 — 평등권·공무담임권 침해

헌재 1999. 12. 23. 98헌마363 제대군인지원에관한법률 제8조 제1항 등 위헌확인

최근 5년 기출 **2026** 경찰간부후보생 · 국가직 5급 · 국회직 5급 · 법무사 · 법원행시 · 외교관후보자 선발시험 · 지역인재 7급 | **2025** 국회직 9급 · 법무사 · 비상대비 | **2024** 소방간부후보생 | **2023** 경찰 승진시험 · 국가직 5급 · 국회직 8급 · 해양경찰 | **2022** 국회직 8급

사실 제대군인지원에관한법률 제8조 제1항 등은 제대군인이 6급 이하 공무원 등의 채용시험을 치르면 필기시험의 각 과목별 득점에 과목별 만점의 5퍼센트 또는 3퍼센트를 가산하도록 하였다. 청구인들은 7급 또는 9급 국가공무원 공개경쟁채용시험을 준비하던 여성 5명과 신체장애가 있는 남성 1명이다. 청구인들은 이 가산점제도가 평등권, 공무담임권, 직업선택의 자유를 침해한다며 헌법소원심판을 청구하였다.

쟁점 **제대군인에게 공무원 채용 필기점수를 더해 주는 가산점제도는 여성과 장애인의 평등권을 침해할까?**

판단 평등위반 여부를 심사함에 있어 엄격한 심사척도에 의할 것인지, 완화된 심사척도에 의할 것인지는 입법자에게 인정되는 입법형성권의 정도에 따라 달라지게 될 것이나, 헌법에서 특별히 평등을 요구하고 있는 경우와 차별적 취급으로 인하여 관련 기본권에 대한 중대한 제한을 초래하게 된다면 입법형성권은 축소되어 보다 엄격한 심사척도가 적용되어야 할 것인바, 가산점제도는 헌법 제32조 제4항이 특별히 남녀평등을 요구하고 있는 "근로" 내지 "고용"의 영역에서 남성과 여성을 달리 취급하는 제도이고, 또한 헌법 제25조에 의하여 보장된 공무담임권이라는 기본권의 행사에 중대한 제약을 초래하는 것이기 때문에 엄격한 심사척도가 적용된다. … 가산점제도는 제대군인에 비하여, 여성 및 제대군인이 아닌 남성을 부당한 방법으로 지나치게 차별하는 것으로서 헌법 제11조에 위배되며, 이로 인하여 청구인들의 평등권이 침해된다. … 가산점제도는 … 헌법 제25조에 위배되고, 이로 인하여 청구인들의 공무담임권이 침해된다. — 결정요지 3·4.다.·5

해설 가산점제도는 형식상 제대군인과 제대군인이 아닌 사람을 구별하지만, 실질적으로는 여성, 그리고 병역면제자나 보충역으로 복무를 마친 남성을 차별하는 제도이다. 헌법이 특별히 평등을 요구하는 영역에서의 차별이거나 차별로 관련 기본권에 중대한 제한이 생기면, 차별의 목적과 수단 사이에 엄격한 비례관계가 있는지를 따지는 엄격한 심사척도가 적용된다. 제대군인의 사회복귀 지원이라는 목적은 정당하나, 여성과 장애인 등의 기회를 박탈하는 수단은 적합성을 잃었고 차별의 효과가 극심하여 비례성도 상실하였다. 헌법 제39조 제2항은 병역의무 이행으로 불이익한 처우를 받지 않게 할 뿐 보상 의무를 지우지 않으므로 가산점제도의 근거가 되지 못한다.

확인 가산점제도의 평등위반 여부는 입법자의 넓은 형성권을 존중하여 자의금지원칙에 따른 완화된 심사척도로 판단한다. **(O · X)**

핵심어 평등권·엄격한 심사척도·비례성원칙·제대군인 가산점·공무담임권
함께 읽기 특-115 · 특-015 · 1-012 · 특-011 · 특-013 · 1-011 · 특-014 · 1-009 · 특-012 · 1-010 · 1-013 · 특-016
확인 답 X — 가산점제도는 헌법이 특별히 남녀평등을 요구하는 고용 영역에서 남녀를 달리 취급하고 공무담임권에 중대한 제약을 초래하므로 엄격한 심사척도가 적용된다.

제17조 모든 국민은 사생활의 비밀과 자유를 침해받지 아니한다.

교원노조 가입현황 공개 — 개인정보자기결정권 침해

대법원 2014. 7. 24. 선고 2012다49933 판결 손해배상(기)

최근 5년 기출 **2026** 해양경찰 | **2025** 경찰 승진시험 · 경찰간부후보생 · 국가직 5급 · 법원행시 · 비상대비 · 외교관후보자 선발시험 · 지역인재 7급 | **2024** 경찰 · 국회직 5급 · 법원행시 · 소방간부후보생 · 해양경찰 | **2023** 경찰 · 법무사 · 법원직 9급 | **2022** 국회직 8급 · 군무원 · 법원행시 · 비상대비 · 해양경찰

사실 국회의원이던 갑은 학교장들이 교원단체 및 노동조합 가입 인원을 사실대로 공시하는지 확인한다는 명분으로 교육과학기술부장관에게 요청하여 자료를 받았다. 이 자료에는 학교명, 교사명, 담당교과, 교원단체 및 노동조합 가입현황 등이 담겨 있었는데, 갑 등은 이를 인터넷을 통하여 공개하였다. 교원들과 전국교직원노동조합이 갑 등을 상대로 손해배상을 청구하였고, 원심은 공개행위가 위법하다고 보았다.

쟁점 **교사의 이름과 교원노조 가입 여부가 담긴 자료를 인터넷에 공개하면 개인정보자기결정권 침해가 될까?**

판단 인간의 존엄과 가치, 행복추구권을 규정한 헌법 제10조 제1문에서 도출되는 일반적 인격권 및 헌법 제17조의 사생활의 비밀과 자유에 의하여 보장되는 개인정보자기결정권은 자신에 관한 정보가 언제 누구에게 어느 범위까지 알려지고 또 이용되도록 할 것인지를 정보주체가 스스로 결정할 수 있는 권리이다. 개인정보자기결정권의 보호대상이 되는 개인정보는 개인의 신체, 신념, 사회적 지위, 신분 등과 같이 개인의 인격주체성을 특징짓는 사항으로서 개인의 동일성을 식별할 수 있게 하는 일체의 정보라고 할 수 있고, 반드시 개인의 내밀한 영역에 속하는 정보에 국한되지 않고 공적 생활에서 형성되었거나 이미 공개된 개인정보까지 포함한다. … 이 사건 정보를 일반 대중에게 공개하는 행위는 해당 교원들의 개인정보자기결정권의 침해에 해당한다고 봄이 상당하다. — 판결요지 [1], 이유 1.

해설 개인정보자기결정권은 헌법 제10조 제1문에서 도출되는 일반적 인격권과 헌법 제17조의 사생활의 비밀과 자유에 의하여 보장된다. 보호대상인 개인정보는 개인의 동일성을 식별할 수 있게 하는 일체의 정보로서 내밀한 영역의 정보에 한정되지 않는다. 특정 교원을 식별하고 그 조합원 신분을 알 수 있게 하는 이 사건 정보도 이에 해당한다. 다만 공개행위의 최종적인 위법성은 공개로 얻는 이익과 비공개로 보호되는 이익을 구체적으로 비교 형량하여 판단한다. 대법원은 자료를 받은 목적에 어긋난 공개였고 인터넷을 통해 순식간에 광범위하게 전파될 수 있는 점 등을 들어, 공개로 얻는 이익이 비공개로 보호되는 이익보다 우월하다고 할 수 없다고 보았다. 조합원 신분이 공개되면 전국교직원노동조합의 존속·유지·발전에 관한 권리도 침해된다고 하였다.

확인 공적 생활에서 형성되었거나 이미 공개된 정보는 개인정보자기결정권의 보호대상인 개인정보에 해당하지 않는다. **(O · X)**

핵심어 개인정보자기결정권·개인정보·일반적 인격권·사생활의 비밀과 자유·이익형량

함께 읽기 2-018 · 2-017 · 특-043 · 1-026 · 특-044 · 특-047 · 특-046 · 특-045

확인 답 X — 보호대상인 개인정보는 개인의 내밀한 영역에 속하는 정보에 국한되지 않고 공적 생활에서 형성되었거나 이미 공개된 개인정보까지 포함한다.

제19조 모든 국민은 양심의 자유를 가진다.

국가보안법상 불고지죄 — 양심의 자유 침해 아님

헌재 1998. 7. 16. 96헌바35 구 국가보안법 제10조 위헌소원

최근 5년 기출 **2026** 경찰간부후보생 · 법무사 | **2025** 국회직 8급 · 국회직 9급 | **2024** 소방간부후보생 | **2023** 국가직 5급 · 국회직 8급 · 군무원 · 해양경찰 | **2022** 경찰 승진시험 · 법원직 9급 · 법원행시

사실 구 국가보안법 제10조는 같은 법 제3조 내지 제9조의 죄를 범한 자라는 정을 알면서 수사기관 또는 정보기관에 고지하지 아니한 자를 처벌하였다. 청구인은 차남이 북한 지역으로 탈출하였다가 다시 잠입하여 간첩활동을 하고 있다는 정을 알면서도 이를 고지하지 아니하였다는 등의 범죄사실로 기소되어 유죄판결을 받았다. 청구인은 항소심에서 위 조항에 대한 위헌제청신청이 기각되자 헌법소원심판을 청구하였다.

쟁점 **간첩 등의 범죄를 알고도 수사기관에 알리지 않은 사람을 처벌하는 불고지죄는 양심의 자유를 침해할까?**

판단 그런데 이 사건 심판대상 법률조항이 규정한 불고지죄는 국가의 존립과 안전에 저해가 되는 타인의 범행에 관한 객관적 사실을 고지할 의무를 부과할 뿐이고 개인의 세계관·인생관·주의·신조 등이나 내심에 있어서의 윤리적 판단을 그 고지의 대상으로 하는 것은 아니므로 양심의 자유 특히 침묵의 자유를 직접적으로 침해하는 것이라고 볼 수 없을 뿐만 아니라 … 이를 수사기관 또는 정보기관에 고지하는 것이 양심이나 사상에 어긋난다는 등의 이유로 고지하지 아니하는 것은 결국 부작위에 의한 양심실현 즉 내심의 의사를 외부에 표현하거나 실현하는 행위가 되는 것이고 이는 이미 순수한 내심의 영역을 벗어난 것이므로 이에 대하여는 필요한 경우 법률에 의한 제한이 가능하다 할 것이다. … 그러므로 이 사건 심판대상 법률조항은 양심의 자유를 침해한 것이라고 할 수 없다. — 이유 3. 나.

해설 양심의 자유에는 양심형성의 자유와 양심적 결정의 자유라는 내심적 자유와, 양심적 결정을 외부로 표현하고 실현하는 양심실현의 자유가 포함된다. 내심적 자유는 내심에 머무르는 한 절대적이지만, 양심실현의 자유는 헌법 제37조 제2항에 따라 법률로 제한될 수 있는 상대적 자유이다. 불고지죄는 타인의 범행이라는 객관적 사실을 알리게 할 뿐 윤리적 판단을 고지하게 하지 않으므로 침묵의 자유를 직접 침해하지 않는다. 양심을 이유로 고지하지 않는 것은 부작위에 의한 양심실현이어서 법률로 제한할 수 있다. 남북한의 긴장관계, 보호법익의 중요성, 친족에 대한 형의 감면 특례 등에 비추어 과잉금지원칙에도 위반되지 않는다. 고지의 대상은 자기가 아닌 타인의 범죄사실이므로 진술거부권의 문제도 생기지 않는다.

확인 불고지죄는 개인의 내심에 있는 윤리적 판단을 고지하도록 강제하므로 양심의 자유 중 침묵의 자유를 직접 침해한다. **(O · X)**

핵심어 양심의 자유·침묵의 자유·양심실현의 자유·불고지죄·진술거부권

함께 읽기 특-049 · 1-018 · 3-007 · 3-006

확인 답 X — 불고지죄는 타인의 범행에 관한 객관적 사실을 고지할 의무를 부과할 뿐 내심의 윤리적 판단을 고지의 대상으로 하지 않는다.

제21조
①모든 국민은 언론·출판의 자유와 집회·결사의 자유를 가진다.

외교기관 인근 집회의 전면금지 — 집회의 자유 침해

헌재 2003. 10. 30. 2000헌바67 집회및시위에관한법률 제11조 제1호 중 국내주재 외국의 외교기관 부분 위헌소원

최근 5년 기출 **2025** 법원직 9급 · 해양경찰 | **2024** 경찰 · 경찰 승진시험 · 지방직 7급 · 해양경찰 | **2023** 경찰 · 법무사 | **2022** 경찰 승진시험 · 경찰간부후보생 · 소방간부후보생 · 지방직 7급

사실 집회및시위에관한법률 제11조는 국내주재 외국의 외교기관 청사의 경계지점으로부터 1백미터 이내의 장소에서 옥외집회와 시위를 금지하였다. 청구인이 서울 광화문 시민열린마당의 공터에서 옥외집회를 열겠다고 신고하자, 관할 경찰서장은 그곳이 미국대사관과 일본대사관 영사부의 경계로부터 각각 97미터, 35미터밖에 떨어져 있지 않다며 금지통고를 하였다. 청구인은 그 취소를 구하는 행정소송에서 위 조항에 대한 위헌제청신청이 기각되자 헌법소원심판을 청구하였다.

쟁점 **외교기관 경계로부터 1백미터 안에서는 예외 없이 옥외집회를 금지하는 법률조항은 집회의 자유를 침해할까?**

판단 특정장소에서의 집회가 이 사건 법률조항에 의하여 보호되는 법익에 대한 직접적인 위협을 초래한다는 일반적 추정이 구체적인 상황에 의하여 부인될 수 있다면, 입법자는 '최소침해의 원칙'의 관점에서 금지에 대한 예외적인 허가를 할 수 있도록 규정해야 한다. … 따라서 입법자가 '외교기관 인근에서의 집회의 경우에는 일반적으로 고도의 법익충돌위험이 있다'는 예측판단을 전제로 하여 이 장소에서의 집회를 원칙적으로 금지할 수는 있으나, 일반·추상적인 법규정으로부터 발생하는 과도한 기본권제한의 가능성이 완화될 수 있도록 일반적 금지에 대한 예외조항을 두어야 할 것이다. … 그러므로 이 사건 법률조항은 최소침해의 원칙에 위반되어 집회의 자유를 과도하게 침해하는 위헌적인 규정이다. — 결정요지 9·10

해설 집회의 자유는 집회의 시간·장소·방법과 목적을 스스로 결정할 권리를 보장하며, 집회장소는 집회의 목적과 효과에 중요한 의미를 가진다. 헌법재판소는 외교기관의 기능보장과 외교공관의 안녕보호라는 입법목적을 인정하고, 특정 장소에서의 집회를 원칙적으로 금지하는 특별규정을 두는 것 자체는 과도한 규제가 아니라고 보았다. 그러나 외교기관이 아닌 다른 대상을 향한 집회, 소규모의 평화적 집회, 외교기관의 업무가 없는 휴일의 집회처럼 법익충돌의 위험이 작은 경우까지 예외 없이 금지한 것은 최소침해의 원칙에 반한다. 한편 집회의 금지와 해산은 조건을 붙여 허용하는 등 덜 제한적인 수단을 모두 소진한 뒤에 비로소 고려할 수 있는 최종적 수단이다.

확인 외교기관 인근에서의 옥외집회를 원칙적으로 금지하는 것 자체가 허용되지 않으므로 이 사건 법률조항은 위헌이다. **(O · X)**

핵심어 집회의 자유·집회장소·옥외집회 금지장소·최소침해의 원칙·예외조항

함께 읽기 3-008 · 1-035 · 특-056 · 특-057 · 4-008 · 2-019 · 1-034 · 특-058 · 1-033 · 특-052 · 특-060 · 2-020 외 5

확인 답 X — 그 장소에서의 집회를 원칙적으로 금지할 수는 있으나, 위험이 구체적으로 존재하지 않는 경우를 위한 예외조항 없이 전면 금지한 점이 최소침해의 원칙에 위반된다.

제34조
①모든 국민은 인간다운 생활을 할 권리를 가진다.

최저생계비 고시 — 인간다운 생활을 할 권리 침해 아님

헌재 2004. 10. 28. 2002헌마328 2002년도 국민기초생활보장최저생계비 위헌확인

최근 5년 기출 **2026** 국가직 7급 | **2025** 경찰간부후보생 · 국가직 7급 | **2023** 경찰 · 국회직 8급 | **2022** 경찰 · 경찰 승진시험 · 해양경찰

사실 청구인들은 장애인 2명과 비장애인 1명으로 이루어진 한 가구로서 국민기초생활보장법에 따른 생계급여 수급자이다. 보건복지부장관은 2002년도 최저생계비를 가구별 인원수만을 기준으로 정하여 고시하면서, 장애인가구의 추가지출비용을 반영한 최저생계비는 따로 정하지 않았다. 청구인들은 이 고시가 인간다운 생활을 할 권리와 평등권 등을 침해한다며 헌법소원심판을 청구하였다.

쟁점 **장애로 인한 추가비용을 반영하지 않고 가구원 수만으로 정한 최저생계비 고시는 장애인가구의 인간다운 생활을 할 권리를 침해할까?**

판단 그러므로 국가가 인간다운 생활을 보장하기 위한 헌법적 의무를 다하였는지의 여부가 사법적 심사의 대상이 된 경우에는, 국가가 최저생활보장에 관한 입법을 전혀 하지 아니하였다든가 그 내용이 현저히 불합리하여 헌법상 용인될 수 있는 재량의 범위를 명백히 일탈한 경우에 한하여 헌법에 위반된다고 할 수 있다. … 국가가 생활능력 없는 장애인의 인간다운 생활을 보장하기 위하여 행하는 사회부조에는 국민기초생활보장법에 의한 생계급여 지급을 통한 최저생활보장 외에 다른 법령에 의하여 행하여지는 것도 있으므로, … 인간다운 생활을 보장하기 위한 객관적 내용의 최소한을 보장하고 있는지 여부는 보장법에 의한 생계급여만을 가지고 판단하여서는 아니되고, 그 외의 법령에 의거하여 국가가 최저생활보장을 위하여 지급하는 각종 급여나 각종 부담의 감면 등을 총괄한 수준으로 판단하여야 한다. … 이 사건 고시로 인하여 생활능력 없는 장애인가구 구성원의 인간다운 생활을 할 권리가 침해되었다고 할 수 없다. — 결정요지 첫째·둘째 문단, 이유 4. 가. (5)

해설 헌법 제34조 제1항의 인간다운 생활을 할 권리로부터는 인간의 존엄에 상응하는 최소한의 물질적 생활의 유지에 필요한 급부를 요구할 수 있는 구체적 권리가 상황에 따라 직접 도출될 수 있으나, 그 이상의 급부를 내용으로 하는 권리는 법률을 통하여 구체화될 때 비로소 인정되는 법률적 권리이다. 이 권리는 입법부·행정부에는 가능한 범위에서 최대한 보장하라는 행위규범이지만, 헌법재판에서는 국가가 객관적으로 필요한 최소한의 조치를 취하였는지를 심사하는 통제규범으로 작용한다. 이 사건에서는 소득평가액을 산정할 때 장애수당 등을 실제소득에서 공제하는 방식과 다른 법령에 따른 각종 급여·부담감면을 함께 고려하여 침해를 부정하였다. 장애인가구와 비장애인가구에 같은 최저생계비를 적용한 것도 자의적이지 않다고 보아 평등권 침해도 부정하였다.

확인 국가가 인간다운 생활을 보장하기 위한 최소한의 조치를 다하였는지는 국민기초생활보장법에 의한 생계급여의 수준만을 가지고 판단한다. **(O · X)**

핵심어 인간다운 생활을 할 권리·사회적 기본권·최저생계비·행위규범과 통제규범·입법재량
함께 읽기 3-018 · 특-107 · 1-061 · 특-106
확인 답 X — 생계급여만이 아니라 다른 법령에 따라 지급되는 각종 급여나 각종 부담의 감면 등을 총괄한 수준으로 판단하여야 한다.

제45조 국회의원은 국회에서 직무상 행한 발언과 표결에 관하여 국회 외에서 책임을 지지 아니한다.

국회의원 면책특권 — 보도자료 사전 배포도 직무부수행위

대법원 2011. 5. 13. 선고 2009도14442 판결 통신비밀보호법위반·명예훼손

최근 5년 기출 **2026** 국회직 9급 | **2025** 경찰 승진시험 | **2024** 경찰 승진시험 · 비상대비 | **2023** 경찰 승진시험(형법)

사실 국회 법제사법위원회 소속 국회의원인 피고인은 구 국가안전기획부가 대기업 고위관계자와 중앙일간지 사주의 대화를 불법 녹음한 자료를 입수하였다. 피고인은 그 대화 내용과, 전직 검찰간부인 피해자가 그 기업으로부터 떡값 명목의 금품을 받았다는 내용을 담은 보도자료를 작성하였다. 피고인은 위원회 개의 직전에 국회의원회관에서 이 보도자료를 기자들에게 배포하고, 같은 날 위원회에서 그 주요 내용을 발언하였다. 피고인은 허위사실적시 명예훼손과 통신비밀보호법 위반으로 기소되었다.

쟁점 **국회의원이 위원회에서 발언할 내용을 담은 보도자료를 회의 직전에 기자들에게 나누어 준 행위도 면책특권의 보호를 받을까?**

판단 헌법 제45조는 "국회의원은 국회에서 직무상 행한 발언과 표결에 관하여 국회 외에서 책임을 지지 아니한다"고 규정하여 국회의원의 면책특권을 인정하고 있다. … 따라서 면책특권의 대상이 되는 행위는 국회의 직무수행에 필수적인 국회의원의 국회 내에서의 직무상 발언과 표결이라는 의사표현행위 자체에만 국한되지 아니하고 이에 통상적으로 부수하여 행하여지는 행위까지 포함하며, 그와 같은 부수행위인지 여부는 구체적인 행위의 목적·장소·태양 등을 종합하여 개별적으로 판단하여야 한다. … 피고인이 국회 법제사법위원회에서 발언할 내용이 담긴 이 사건 보도자료를 사전에 배포한 행위는 국회의원의 면책특권의 대상이 되는 직무부수행위에 해당한다고 할 것이다. — 판결요지 [1], 이유 1.

해설 헌법 제45조의 면책특권은 국회의원이 국민의 대표자로서 국회 내에서 자유롭게 발언하고 표결할 수 있도록 보장하여 국회가 헌법상 권한을 적정하게 행사하게 하려는 것이다. 판례는 그 대상을 직무상 발언과 표결이라는 의사표현행위 자체에 한정하지 않고 이에 통상적으로 부수하여 행하여지는 행위까지 넓힌다. 부수행위인지는 행위의 목적·장소·태양 등을 종합하여 개별적으로 판단한다. 이 사건 보도자료는 위원회에서 발언할 내용을 정리한 것으로, 개의 직전 국회의원회관에서 보도의 편의를 위하여 배포되었다. 면책특권의 대상인 행위에 대한 공소는 공소제기의 절차가 법률의 규정에 위반하여 무효인 때에 해당하므로 기각하여야 한다.

범위 같은 보도자료를 자신의 인터넷 홈페이지에 게재한 행위에 대하여는 통신비밀보호법 위반죄의 정당행위 해당 여부를 따로 심사하여 이를 부정하였다.

확인 면책특권의 대상은 국회 내에서의 직무상 발언과 표결 자체에 국한되므로, 발언 전에 그 내용을 담은 보도자료를 배포한 행위는 면책되지 않는다. **(O · X)**

핵심어 면책특권·직무부수행위·국회의원·공소기각

함께 읽기 특-116 · 3-021

확인 답 X — 면책특권의 대상에는 직무상 발언과 표결에 통상적으로 부수하여 행하여지는 행위까지 포함되고, 이 사건 보도자료의 사전 배포는 직무부수행위에 해당한다.

제130조
①국회는 헌법개정안이 공고된 날로부터 60일 이내에 의결하여야 하며, 국회의 의결은 재적의원 3분의 2 이상의 찬성을 얻어야 한다.
②헌법개정안은 국회가 의결한 후 30일 이내에 국민투표에 붙여 국회의원선거권자 과반수의 투표와 투표자 과반수의 찬성을 얻어야 한다.
③헌법개정안이 제2항의 찬성을 얻은 때에는 헌법개정은 확정되며, 대통령은 즉시 이를 공포하여야 한다.

관습헌법인 수도 서울 — 법률로 이전하면 국민투표권 침해

헌재 2004. 10. 21. 2004헌마554 신행정수도의건설을위한특별조치법 위헌확인

최근 5년 기출 **2026** 경찰 승진시험 · 국회직 5급 | **2025** 국회직 8급 | **2024** 경찰 · 비상대비 · 해양경찰 | **2023** 경찰 · 경찰간부후보생 · 법원행시 · 해양경찰 | **2022** 경찰 · 경찰 승진시험 · 경찰간부후보생 · 해양경찰

사실 정부는 행정수도를 충청권으로 옮기는 신행정수도의건설을위한특별조치법안을 제안하였고, 국회는 2003. 12. 29. 이를 의결하였으며, 법률은 2004. 1. 16. 공포되었다. 서울특별시 소속 공무원, 서울특별시 의회 의원, 전국 각지의 국민 등인 청구인들은 이 법률이 헌법개정 등의 절차를 거치지 않은 수도이전을 추진하여 국민투표권 등을 침해한다며 헌법소원심판을 청구하였다.

쟁점 **서울이 수도라는 관습헌법을 헌법개정 없이 법률로 바꾸어 수도를 옮길 수 있을까?**

판단 관습헌법도 헌법의 일부로서 성문헌법의 경우와 동일한 효력을 가지기 때문에 그 법규범은 최소한 헌법 제130조에 의거한 헌법개정의 방법에 의하여만 개정될 수 있다. … 한편 헌법 제130조에 의하면 헌법의 개정은 반드시 국민투표를 거쳐야만 하므로 국민은 헌법개정에 관하여 찬반투표를 통하여 그 의견을 표명할 권리를 가진다. 그런데 이 사건 법률은 헌법개정사항인 수도의 이전을 헌법개정의 절차를 밟지 아니하고 단지 단순법률의 형태로 실현시킨 것으로서 결국 헌법 제130조에 따라 헌법개정에 있어서 국민이 가지는 참정권적 기본권인 국민투표권의 행사를 배제한 것이므로 동 권리를 침해하여 헌법에 위반된다. — 결정요지 11·14

해설 헌법재판소는 성문헌법 국가에서도 기본적 헌법사항에 관하여 관습헌법이 성립할 수 있다고 보고, 서울이 수도라는 점을 관습헌법으로 인정하였다. 관습헌법이 성립하려면 관행의 존재, 반복·계속성, 항상성, 명료성, 국민적 합의가 갖추어져야 한다. 관습헌법도 헌법이므로 헌법 제130조가 정한 국회의 의결과 국민투표를 거치는 헌법개정절차로만 바꿀 수 있고, 하위 규범인 법률로는 바꿀 수 없다. 다만 관습헌법은 성문헌법과 달리 반대 내용의 새 조항을 헌법에 넣는 것만으로 폐지되며, 국민적 합의를 잃으면 자연히 사멸할 수도 있다. 이 결정에는 헌법 제72조의 국민투표권 침해를 이유로 든 별개의견과 청구가 부적법하다는 반대의견이 있었다.

확인 관습헌법은 헌법전에 규정되어 있지 않으므로 법률의 형식으로 개정할 수 있다. **(O · X)**

핵심어 관습헌법·헌법개정절차·국민투표권·수도·경성헌법
함께 읽기 특-125 · 특-134
확인 답 X — 관습헌법도 성문헌법과 동일한 효력을 가지므로 헌법 제130조에 의거한 헌법개정의 방법에 의하여만 개정될 수 있다.

제68조(청구 사유)
① 공권력의 행사 또는 불행사(不行使)로 인하여 헌법상 보장된 기본권을 침해받은 자는 헌법재판소에 헌법소원심판을 청구할 수 있다. 다만, 다른 법률에 구제절차가 있는 경우에는 그 절차를 모두 거친 후에 청구할 수 있다.

조약 체결행위 — 헌법소원의 대상인 공권력의 행사

헌재 2001. 3. 21. 99헌마139 대한민국과일본국간의어업에관한협정비준 위헌확인

최근 5년 기출 **2025** 국가직 5급 · 법원행시 · 소방간부후보생 · 외교관후보자 선발시험 · 지방직 7급 · 지역인재 7급 · 해양경찰 | **2024** 국가직 5급 · 국회직 9급 · 해양경찰 | **2023** 경찰간부후보생 · 법원행시 · 소방간부후보생 · 해양경찰 | **2022** 경찰 승진시험 · 법무사 · 변호사시험 · 해양경찰

사실 대한민국과일본국간의어업에관한협정은 1999. 1. 6. 국회 본회의에서 비준동의안이 가결되어 1999. 1. 22. 발효되었다. 어민과 변호사 등인 청구인들은 이 협정이 독도 등을 중간수역에 포함시키고 조업수역을 축소하여 영토권, 행복추구권, 직업선택의 자유, 재산권 등을 침해한다며 헌법소원심판을 청구하였다. 헌법재판소는 어업에 종사하지 않는 청구인들의 청구를 각하하고 나머지 청구를 기각하였다.

쟁점 **정부가 외국과 조약을 체결한 행위도 헌법소원으로 다툴 수 있는 '공권력의 행사'에 해당할까?**

판단 헌법소원심판의 대상이 되는 것은 헌법에 위반된 "공권력의 행사 또는 불행사"이다. 여기서 '공권력'이란 입법권·행정권·사법권을 행사하는 모든 국가기관·공공단체등의 고권적 작용이라고 할 수 있는바, 이 사건 협정은 우리나라 정부가 일본 정부와의 사이에서 어업에 관해 체결·공포한 조약(조약 제1477호)으로서 헌법 제6조 제1항에 의하여 국내법과 같은 효력을 가지므로, 그 체결행위는 고권적 행위로서 '공권력의 행사'에 해당한다. — 이유 3. 가. (1)

해설 헌법재판소법 제68조 제1항의 헌법소원은 공권력의 행사 또는 불행사로 헌법상 보장된 기본권을 침해받은 자가 청구한다. 여기서 공권력은 입법권·행정권·사법권을 행사하는 모든 국가기관·공공단체 등의 고권적 작용을 말한다. 헌법에 의하여 체결·공포된 조약은 헌법 제6조 제1항에 따라 국내법과 같은 효력을 가지므로, 이 사건 협정의 체결행위는 고권적 행위로서 공권력의 행사에 해당한다. 반면 이 사건 협정의 합의의사록은 구체적인 법률관계의 발생을 목적으로 한 것이 아니어서 조약에 해당하지 않는다고 보았다. 이 결정은 또 헌법전문의 3·1정신은 헌법소원의 대상인 기본권이 아니지만, 영토권은 그 기본권의 하나로 간주할 수 있다고 하였다.

현행 2026. 3. 12. 개정으로 제1항 본문의 '법원의 재판을 제외하고는' 부분이 삭제되고, 법원의 재판에 대한 헌법소원은 확정된 재판을 대상으로 일정한 경우에 한하여 청구할 수 있다는 제3항이 신설되었다.

확인 조약은 국가 사이의 합의일 뿐이므로 정부의 조약 체결행위는 헌법소원의 대상인 공권력의 행사에 해당하지 않는다. **(O · X)**

핵심어 헌법소원의 대상·공권력의 행사·조약·고권적 작용·영토권
함께 읽기 특-144 · 특-142 · 3-028 · 특-143 · 3-030 · 3-029 · 특-146 · 특-147 · 2-037 · 특-145 · 특-156 · 1-096 외 18
확인 답 X — 이 사건 협정은 헌법 제6조 제1항에 의하여 국내법과 같은 효력을 가지므로 그 체결행위는 고권적 행위로서 공권력의 행사에 해당한다.

제1조(법원) 민사에 관하여 법률에 규정이 없으면 관습법에 의하고 관습법이 없으면 조리에 의한다.

관습법의 효력 — 변화한 법질서에 맞지 않으면 부정된다

대법원 2005. 7. 21. 선고 2002다1178 전원합의체 판결 종회회원확인

최근 5년 기출 **2026** 경찰(경찰학) · 행정사 | **2025** 법무사 · 세무사 · 주택관리사보 | **2024** 가맹거래사 | **2023** 주택관리사보 | **2022** 행정사

사실 A종회는 중시조의 후손으로 이루어진 종중이고, 갑 등은 그 중시조의 후손인 여성들이다. A종회의 규약은 중시조의 '후손으로서 성년이 되면 회원자격을 가진다'고만 정하고 있었다. 갑 등이 종회 회원(종원) 지위의 확인을 구하였으나, 원심은 종래 관습상 종중은 성년 남자를 구성원으로 하고 여성은 구성원이 될 수 없다는 이유로 청구를 배척하였다.

쟁점 **한때 관습법으로 인정된 관행이라도, 사회와 법질서가 바뀌어 맞지 않게 되면 효력을 잃을까?**

판단 관습법이란 사회의 거듭된 관행으로 생성한 사회생활규범이 사회의 법적 확신과 인식에 의하여 법적 규범으로 승인·강행되기에 이른 것을 말하고, 그러한 관습법은 법원(法源)으로서 법령에 저촉되지 아니하는 한 법칙으로서의 효력이 있는 것이고, … 헌법을 최상위 규범으로 하는 전체 법질서에 반하지 아니하는 것으로서 정당성과 합리성이 있다고 인정될 수 있는 것이어야 하고, … 사회의 거듭된 관행으로 생성된 사회생활규범이 관습법으로 승인되었다고 하더라도 사회 구성원들이 그러한 관행의 법적 구속력에 대하여 확신을 갖지 않게 되었다거나, 사회를 지배하는 기본적 이념이나 사회질서의 변화로 인하여 그러한 관습법을 적용하여야 할 시점에 있어서의 전체 법질서에 부합하지 않게 되었다면 그러한 관습법은 법적 규범으로서의 효력이 부정될 수밖에 없다. — 판결요지 [1]·[2]

해설 민법 제1조는 민사에 관하여 법률에 규정이 없으면 관습법에 의하도록 하여 관습법을 법원(法源)으로 삼는다. 관습법은 거듭된 관행이 사회의 법적 확신에 의하여 법규범으로 승인된 것이고, 헌법을 최상위 규범으로 하는 전체 법질서에 반하지 않는 정당성과 합리성을 갖추어야 한다. 한때 관습법으로 승인되었더라도 사회 구성원들이 그 법적 구속력에 대한 확신을 갖지 않게 되거나, 적용 시점의 전체 법질서에 부합하지 않게 되면 효력이 부정된다. 이 판결은 종중 구성원을 성년 남자로 제한하던 관습법이 양성평등으로 변화한 법질서에 맞지 않아 효력을 잃었다고 보고, 공동선조와 성과 본을 같이 하는 후손은 성별 구별 없이 성년이 되면 당연히 종원이 된다고 하였다.

범위 변경된 견해는 판결 선고 이후 새로 성립하는 법률관계에만 적용되고, 이 사건 청구에 한하여 소급 적용되었다.

확인 거듭된 관행이 법적 확신을 얻어 관습법으로 승인되었다면, 그 뒤 전체 법질서가 바뀌더라도 관습법으로서의 효력은 유지된다. **(O · X)**

핵심어 관습법·법원(法源)·법적 확신·전체 법질서·종중 구성원

함께 읽기 2-041 · 특-162 · 특-161 · 2-042

확인 답 X — 관습법을 적용하여야 할 시점의 전체 법질서에 부합하지 않게 되면 그 관습법은 법적 규범으로서의 효력이 부정된다.

제35조(법인의 불법행위능력)
①법인은 이사 기타 대표자가 그 직무에 관하여 타인에게 가한 손해를 배상할 책임이 있다. 이사 기타 대표자는 이로 인하여 자기의 손해배상책임을 면하지 못한다.

비법인사단의 불법행위책임 — 악의·중과실 피해자에게는 없다

대법원 2008. 1. 18. 선고 2005다34711 판결 손해배상(기)

최근 5년 기출 **2026** 세무사 | **2025** 감정평가사 | **2024** 법원행시

사실 을 종중의 대표자 병은 적법한 총회결의를 거치지 않고 갑에게 임야를 파는 매매계약을 맺었고, 이 계약은 무효가 되었다. 계약 뒤 종중원 상당수가 반대하며 병에 대한 해임결의를 하는 등 분쟁이 생겼다. 갑은 병이 반대를 무릅쓰고 계약 이행에 협조하도록, 다른 종중원들 몰래 병에게 개인적으로 5,000만 원을 주었다. 갑은 이 돈에 대하여도 을 종중에 배상책임이 있다고 주장하였으나, 원심은 받아들이지 않았다.

쟁점 **비법인사단 대표자의 행위가 직무에 관한 행위가 아님을 피해자가 알았거나 중대한 과실로 몰랐다면, 사단에 손해배상책임을 물을 수 있을까?**

판단 비법인사단의 대표자가 직무에 관하여 타인에게 손해를 가한 경우 그 사단은 민법 제35조 제1항의 유추적용에 의하여 그 손해를 배상할 책임이 있고, … 그 대표자의 행위가 직무에 관한 행위에 해당하지 아니함을 피해자 자신이 알았거나 또는 중대한 과실로 인하여 알지 못한 경우에는 비법인사단에게 손해배상책임을 물을 수 없다. 여기서 중대한 과실이라 함은, 거래의 상대방이 조금만 주의를 기울였더라면 대표자의 행위가 그 직무권한 내에서 적법하게 행하여진 것이 아니라는 사정을 알 수 있었음에도 만연히 이를 직무권한 내의 행위라고 믿음으로써 일반인에게 요구되는 주의의무에 현저히 위반하는 것으로 거의 고의에 가까운 정도의 주의를 결여하고, 공평의 관점에서 상대방을 구태여 보호할 필요가 없다고 봄이 상당하다고 인정되는 상태를 말한다. — 판결요지 [1]

해설 민법 제35조 제1항에 따라 법인은 이사 기타 대표자가 직무에 관하여 타인에게 가한 손해를 배상할 책임이 있고, 판례는 이를 비법인사단에 유추적용한다. 직무에 관한 행위인지는 외관상, 객관적으로 판단하므로 대표자가 개인의 사리를 도모하였거나 법령에 위배한 행위도 이에 해당할 수 있다. 다만 피해자가 직무에 관한 행위가 아님을 알았거나 중대한 과실로 몰랐다면, 공평의 관점에서 보호할 필요가 없어 사단에 책임을 물을 수 없다. 갑이 병에게 준 돈은 외관상 병의 직무집행과 관련된 것으로 볼 수는 있다. 그러나 갑은 병이 권한 내에서 적법하게 행동하는 것이 아님을 알았거나 조금만 주의하면 알 수 있었다. 이 판결은 또 무효인 매매의 매도인이 대금을 정기예금에 넣어 얻은 이자도 반환할 부당이득에 포함된다고 보았다.

확인 비법인사단 대표자의 행위가 외관상, 객관적으로 직무에 관한 행위라면, 피해자가 직무에 관한 행위가 아님을 알았더라도 사단은 손해배상책임을 진다. **(O · X)**

핵심어 법인의 불법행위능력·비법인사단·유추적용·직무에 관한 행위·중대한 과실
함께 읽기 1-107
확인 답 X — 피해자 자신이 알았거나 중대한 과실로 알지 못한 경우에는 비법인사단에게 손해배상책임을 물을 수 없다.

제108조(통정한 허위의 의사표시)
①상대방과 통정한 허위의 의사표시는 무효로 한다.

통정허위표시와 채권자취소권 — 취소 대상이 되어도 무효

대법원 1998. 2. 27. 선고 97다50985 판결 과지불매매대금등

최근 5년 기출 **2026** 가맹거래사 · 변리사 · 세무사 | **2025** 가맹거래사 · 공인중개사 · 노무사 · 주택관리사보 | **2024** 가맹거래사 · 법원행시 | **2023** 노무사 · 행정사

사실 A회사는 을을 상대로 공사대금 등 청구소송을 내어 가집행선고부 승소판결을 받았다. 을은 건물에 대한 A회사의 강제집행을 피하려고, 건물과 대지를 갑에게 판다는 매매계약서를 작성하고 갑 앞으로 소유권이전등기를 마쳤다. 또 그 소송의 항소심에서 인용 금액을 줄이려고, 갑에게 부족한 건평의 대금 반환과 미완성 부분 공사비 지급을 약정하는 각서를 작성하여 법원에 제출하였다. A회사는 이 매매가 가장매매라며 갑을 상대로 사해행위취소소송을 냈다. 갑이 을에게 과지급 매매대금 등을 청구하자, 원심은 매매계약서와 각서가 통정허위표시로서 무효라고 보았다.

쟁점 **사해행위로 취소될 수 있는 가장매매라도, 통정허위표시의 요건을 갖추면 무효가 될까?**

판단 채무자의 법률행위가 통정허위표시인 경우에도 채권자취소권의 대상이 되고, 한편 채권자취소권의 대상으로 된 채무자의 법률행위라도 통정허위표시의 요건을 갖춘 경우에는 무효라고 할 것이다. — 판결요지

해설 상대방과 통정한 허위의 의사표시는 무효이다(민법 제108조 제1항). 이 판결은 통정허위표시와 채권자취소권이 서로를 배척하지 않는다고 보았다. 무효인 가장매매도 채권자취소권의 대상이 되고, 거꾸로 채권자취소권의 대상이 되었다고 하여 통정허위표시의 무효가 부정되지도 않는다. 다만 사해행위라는 사정만으로 통정허위표시가 되는 것은 아니며, 그 요건은 따로 따진다. 이 사건 매매계약서와 각서는 법률효과를 발생시킬 의도 없이 강제집행을 피하기 위한 수단으로 작성되었으므로 무효이고, 갑은 이를 근거로 돈을 청구할 수 없었다.

확인 채무자의 법률행위가 통정허위표시로서 무효라면, 채권자는 이를 채권자취소권의 대상으로 삼을 수 없다. **(O · X)**

핵심어 통정허위표시·가장매매·채권자취소권·사해행위
함께 읽기 1-230 · 4-025 · 3-037 · 특-201 · 1-127 · 특-200 · 특-199 · 2-051
확인 답 X — 채무자의 법률행위가 통정허위표시인 경우에도 채권자취소권의 대상이 된다.

제109조(착오로 인한 의사표시)
①의사표시는 법률행위의 내용의 중요부분에 착오가 있는 때에는 취소할 수 있다. 그러나 그 착오가 표의자의 중대한 과실로 인한 때에는 취소하지 못한다.

착오와 하자담보책임 — 담보책임이 있어도 취소할 수 있다

대법원 2018. 9. 13. 선고 2015다78703 판결 위약약정금

최근 5년 기출 **2026** 감정평가사 · 법무사 | **2025** 변리사 · 세무사 · 주택관리사보 | **2024** 행정사 | **2023** 감정평가사 · 법원행시 · 세무사 | **2022** 법무사 · 주택관리사보

사실 갑은 을로부터 서화 여러 점을 샀는데, 그중 5점이 위작이었고 갑은 이를 진품으로 알고 산 것이었다. 갑이 착오를 이유로 그 부분 매매계약을 취소하자, 을은 갑이 하자담보책임을 물을 수 있었으므로 착오를 이유로 취소할 수는 없다고 다투었다. 원심은 취소가 적법하다고 보아 을에게 위작 서화를 돌려받음과 동시에 부당이득을 반환하라고 하였다.

쟁점 **산 물건에 하자가 있어 하자담보책임을 물을 수 있는 매수인도, 착오를 이유로 매매계약을 취소할 수 있을까?**

판단 민법 제109조 제1항에 의하면 법률행위 내용의 중요 부분에 착오가 있는 경우 착오에 중대한 과실이 없는 표의자는 법률행위를 취소할 수 있고, 민법 제580조 제1항, 제575조 제1항에 의하면 매매의 목적물에 하자가 있는 경우 하자가 있는 사실을 과실 없이 알지 못한 매수인은 매도인에 대하여 하자담보책임을 물어 계약을 해제하거나 손해배상을 청구할 수 있다. 착오로 인한 취소 제도와 매도인의 하자담보책임 제도는 취지가 서로 다르고, 요건과 효과도 구별된다. 따라서 매매계약 내용의 중요 부분에 착오가 있는 경우 매수인은 매도인의 하자담보책임이 성립하는지와 상관없이 착오를 이유로 매매계약을 취소할 수 있다. – 판결요지

해설 민법 제109조 제1항에 따라 법률행위 내용의 중요부분에 착오가 있으면 표의자는 중대한 과실이 없는 한 의사표시를 취소할 수 있다. 한편 매매 목적물에 하자가 있으면 이를 과실 없이 알지 못한 매수인은 매도인에게 하자담보책임을 물어 계약을 해제하거나 손해배상을 청구할 수 있다. 두 제도는 취지가 다르고 요건과 효과도 구별되므로, 하자담보책임이 성립한다고 하여 착오를 이유로 한 취소가 막히지 않는다. 진품으로 알고 산 서화가 위작이면 매매계약 내용의 중요부분에 착오가 있는 것이어서, 매수인은 담보책임과 상관없이 계약을 취소할 수 있다.

확인 매매 목적물의 하자에 관하여 매도인의 하자담보책임이 성립하는 경우에는, 매수인은 착오를 이유로 매매계약을 취소할 수 없다. **(O · X)**

핵심어 착오에 의한 의사표시·법률행위 내용의 중요부분·하자담보책임·착오취소
함께 읽기 1-129 · 1-130 · 특-202 · 특-206 · 2-052 · 2-053 · 특-204 · 3-038 · 특-205 · 특-203 · 1-128 · 4-026
확인 답 X — 착오로 인한 취소 제도와 하자담보책임 제도는 취지·요건·효과가 구별되므로, 매수인은 하자담보책임의 성립과 상관없이 착오를 이유로 취소할 수 있다.

제126조(권한을 넘은 표현대리) 대리인이 그 권한외의 법률행위를 한 경우에 제삼자가 그 권한이 있다고 믿을 만한 정당한 이유가 있는 때에는 본인은 그 행위에 대하여 책임이 있다.

표현대리와 과실상계 — 본인의 책임을 경감할 수 없다

대법원 1996. 7. 12. 선고 95다49554 판결 매매대금반환

최근 5년 기출 **2026** 가맹거래사 · 세무사 | **2025** 노무사 | **2024** 가맹거래사 · 감정평가사 · 주택관리사보 | **2023** 가맹거래사 · 노무사 · 주택관리사보

사실 을은 갑으로부터 리스금융을 받는 데 필요한 대리권을 위임받아 갑의 인감도장과 인감증명서를 가지고 있었다. 리스회사인 A회사는 을과 리스물건에 관한 매매계약을 체결하면서, 리스금융에 필요한 모든 서류를 제출받아 확인하고 갑 명의 예금계좌로 매매대금을 송금하였다. A회사가 매매계약의 해제에 따른 매매대금의 반환을 구한 이 사건에서, 원심은 을의 행위를 권한을 넘은 표현대리로 보아 갑의 책임을 인정하였다. 갑은 A회사에도 과실이 있으니 반환할 금액을 줄여야 한다고 다투었다.

쟁점 **표현대리가 성립한 경우, 상대방에게도 과실이 있으면 본인의 책임을 줄일 수 있을까?**

판단 표현대리행위가 성립하는 경우에 그 본인은 표현대리행위에 의하여 전적인 책임을 져야 하고, 상대방에게 과실이 있다고 하더라도 과실상계의 법리를 유추적용하여 본인의 책임을 경감할 수 없다. — 판결요지

해설 민법 제126조에 따르면 대리인이 권한 밖의 법률행위를 하였더라도 제삼자가 그 권한이 있다고 믿을 만한 정당한 이유가 있으면 본인은 그 행위에 대하여 책임이 있다. 이 사건에서 대리인은 본인의 인감도장과 인감증명서를 가지고 있었고, 상대방은 필요한 서류를 모두 확인한 뒤 본인 명의 계좌로 대금을 보냈다. 리스거래가 이루어지는 통상의 실태에 비추어 정당한 이유가 인정되었다. 표현대리가 성립하면 본인은 그 행위에 대하여 전적인 책임을 진다. 따라서 상대방에게 과실이 있더라도 손해배상에서 쓰는 과실상계의 법리(민법 제396조)를 유추적용하여 본인의 책임을 줄일 수 없다.

확인 표현대리가 성립하더라도 상대방에게 과실이 있으면, 과실상계의 법리를 유추적용하여 본인의 책임을 경감할 수 있다. **(O · X)**

핵심어 권한을 넘은 표현대리·정당한 이유·과실상계·유추적용

함께 읽기 특-213 · 4-027

확인 답 X — 표현대리가 성립하면 본인은 전적인 책임을 지고, 상대방에게 과실이 있더라도 과실상계의 법리를 유추적용하여 그 책임을 경감할 수 없다.

제168조(소멸시효의 중단사유) 소멸시효는 다음 각호의 사유로 인하여 중단된다.
1. 청구
2. 압류 또는 가압류, 가처분
3. 승인

대항요건 없는 채권양수인의 소 — 소멸시효가 중단된다

대법원 2005. 11. 10. 선고 2005다41818 판결 손해배상(기)

최근 5년 기출 **2026** 법원직 9급 · 변리사 | **2025** 법무사 | **2024** 감정평가사 | **2023** 감정평가사

사실 A은행은 갑·을에 대한 불법행위 손해배상채권을 B회사에 양도하였고, 이 채권은 그 뒤 순차로 양도되었다. B회사는 2001. 5. 23. 갑·을을 상대로 손해배상청구의 소를 제기하였으나, A은행이 갑·을에게 양도를 통지한 것은 3년의 소멸시효기간이 지난 2004. 5. 17.이었다. 원심은 대항요건을 갖추지 못한 양수인의 소 제기로는 시효가 중단되지 않는다고 보아 갑·을의 소멸시효 항변을 받아들였다.

쟁점 **채무자에게 양도통지가 되기 전에 채권양수인이 소를 제기하였다면, 그 소 제기로 소멸시효가 중단될까?**

판단 채권양도는 구 채권자인 양도인과 신 채권자인 양수인 사이에 채권을 그 동일성을 유지하면서 전자로부터 후자에게로 이전시킬 것을 목적으로 하는 계약을 말한다 할 것이고, 채권양도에 의하여 채권은 그 동일성을 잃지 않고 양도인으로부터 양수인에게 이전되며, 이러한 법리는 채권양도의 대항요건을 갖추지 못하였다고 하더라도 마찬가지인 점, … 채무자를 상대로 재판상의 청구를 한 채권의 양수인을 '권리 위에 잠자는 자'라고 할 수 없는 점 등에 비추어 보면, 비록 대항요건을 갖추지 못하여 채무자에게 대항하지 못한다고 하더라도 채권의 양수인이 채무자를 상대로 재판상의 청구를 하였다면 이는 소멸시효 중단사유인 재판상의 청구에 해당한다고 보아야 한다. – 판결요지

해설 민법 제168조 제1호는 청구를 소멸시효의 중단사유로 정하고, 소를 제기하는 재판상 청구가 그 대표적인 예이다. 채권양도는 채권을 동일성을 유지한 채 양도인에게서 양수인에게 옮기는 계약이므로, 채무자에 대한 통지나 승낙이라는 대항요건을 갖추지 못하였더라도 채권은 양수인에게 이전한다. 대항요건이 없는 양수인은 채무자에게 대항하지 못할 뿐 채권자이고, 채무자를 상대로 소를 제기한 양수인을 '권리 위에 잠자는 자'라고 할 수 없다. 그래서 그 재판상 청구는 시효중단사유가 된다.

확인 채권양도의 대항요건을 갖추지 못한 양수인이 채무자를 상대로 소를 제기하였다면, 채무자에게 대항할 수 없으므로 그 소로 소멸시효가 중단되지 않는다. **(O · X)**

핵심어 소멸시효의 중단·재판상의 청구·채권양도·대항요건

함께 읽기 특-391 · 특-396 · 3-047 · 특-248 · 3-048 · 특-245 · 특-246 · 1-154 · 1-152 · 특-247 · 특-249 · 1-153

확인 답 X — 대항요건을 갖추지 못하였더라도 채권의 양수인이 채무자를 상대로 한 재판상의 청구는 소멸시효 중단사유인 재판상의 청구에 해당한다.

제186조(부동산물권변동의 효력) 부동산에 관한 법률행위로 인한 물권의 득실변경은 등기하여야 그 효력이 생긴다.

공유지분의 포기 — 등기하여야 물권변동의 효력이 생긴다

대법원 2016. 10. 27. 선고 2015다52978 판결 부당이득금반환

최근 5년 기출 **2025** 변리사 · 주택관리사보 | **2023** 주택관리사보 | **2022** 법무사 · 법원직 9급

사실 갑과 을은 한 토지의 공유자였다. 을은 갑 등 다른 공유자들을 상대로 낸 소장에서 자기 지분을 포기한다는 의사표시를 하였으나, 그에 따른 등기가 마쳐지기 전에 사망하였다. 병은 강제경매로 갑의 지분을 취득하였다. 그 뒤 병은 을의 상속인들을 상대로 한 소송을 거쳐, 을의 지분 중 갑이 이전등기를 청구할 수 있었던 부분까지 자기 앞으로 등기한 다음 처분하였다. 갑이 부당이득의 반환을 구하자 원심은 병에게 반환의무가 있다고 판단하였다.

쟁점 **공유자가 지분을 포기한다는 의사표시를 하면, 등기 없이도 그 지분이 곧바로 다른 공유자에게 넘어갈까?**

판단 민법 제267조는 "공유자가 그 지분을 포기하거나 상속인 없이 사망한 때에는 그 지분은 다른 공유자에게 각 지분의 비율로 귀속한다."라고 규정하고 있다. 여기서 공유지분의 포기는 법률행위로서 상대방 있는 단독행위에 해당하므로, 부동산 공유자의 공유지분 포기의 의사표시가 다른 공유자에게 도달하더라도 이로써 곧바로 공유지분 포기에 따른 물권변동의 효력이 발생하는 것은 아니고, 다른 공유자는 자신에게 귀속될 공유지분에 관하여 소유권이전등기청구권을 취득하며, 이후 민법 제186조에 의하여 등기를 하여야 공유지분 포기에 따른 물권변동의 효력이 발생한다. 그리고 부동산 공유자의 공유지분 포기에 따른 등기는 해당 지분에 관하여 다른 공유자 앞으로 소유권이전등기를 하는 형태가 되어야 한다. — 판결요지

해설 민법 제267조는 공유자가 지분을 포기하면 그 지분이 다른 공유자에게 각 지분의 비율로 귀속한다고 정한다. 판례는 이 포기를 법률행위인 상대방 있는 단독행위로 보아, 부동산 공유지분의 포기에는 법률행위로 인한 물권변동에 관한 민법 제186조가 적용된다고 하였다. 따라서 포기의 의사표시가 도달하여도 다른 공유자는 소유권이전등기청구권을 취득할 뿐이고, 해당 지분에 관하여 자기 앞으로 소유권이전등기를 마쳐야 지분을 취득한다. 이 사건에서 갑은 을의 포기로 그 부분에 관한 등기청구권을 가지게 되었다. 반면 경매로 갑의 종전 지분만 취득한 병은 그 부분에 관하여 아무런 권원이 없었으므로 부당이득반환의무를 진다.

확인 부동산 공유자의 지분 포기의 의사표시가 다른 공유자에게 도달하면, 등기가 없어도 그 지분은 곧바로 다른 공유자에게 귀속한다. **(O · X)**

핵심어 공유지분의 포기·상대방 있는 단독행위·부동산물권변동·등기·소유권이전등기청구권

함께 읽기 특-258 · 특-262 · 특-260 · 1-159 · 특-256 · 특-257 · 1-160 · 2-066 · 특-261 · 1-157 · 2-065 · 3-049 외 2

확인 답 X — 공유지분의 포기는 법률행위이므로 민법 제186조에 따라 등기를 하여야 물권변동의 효력이 생기고, 그 전에는 다른 공유자가 소유권이전등기청구권을 취득할 뿐이다.

제197조(점유의 태양)
①점유자는 소유의 의사로 선의, 평온 및 공연하게 점유한 것으로 추정한다.

타인 토지를 산 매수인의 점유 — 자주점유 추정은 유지된다

대법원 2000. 3. 16. 선고 97다37661 전원합의체 판결 건물철거등

최근 5년 기출 **2025** 법무사 | **2023** 감정평가사 | **2022** 주택관리사보

사실 을은 1965년 1월경 등기부상 소유자가 아닌 병으로부터 농촌지역의 토지를 사서 채소를 기르다가 그 위에 건물을 지어 점유·사용하였고, 1985년 5월경 토지와 건물을 정에게 팔았다. 을은 소유권이전등기를 한 적이 없다. 등기부상 소유자의 상속인으로서 토지의 공유자인 갑이 공유물의 보존행위로 건물의 철거를 구하자, 정은 을의 점유취득시효가 완성되었다고 다투었다. 원심은 을의 점유가 자주점유로 추정된다고 보아 갑의 청구를 배척하였다.

쟁점 **등기부상 소유자가 아닌 사람에게서 땅을 사서 등기 없이 점유해 온 매수인도, 소유의 의사로 점유한 것으로 추정될까?**

판단 토지의 매수인이 매매계약에 의하여 목적 토지의 점유를 취득한 경우 설사 그것이 타인의 토지의 매매에 해당하여 그에 의하여 곧바로 소유권을 취득할 수 없다고 하더라도 그것만으로 매수인이 점유권원의 성질상 소유의 의사가 없는 것으로 보이는 권원에 바탕을 두고 점유를 취득한 사실이 증명되었다고 단정할 수 없을 뿐만 아니라, 매도인에게 처분권한이 없다는 것을 잘 알면서 이를 매수하였다는 등의 다른 특별한 사정이 입증되지 않는 한, 그 사실만으로 바로 그 매수인의 점유가 소유의 의사가 있는 점유라는 추정이 깨어지는 것이라고 할 수 없고, … 점유자에게 추정되는 소유의 의사는 사실상 소유할 의사가 있는 것으로 충분한 것이지 반드시 등기를 수반하여야 하는 것은 아니므로 등기를 수반하지 아니한 점유임이 밝혀졌다고 하여 이 사실만 가지고 바로 점유권원의 성질상 소유의 의사가 결여된 타주점유라고 할 수 없다. — 판결요지 [2] 다수의견

해설 민법 제197조 제1항에 따라 점유자는 소유의 의사로 점유한 것으로 추정되므로, 취득시효를 부정하는 쪽이 타주점유임을 증명하여야 한다. 자주점유인지는 점유자의 내심이 아니라 점유 취득의 원인이 된 권원의 성질 등에 의하여 외형적·객관적으로 정해진다. 추정되는 소유의 의사는 사실상 소유할 의사로 충분하고 등기를 수반할 필요가 없으므로, 매도인이 무권리자여서 곧바로 소유권을 얻지 못하였다거나 등기를 하지 않았다는 사정만으로 추정이 깨지지 않는다. 다만 매도인에게 처분권한이 없음을 잘 알면서 샀거나, 법률요건이 없음을 알면서 남의 부동산을 무단점유한 경우에는 추정이 깨진다. 반대의견은 등기 없는 매수인의 점유를 타주점유로 보았다.

범위 이 사건에서는 현행 민법 시행 뒤 얼마 되지 않은 1965년 무렵의 매수이고 토지가 농촌지역에 있다는 사정도 함께 고려되었다.

확인 등기부상 소유자가 아닌 사람에게서 토지를 매수하여 곧바로 소유권을 취득할 수 없었다면, 그 사정만으로 매수인의 자주점유 추정은 깨진다. **(O · X)**

핵심어 자주점유의 추정·소유의 의사·타인 토지의 매매·점유취득시효·무단점유
함께 읽기 3-051 · 특-272 · 3-052 · 특-273 · 1-170 · 특-271 · 특-269 · 특-270
확인 답 X — 매도인에게 처분권한이 없음을 잘 알면서 매수하였다는 등의 특별한 사정이 입증되지 않는 한, 그것만으로 자주점유의 추정은 깨지지 않는다.

제245조(점유로 인한 부동산소유권의 취득기간)
①20년간 소유의 의사로 평온, 공연하게 부동산을 점유하는 자는 등기함으로써 그 소유권을 취득한다.

2차 점유취득시효 — 도중에 바뀐 명의자에게도 주장 가능

대법원 2009. 7. 16. 선고 2007다15172, 15189 전원합의체 판결 점유토지반환및손해배상·소유권이전등기

최근 5년 기출 **2024** 법원행시 | **2023** 법원직 9급 · 변호사시험

사실 갑은 1961. 1.경 토지를 매수하면서 이웃 대지 일부의 점유를 승계하여 텃밭으로 점유·사용해 왔다. 최초 점유일부터 기산한 갑의 1차 취득시효가 완성된 뒤 그 등기를 하지 않은 사이에, 1982. 2. 15. 병 앞으로 대지의 소유권이전등기가 마쳐졌다. 이어 1988년에 정과 을 앞으로 차례로 소유권이전등기가 되었다. 을이 토지 인도를 구하자 갑은 반소로 시효취득을 원인으로 한 소유권이전등기를 구하였다. 원심은 병의 등기 뒤 소유자가 다시 바뀌었으므로 그 등기 시점을 새 기산점으로 삼을 수 없다고 보았다.

쟁점 **시효완성 뒤 소유자가 바뀐 때부터 새로 진행하는 취득시효 기간 중에 명의자가 또 바뀌면, 점유자는 새 명의자에게 시효취득을 주장할 수 있을까?**

판단 취득시효기간이 경과하기 전에 등기부상의 소유명의자가 변경된다고 하더라도 그 사유만으로는 점유자의 종래의 사실상태의 계속을 파괴한 것이라고 볼 수 없어 취득시효를 중단할 사유가 되지 못하므로, 새로운 소유명의자는 취득시효 완성 당시 권리의무 변동의 당사자로서 취득시효 완성으로 인한 불이익을 받게 된다 할 것이어서 시효완성자는 그 소유명의자에게 시효취득을 주장할 수 있는 바, 이러한 법리는 새로이 2차의 취득시효가 개시되어 그 취득시효기간이 경과하기 전에 등기부상의 소유명의자가 다시 변경된 경우에도 마찬가지로 적용된다고 봄이 상당하다. — 판결요지 [2] 다수의견

해설 판례는 점유취득시효 완성 당시의 소유자에게는 등기 없이도 시효취득을 주장할 수 있지만, 완성 뒤 등기를 넘겨받은 제3자에게는 대항할 수 없다고 본다. 다만 점유를 계속하여 그 제3자 앞으로의 소유권 변동시부터 다시 시효기간이 지나면, 그때를 기산점으로 한 2차 취득시효의 완성을 주장할 수 있다. 종전 판례는 이 2차 시효기간 중에 등기명의자가 바뀌지 않아야 한다고 하였으나, 이 판결은 그 부분을 변경하였다. 소유명의의 변경은 점유 상태의 계속을 깨뜨리지 않아 시효중단사유가 아니고, 이 법리는 2차 취득시효에도 그대로 적용된다는 것이다. 그래서 갑은 병 앞으로의 소유권 변동시를 기산점으로 삼아, 그 기간 중 소유명의를 취득한 을에게 시효취득을 주장할 수 있다. 반대의견은 등기의 형식주의와 거래의 안전을 들어 종전 판례를 유지하여야 한다고 하였다.

확인 1차 시효 완성 뒤 제3자에게 소유권이 넘어가 새로 진행하던 시효기간 중에 등기명의자가 바뀌었다면, 그 기간이 지나도 점유자는 새 명의자에게 시효취득을 주장할 수 없다. **(O · X)**

핵심어 점유취득시효·2차 취득시효·기산점·시효중단·판례변경
함께 읽기 1-180 · 2-071 · 4-032 · 특-290 · 3-055 · 특-287 · 특-288 · 특-289 · 3-054
확인 답 X — 등기부상 소유명의자의 변경은 취득시효의 중단사유가 아니어서, 2차 취득시효 완성 당시의 소유명의자에게 시효취득을 주장할 수 있다.

제275조(물건의 총유)
①법인이 아닌 사단의 사원이 집합체로서 물건을 소유할 때에는 총유로 한다.
②총유에 관하여는 사단의 정관 기타 계약에 의하는 외에 다음 2조의 규정에 의한다.

교회 재산의 처분 — 규약이 없으면 교인총회의 결의로

대법원 2009. 2. 12. 선고 2006다23312 판결 소유권이전등기

최근 5년 기출 **2025** 가맹거래사 · 법무사 | **2023** 법무사

사실 을 교회는 당회의 결의에 따라 2004. 2. 11. 갑과 교회 재산인 부동산의 매매계약을 맺었고, 갑은 이 매매계약을 원인으로 소유권이전등기를 구하였다. 원심은 비법인사단인 을 교회의 정관이나 규약에 교회 재산의 처분에 관한 정함이 없고, 을 교회가 속한 교단 총회의 헌법이 교인총회의 결의를 대신한다고 볼 수 없으며, 교인총회가 당회에 처분권한을 위임하였다는 증거도 부족하다고 보아 갑의 청구를 배척하고 표현대리 주장도 받아들이지 않았다.

쟁점 **규약에 정함이 없는 교회가 교인총회의 결의 없이 당회의 결의만으로 교회 재산을 팔 수 있을까?**

판단 기독교 단체인 교회에 있어서 교인들의 연보, 헌금 기타 교회의 수입으로 이루어진 재산은 특별한 사정이 없는 한 그 교회 소속 교인들의 총유에 속한다. 따라서 그 재산의 처분은 그 교회의 정관 기타 규약에 의하거나 그것이 없는 경우에는 그 교회 소속 교인들로 구성된 총회의 결의에 따라야 한다. — 판결요지 [1]

해설 법인 아닌 사단의 사원이 집합체로서 물건을 소유하면 총유가 된다(민법 제275조 제1항). 총유물의 처분은 사단의 정관 기타 계약에 정함이 없으면 사원총회의 결의에 의한다(민법 제275조 제2항, 제276조 제1항). 판례는 교인들의 연보, 헌금 등으로 이루어진 교회 재산을 특별한 사정이 없는 한 교인들의 총유로 보아 이 규정을 적용하였다. 그래서 갑은 규약에 정함이 없는 을 교회가 당회의 결의만 거쳐 맺은 매매계약으로 소유권이전등기를 청구할 수 없었다. 교회의 대표자도 교인총회의 결의 없이는 교회 재산의 처분을 대표할 권한이 없고, 이러한 처분행위에는 민법 제126조의 표현대리 규정이 준용되지 않는다.

확인 규약에 교회 재산의 처분에 관한 정함이 없는 교회는 당회의 결의만 거치면 교회 재산을 처분할 수 있다. **(O · X)**

핵심어 총유·비법인사단·교회 재산·교인총회의 결의·표현대리
함께 읽기 2-072
확인 답 X — 정관 기타 규약이 없으면 그 교회 소속 교인들로 구성된 총회의 결의에 따라야 한다.

제324조(유치권자의 선관의무)
①유치권자는 선량한 관리자의 주의로 유치물을 점유하여야 한다.
②유치권자는 채무자의 승낙없이 유치물의 사용, 대여 또는 담보제공을 하지 못한다. 그러나 유치물의 보존에 필요한 사용은 그러하지 아니하다.
③유치권자가 전2항의 규정에 위반한 때에는 채무자는 유치권의 소멸을 청구할 수 있다.

유치권자의 거주 — 보존에 필요한 사용이나 이득은 반환

대법원 2009. 9. 24. 선고 2009다40684 판결 점유권확인

최근 5년 기출 **2026** 가맹거래사 | **2024** 공인중개사 · 주택관리사보 | **2022** 법무사

사실 을 등은 공사대금채권에 기하여 건물 2, 3층을 점유하며 사용하여 왔다. 그 건물을 낙찰받은 갑이 인도를 구하자 을 등은 유치권을 들어 거절하였고, 갑은 을 등의 점유가 불법점유라고 다투었다. 원심은 을 등의 유치권을 인정하여 인도청구를 배척하면서, 을 등이 건물을 사용하여 얻은 이익은 공사대금채권에서 공제되어야 한다고 보았다.

쟁점 **유치권자가 유치물인 주택에 스스로 살며 쓰는 것은 허용되는 사용일까, 그렇다면 그 사용 이익은 돌려주어야 할까?**

판단 민법 제324조에 의하면, 유치권자는 선량한 관리자의 주의로 유치물을 점유하여야 하고, 소유자의 승낙 없이 유치물을 보존에 필요한 범위를 넘어 사용하거나 대여 또는 담보제공을 할 수 없으며, 소유자는 유치권자가 위 의무를 위반한 때에는 유치권의 소멸을 청구할 수 있다고 할 것인바, 공사대금채권에 기하여 유치권을 행사하는 자가 스스로 유치물인 주택에 거주하며 사용하는 것은 특별한 사정이 없는 한 유치물인 주택의 보존에 도움이 되는 행위로서 유치물의 보존에 필요한 사용에 해당한다고 할 것이다. 그리고 유치권자가 유치물의 보존에 필요한 사용을 한 경우에도 특별한 사정이 없는 한 차임에 상당한 이득을 소유자에게 반환할 의무가 있다. — 판결요지

해설 민법 제324조에 따라 유치권자는 선량한 관리자의 주의로 유치물을 점유하여야 하고, 승낙 없이 유치물을 사용·대여하거나 담보로 제공하지 못하며, 이를 어기면 유치권 소멸청구를 받을 수 있다. 다만 유치물의 보존에 필요한 사용은 승낙 없이도 할 수 있다. 판례는 공사대금채권의 유치권자가 유치물인 주택에 스스로 거주하는 것을 특별한 사정이 없는 한 주택의 보존에 도움이 되는 행위로서 보존에 필요한 사용으로 보았다. 그러나 사용이 허용된다고 그 이익까지 가질 수는 없어서, 유치권자는 차임에 상당한 이득을 소유자에게 반환하여야 한다. 원심이 사용 이익을 공사대금채권에서 공제한 것도 이 반환의무를 전제로 한 것이다. 유치물의 소유자가 채무자 아닌 제3자라고 하여 유치권자의 과실수취권이 부정되지도 않는다.

확인 유치권자가 유치물인 주택에 스스로 거주하는 것이 보존에 필요한 사용에 해당하더라도, 유치권자는 특별한 사정이 없는 한 차임 상당 이득을 소유자에게 반환하여야 한다. **(O · X)**

핵심어 유치권·선량한 관리자의 주의·보존에 필요한 사용·유치권 소멸청구·차임 상당 이득
함께 읽기 특-318 · 2-079
확인 답 O — 유치권자가 유치물의 보존에 필요한 사용을 한 경우에도 특별한 사정이 없는 한 차임에 상당한 이득을 소유자에게 반환할 의무가 있다.

제366조(법정지상권) 저당물의 경매로 인하여 토지와 그 지상건물이 다른 소유자에 속한 경우에는 토지소유자는 건물소유자에 대하여 지상권을 설정한 것으로 본다. 그러나 지료는 당사자의 청구에 의하여 법원이 이를 정한다.

공동저당과 재축 건물 — 법정지상권은 성립하지 않는다

대법원 2003. 12. 18. 선고 98다43601 전원합의체 판결 건물철거등

최근 5년 기출 **2025** 법무사 | **2024** 법원행시

사실 갑은 자기 소유의 대지와 그 지상 단층주택에 공동으로 근저당권을 설정해 주었다. 그 뒤 갑은 을에게 도급을 주어 단층주택을 헐고 3층 주택을 새로 지었으나, 신축건물에는 토지와 같은 순위의 공동저당권이 설정되지 않았다. 근저당권 실행을 위한 경매에서 대지만 매각되었고, 이후 대지 소유권을 순차로 넘겨받은 병이 신축건물의 철거와 대지 인도를 구하였다. 원심은 신축건물을 위한 법정지상권이 성립한다고 보아 이를 배척하였다.

쟁점 **토지와 건물에 함께 저당권을 설정한 뒤 건물을 헐고 새로 지었다면, 경매로 소유자가 갈릴 때 새 건물을 위한 법정지상권이 생길까?**

판단 동일인의 소유에 속하는 토지 및 그 지상건물에 관하여 공동저당권이 설정된 후 그 지상건물이 철거되고 새로 건물이 신축된 경우에는, 그 신축건물의 소유자가 토지의 소유자와 동일하고, 토지의 저당권자에게 신축건물에 관하여 토지의 저당권과 동일한 순위의 공동저당권을 설정해 주는 등 특별한 사정이 없는 한, 저당물의 경매로 인하여 토지와 그 신축건물이 다른 소유자에 속하게 되더라도 그 신축건물을 위한 법정지상권은 성립하지 않는다고 해석함이 상당하다. … 건물이 철거된 후 신축된 건물에 토지와 동순위의 공동저당권이 설정되지 아니 하였는데도 그 신축건물을 위한 법정지상권이 성립한다고 해석하게 되면, 공동저당권자가 법정지상권이 성립하는 신축건물의 교환가치를 취득할 수 없게 되는 결과 … 당초 나대지로서의 토지의 교환가치 전체를 기대하여 담보를 취득한 공동저당권자에게 불측의 손해를 입게 하기 때문이다. — 이유 2. 가. (1)

해설 민법 제366조의 법정지상권은 저당권 설정 당시 토지 위에 건물이 있고 토지와 건물이 같은 사람의 소유였다가, 경매로 소유자가 달라질 때 성립한다. 토지에만 저당권이 설정된 경우에는 건물이 헐리고 새로 지어져도 구건물을 기준으로 한 범위에서 법정지상권이 인정되어 왔다. 그러나 토지와 건물에 공동저당권이 설정되면 저당권자는 토지와 건물 각각의 교환가치 전부를 담보로 취득하여, 결국 나대지로서 토지의 교환가치 전체를 실현하리라 기대한다. 그래서 신축건물에 같은 순위의 공동저당권을 설정해 주는 등 특별한 사정이 없으면 신축건물을 위한 법정지상권은 성립하지 않는다. 이 판결로 반대 취지의 종전 판례가 변경되었고, 반대의견이 있다.

확인 토지와 지상 건물에 공동저당권이 설정된 뒤 건물이 헐리고 새로 지어졌다면, 경매로 토지와 새 건물의 소유자가 달라질 때 원칙적으로 새 건물을 위한 법정지상권이 성립한다. **(O · X)**

핵심어 법정지상권·공동저당·건물의 재축·나대지의 교환가치·판례 변경

함께 읽기 특-337 · 1-205 · 특-335 · 특-334 · 3-064 · 2-083 · 2-082 · 특-336

확인 답 X — 신축건물에 토지와 같은 순위의 공동저당권이 설정되는 등 특별한 사정이 없는 한 신축건물을 위한 법정지상권은 성립하지 않는다.

제398조(배상액의 예정)
①당사자는 채무불이행에 관한 손해배상액을 예정할 수 있다.
②손해배상의 예정액이 부당히 과다한 경우에는 법원은 적당히 감액할 수 있다.
③손해배상액의 예정은 이행의 청구나 계약의 해제에 영향을 미치지 아니한다.
④위약금의 약정은 손해배상액의 예정으로 추정한다.
⑤당사자가 금전이 아닌 것으로써 손해의 배상에 충당할 것을 예정한 경우에도 전4항의 규정을 준용한다.

손해배상액의 예정 — 귀책사유 없음을 증명하면 면책된다

대법원 2007. 12. 27. 선고 2006다9408 판결 매매대금

최근 5년 기출 **2024** 노무사 · 법원직 9급

사실 갑은 누적 적자를 내던 A회사의 대주주이자 핵심 기술인력인 을로부터 주식을 액면가의 2.5배로 사면서, 을이 3년간 A회사에 근무하고 이를 어기면 주식 매매대금 반환 등 손해배상을 청구할 수 있다고 약정하였다. 그 뒤 A회사의 회장이 된 갑이 영업 중심의 경영방침을 밝히자, 이에 동의한 을은 연구개발 임직원들의 거듭된 퇴사 요구 끝에 퇴사하였다. 갑이 예정배상액을 청구하자 원심은 을의 귀책사유를 묻지 않고 청구할 수 있다고 보았다.

쟁점 **손해배상액을 미리 정해 둔 경우에도, 채무자는 자기에게 잘못이 없음을 증명하여 그 지급을 면할 수 있을까?**

판단 채무불이행으로 인한 손해배상액이 예정되어 있는 경우에는 채권자는 채무불이행 사실만 증명하면 손해의 발생 및 그 액을 증명하지 아니하고 예정배상액을 청구할 수 있고, 채무자는 채권자와 채무불이행에 있어 채무자의 귀책사유를 묻지 아니한다는 약정을 하지 아니한 이상 자신의 귀책사유가 없음을 주장·입증함으로써 예정배상액의 지급책임을 면할 수 있다. 그리고 채무자의 귀책사유를 묻지 아니한다는 약정의 존재 여부는 근본적으로 당사자 사이의 의사해석의 문제로서, … 당사자의 통상의 의사는 채무자의 귀책사유로 인한 채무불이행에 대해서만 손해배상액을 예정한 것으로 봄이 상당하므로, 채무자의 귀책사유를 묻지 않기로 하는 약정의 존재는 엄격하게 제한하여 인정하여야 한다. — 판결요지 [1]

해설 민법 제398조에 따라 당사자는 채무불이행에 관한 손해배상액을 예정할 수 있다. 예정이 있으면 채권자는 채무불이행 사실만 증명하면 손해의 발생과 그 액수를 증명하지 않고 예정배상액을 청구할 수 있다. 그러나 채무자는 귀책사유를 묻지 않기로 하는 약정이 없는 한 자기에게 귀책사유가 없음을 증명하여 지급책임을 면할 수 있다. 당사자의 통상의 의사는 귀책사유 있는 불이행에 대해서만 배상액을 예정한 것이므로, 귀책사유를 묻지 않는다는 약정은 엄격하게 제한하여 인정한다. 귀책사유가 인정되더라도 예정액이 부당히 과다하면 법원은 적당히 감액할 수 있다.

확인 손해배상액의 예정이 있으면 채무자는 자신에게 귀책사유가 없음을 증명하더라도 예정배상액의 지급책임을 면할 수 없다. **(O · X)**

핵심어 손해배상액의 예정·귀책사유·증명책임·의사해석·예정액의 감액
함께 읽기 1-223 · 2-087 · 특-356 · 특-359 · 특-357 · 특-358 · 3-069
확인 답 X — 귀책사유를 묻지 아니한다는 약정을 하지 아니한 이상 채무자는 귀책사유가 없음을 주장·입증하여 지급책임을 면할 수 있다.

제406조(채권자취소권)
①채무자가 채권자를 해함을 알고 재산권을 목적으로 한 법률행위를 한 때에는 채권자는 그 취소 및 원상회복을 법원에 청구할 수 있다. 그러나 그 행위로 인하여 이익을 받은 자나 전득한 자가 그 행위 또는 전득당시에 채권자를 해함을 알지 못한 경우에는 그러하지 아니하다.
②전항의 소는 채권자가 취소원인을 안 날로부터 1년, 법률행위있은 날로부터 5년내에 제기하여야 한다.

구체화 전 재산분할청구권의 포기 — 채권자취소 대상 아님

대법원 2013. 10. 11. 선고 2013다7936 판결 재산분할 청구등

최근 5년 기출 **2025** 국가직 7급 · 법원직 9급 | **2022** 변호사시험

사실 갑 등은 병에 대하여 채권을 가진 채권자이다. 병은 을과 이혼한 뒤, 아직 협의나 심판을 거치지 않은 상태에서 을에 대한 재산분할청구권을 포기하였다. 갑 등은 이 포기가 사해행위라며 그 취소를 구하였으나, 원심은 사해행위 취소의 대상이 되지 않는다고 판단하였다.

쟁점 **이혼 뒤 협의나 심판으로 아직 구체화되지 않은 재산분할청구권을 포기한 것을, 채권자가 사해행위로 취소할 수 있을까?**

판단 이혼으로 인한 재산분할청구권은 이혼을 한 당사자의 일방이 다른 일방에 대하여 재산분할을 청구할 수 있는 권리로서 이혼이 성립한 때에 그 법적 효과로서 비로소 발생하는 것일 뿐만 아니라, 협의 또는 심판에 의하여 구체적 내용이 형성되기까지는 그 범위 및 내용이 불명확·불확정하기 때문에 구체적으로 권리가 발생하였다고 할 수 없으므로 협의 또는 심판에 의하여 구체화되지 않은 재산분할청구권은 채무자의 책임재산에 해당하지 아니하고, 이를 포기하는 행위 또한 채권자취소권의 대상이 될 수 없다. — 판결요지

해설 채권자취소권은 채무자가 채권자를 해함을 알고 한 재산권을 목적으로 한 법률행위의 취소를 구하는 권리이다(민법 제406조 제1항). 이 판결은 재산분할청구권이 채무자의 책임재산에 해당하는지를 기준으로 삼았다. 재산분할청구권은 이혼이 성립한 때에 비로소 발생하고, 분할의 액수와 방법은 협의로 정하되 협의가 되지 않으면 가정법원이 정한다(민법 제839조의2 제2항). 이렇게 협의 또는 심판으로 구체적 내용이 형성되기까지는 그 범위와 내용이 불명확·불확정하다. 그래서 구체화되지 않은 재산분할청구권은 책임재산이 아니고, 그 포기도 채권자취소권의 대상이 될 수 없다. 병의 포기는 협의나 심판을 거치기 전의 것이었으므로 취소의 대상이 되지 않았다.

범위 협의나 심판으로 구체적 내용이 정해진 뒤의 재산분할청구권을 포기한 경우를 다룬 판결은 아니다.

확인 이혼한 채무자가 협의나 심판을 거치기 전에 재산분할청구권을 포기하면, 채권자는 이를 사해행위로 취소할 수 있다. **(O · X)**

핵심어 채권자취소권·사해행위·재산분할청구권·책임재산·포기
함께 읽기 특-372 · 1-228 · 특-370 · 특-369 · 3-073 · 2-090 · 특-367 · 특-379 · 특-378 · 4-048 · 특-374 · 3-075 외 13
확인 답 X — 협의 또는 심판으로 구체화되지 않은 재산분할청구권은 책임재산에 해당하지 않아, 그 포기는 채권자취소권의 대상이 될 수 없다.

제428조(보증채무의 내용)
①보증인은 주채무자가 이행하지 아니하는 채무를 이행할 의무가 있다.
②보증은 장래의 채무에 대하여도 할 수 있다.

주채무의 시효소멸과 보증인 — 보증채무도 소멸한다

대법원 2012. 7. 12. 선고 2010다51192 판결 채무부존재확인

최근 5년 기출 **2026** 법무사 | **2025** 법원직 9급 | **2024** 노무사 · 법무사 · 법원 승진시험 · 법원행시 | **2023** 법무사

사실 갑은 A회사가 B회사에 대하여 부담하는 대출금채무를 연대보증하였다. B회사는 갑의 연대보증채무를 피보전권리로 갑 소유 부동산을 가압류하였으나, A회사의 주채무는 상사소멸시효 5년이 지나 소멸하였다. 그 뒤 B회사가 갑의 부동산에 강제경매를 신청하여 배당금을 받았고, 갑은 이의하지 않았다. 원심은 갑이 보증채무의 시효이익을 포기하였다고 보아 갑의 보증채무 부존재확인 청구를 배척하였다.

쟁점 **주채무가 시효로 소멸한 뒤 보증인이 보증채무를 이행하거나 승인했다면, 보증인은 이제 주채무의 시효소멸을 주장할 수 없을까?**

판단 보증채무에 대한 소멸시효가 중단되는 등의 사유로 완성되지 아니하였다고 하더라도 주채무에 대한 소멸시효가 완성된 경우에는 시효완성 사실로써 주채무가 당연히 소멸되므로 보증채무의 부종성에 따라 보증채무 역시 당연히 소멸된다. 그리고 주채무에 대한 소멸시효가 완성되어 보증채무가 소멸된 상태에서 보증인이 보증채무를 이행하거나 승인하였다고 하더라도, 주채무자가 아닌 보증인의 행위에 의하여 주채무에 대한 소멸시효 이익의 포기 효과가 발생된다고 할 수 없으며, 주채무의 시효소멸에도 불구하고 보증채무를 이행하겠다는 의사를 표시한 경우 등과 같이 부종성을 부정하여야 할 다른 특별한 사정이 없는 한 보증인은 여전히 주채무의 시효소멸을 이유로 보증채무의 소멸을 주장할 수 있다고 보아야 한다. — 판결요지 [1]

해설 보증인은 주채무자가 이행하지 아니하는 채무를 이행할 의무를 지므로(민법 제428조 제1항), 보증채무는 주채무에 부종한다. 그래서 보증채무 자체의 시효가 가압류 등으로 중단되었더라도 주채무가 시효로 소멸하면 보증채무도 당연히 소멸한다. 그 뒤 보증인이 보증채무를 이행하거나 승인하여도, 주채무자가 아닌 보증인의 행위로 주채무의 시효이익이 포기되지는 않는다. 주채무의 시효소멸에도 불구하고 보증채무를 이행하겠다는 의사를 표시하는 등 부종성을 부정할 특별한 사정이 없으면, 보증인은 여전히 보증채무의 소멸을 주장할 수 있다. 경매절차에서 이의 없이 배당된 사정만으로는 그러한 의사표시로 보기에 부족하다.

확인 주채무의 소멸시효가 완성된 뒤 보증인이 보증채무를 승인하였다면, 그로써 주채무에 대한 소멸시효 이익도 포기된 것으로 된다. **(O · X)**

핵심어 보증채무의 부종성·주채무의 소멸시효·시효이익의 포기·연대보증
함께 읽기 1-154 · 1-243 · 특-385 · 특-386 · 특-384 · 3-076
확인 답 X — 주채무자가 아닌 보증인의 행위에 의하여 주채무에 대한 소멸시효 이익의 포기 효과가 발생한다고 할 수 없다.

제430조(목적, 형태상의 부종성) 보증인의 부담이 주채무의 목적이나 형태보다 중한 때에는 주채무의 한도로 감축한다.

보증채권만의 양도 — 주채권과 분리하면 효력이 없다

대법원 2002. 9. 10. 선고 2002다21509 판결 청구이의및채무부존재확인

최근 5년 기출 **2026** 노무사 · 변리사 | **2025** 공인중개사 · 법무사 · 법원직 9급 | **2022** 법무사 · 법원직 9급

사실 갑은 을에 대하여 사료대금채권을 가지고 있었고, 병은 을의 연대보증인이었다. 갑이 병에 대한 보증채권을 A회사에 양도한다는 채권양도계약서가 작성되었으나, 을에 대한 주채권까지 A회사에 양도되고 대항요건이 갖추어졌다는 자료는 없었다. 병은 갑을 상대로 청구이의와 채무부존재확인을 구하면서 채권자는 갑이 아니라 A회사라고 다투었다. 원심은 병에게 양도 통지가 없었다는 등의 이유로 보증채권 양도의 효력을 부정하였다.

쟁점 **주채권은 그대로 둔 채 보증채권만 떼어 다른 사람에게 양도할 수 있을까?**

판단 보증채무는 주채무에 대한 부종성 또는 수반성이 있어서 주채무자에 대한 채권이 이전되면 당사자 사이에 별도의 특약이 없는 한 보증인에 대한 채권도 함께 이전하고, 이 경우 채권양도의 대항요건도 주채권의 이전에 관하여 구비하면 족하고, 별도로 보증채권에 관하여 대항요건을 갖출 필요는 없다. … 주채권과 보증인에 대한 채권의 귀속주체를 달리하는 것은, 주채무자의 항변권으로 채권자에게 대항할 수 있는 보증인의 권리가 침해되는 등 보증채무의 부종성에 반하고, 주채권을 가지지 않는 자에게 보증채권만을 인정할 실익도 없기 때문에 주채권과 분리하여 보증채권만을 양도하기로 하는 약정은 그 효력이 없다. — 판결요지 [1], [2]

해설 보증채무는 주채무에 대하여 부종성을 가지므로 그 부담이 주채무보다 무거울 수 없고(민법 제430조), 주채권이 이전하면 함께 이전하는 수반성도 가진다. 그래서 주채권이 양도되면 특약이 없는 한 보증채권도 함께 이전하고, 대항요건도 주채권의 이전에 관하여만 갖추면 된다. 반대로 주채권과 분리하여 보증채권만 양도하기로 하는 약정은 효력이 없다. 이 사건에서 원심이 보증인에 대한 통지가 없음을 문제 삼은 것은 잘못이지만, 보증채권만 양도하였으므로 양도가 효력이 없다는 결론은 유지되었다. 이 판결은 또 주채무자의 기망으로 체결된 연대보증계약의 일부취소를 인정하였다. 보증책임이 가분적인 금전채무이고 보증인에게 일정 금액을 한도로 한 보증의사가 있었으므로, 취소는 그 금액을 넘는 범위에서만 효력이 생긴다고 보았다.

확인 채권자는 주채무자에 대한 채권은 그대로 가진 채 보증인에 대한 채권만을 떼어 제3자에게 유효하게 양도할 수 있다. **(O · X)**

핵심어 보증채무의 부종성·수반성·보증채권의 양도·채권양도의 대항요건·일부취소

함께 읽기 3-077

확인 답 X — 주채권과 분리하여 보증채권만을 양도하기로 하는 약정은 보증채무의 부종성에 반하여 효력이 없다.

제477조(법정변제충당) 당사자가 변제에 충당할 채무를 지정하지 아니한 때에는 다음 각호의 규정에 의한다.
1. 채무중에 이행기가 도래한 것과 도래하지 아니한 것이 있으면 이행기가 도래한 채무의 변제에 충당한다.
2. 채무전부의 이행기가 도래하였거나 도래하지 아니한 때에는 채무자에게 변제이익이 많은 채무의 변제에 충당한다.
3. 채무자에게 변제이익이 같으면 이행기가 먼저 도래한 채무나 먼저 도래할 채무의 변제에 충당한다.
4. 전2호의 사항이 같은 때에는 그 채무액에 비례하여 각 채무의 변제에 충당한다.

법정변제충당과 물상보증 — 변제이익에 차이가 없다

대법원 2014. 4. 30. 선고 2013다8250 판결 대여금

최근 5년 기출 **2025** 국가직 7급 · 법무사 | **2024** 노무사 | **2022** 법원직 9급

사실 갑은 을에게 다섯 차례에 걸쳐 합계 7억 원을 빌려주었고, 병은 그중 이행기가 가장 먼저 도래하는 1억 원의 차용금 채무를 연대보증하였다. 다섯 채무 가운데 두 건에는 물상보증인이 제공한 물적 담보가 있었다. 모든 채무의 이행기가 도래한 뒤 을이 일부 변제로 3억 원을 지급하였고, 이 돈은 법정변제충당의 방법으로 충당되어야 했다. 원심은 물적 담보가 있는 두 채무가 채무자에게 변제이익이 많다고 보아 3억 원을 그 채무들에 먼저 충당하고, 병의 연대보증채무가 일부 남아 있다고 판단하였다.

쟁점 **물상보증인이 담보를 제공한 채무는 담보가 없는 채무보다 채무자에게 변제이익이 더 많을까?**

판단 변제자가 주채무자인 경우 보증인이 있는 채무와 보증인이 없는 채무 사이에 전자가 후자에 비하여 변제이익이 더 많다고 볼 근거는 전혀 없으므로 양자는 변제이익의 점에서 차이가 없다고 보아야 한다. 마찬가지로 변제자가 채무자인 경우 물상보증인이 제공한 물적 담보가 있는 채무와 그러한 담보가 없는 채무 사이에도 변제이익의 점에서 차이가 없다. — 판결요지

해설 당사자가 변제에 충당할 채무를 지정하지 않으면 민법 제477조의 순서에 따라 충당한다. 채무 전부의 이행기가 도래하였으면 채무자에게 변제이익이 많은 채무에 먼저 충당하고(제2호), 변제이익이 같으면 이행기가 먼저 도래한 채무에 충당한다(제3호). 판례는 변제자가 주채무자이면 보증인이 있는 채무와 없는 채무 사이에 변제이익의 차이가 없다고 보아 왔다. 이 판결은 물상보증인이 제공한 물적 담보가 있는 채무도 마찬가지라고 하였다. 그러므로 3억 원은 제3호에 따라 이행기가 가장 먼저 도래한, 병이 연대보증한 채무에 먼저 충당되고, 그 채무가 소멸하면 병의 연대보증채무도 소멸한다. 원심판결 중 병의 패소 부분은 제2호를 적용한 잘못으로 파기되었다.

범위 이 판결은 물상보증인이 제공한 담보에 관한 것이고, 채무자 자신의 재산에 담보가 설정된 채무까지 다룬 것은 아니다.

확인 채무자가 변제하는 경우, 물상보증인이 제공한 물적 담보가 있는 채무는 그러한 담보가 없는 채무보다 변제이익이 더 많다. **(O · X)**

핵심어 법정변제충당·변제이익·물상보증인·물적 담보·연대보증
함께 읽기 2-097 · 2-098 · 특-405 · 특-404
확인 답 X — 변제자가 채무자인 경우 물상보증인이 제공한 물적 담보가 있는 채무와 그러한 담보가 없는 채무 사이에는 변제이익의 차이가 없다.

제536조(동시이행의 항변권)
①쌍무계약의 당사자 일방은 상대방이 그 채무이행을 제공할 때 까지 자기의 채무이행을 거절할 수 있다. 그러나 상대방의 채무가 변제기에 있지 아니하는 때에는 그러하지 아니하다.
②당사자 일방이 상대방에게 먼저 이행하여야 할 경우에 상대방의 이행이 곤란할 현저한 사유가 있는 때에는 전항 본문과 같다.

중도금 지체 중 잔금기일 도래 — 등기의무와 동시이행

대법원 1992. 4. 14. 선고 91다43107 판결 소유권이전등기

최근 5년 기출 **2026** 주택관리사보 · 행정사 | **2024** 세무사 · 주택관리사보 | **2023** 법무사 · 변호사시험 · 세무사 | **2022** 법무사 · 행정사

사실 갑은 병에게 자기 부동산의 매각을 맡겼고, 병은 갑을 대리하여 을과 매매계약을 체결하였다. 을이 중도금과 잔금을 약정한 날에 치르지 않자, 갑은 기한을 정하여 지급을 최고한 뒤 계약의 해제를 통지하였다. 그러나 갑은 그동안 소유권이전등기 소요서류 등을 준비하여 을에게 수령을 촉구한 적이 전혀 없었다. 을이 소유권이전등기를 구한 이 사건에서 원심은 갑의 해제가 효력이 없다고 판단하였다.

쟁점 **매수인이 중도금을 치르지 않은 채 잔금지급기일도 지났다면, 매도인은 등기서류를 제공하지 않고도 계약을 해제할 수 있을까?**

판단 매수인이 약정대로 중도금을 지급하지 않음으로써, 매도인이 소유권이전등기의무의 이행을 제공하지 않은 것과 관계없이 매수인이 이행지체에 빠졌다고 하더라도, 매도인이 매수인의 중도금지급의무의 불이행을 이유로 매매계약을 해제하지 않고 있는 상태에서 잔금지급기일이 도래하였는데도 매수인이 약정대로 잔금을 지급하지 않았다면, 매수인의 중도금을 포함한 매매잔대금의 지급의무와 매도인의 소유권이전등기의무는, 특별한 다른 사정이 없는 한 동시이행의 관계에 있는 것이라고 봄이 상당하므로 매도인으로서는 소유권이전등기의무의 이행을 제공하지 아니한 채 매수인의 매매잔대금지급의무의 불이행을 이유로 매매계약을 해제할 수 없다. — 판결요지 가.

해설 쌍무계약의 당사자는 상대방이 이행을 제공할 때까지 자기 채무의 이행을 거절할 수 있지만, 상대방의 채무가 변제기 전이면 그렇지 않다(민법 제536조 제1항). 그래서 먼저 치르기로 한 중도금을 약정대로 치르지 않은 매수인은 매도인이 등기의무의 이행을 제공하지 않았더라도 이행지체에 빠진다. 그러나 매도인이 해제하지 않은 사이에 잔금지급기일이 도래하였는데도 매수인이 잔금을 치르지 않았다면 사정이 달라진다. 이때에는 중도금을 포함한 매매잔대금 지급의무와 소유권이전등기의무가 특별한 사정이 없는 한 동시이행관계에 있으므로, 매도인은 등기의무의 이행을 제공하여야 해제할 수 있다. 이 판결은 또 매매계약 체결의 대리인은 원칙적으로 중도금·잔금을 수령할 수 있고, 계약의 체결과 이행에 관한 포괄적 대리인은 대금 지급기일을 연기해 줄 권한도 가진다고 하였다.

확인 매수인이 중도금 지급을 지체하였고 매도인이 해제하지 않은 사이에 잔금지급기일도 지났다면, 매도인은 소유권이전등기의무의 이행을 제공하지 않고도 계약을 해제할 수 있다. **(O · X)**

핵심어 동시이행의 항변권·중도금·매매잔대금·이행제공·계약의 해제
함께 읽기 특-419 · 특-420 · 특-422 · 특-423 · 1-271 · 2-104 · 1-272 · 특-421 · 2-105 · 3-083 · 특-418 · 3-084
확인 답 X — 이때 중도금을 포함한 매매잔대금 지급의무와 소유권이전등기의무는 동시이행관계에 있으므로, 매도인은 이행을 제공하지 않은 채 해제할 수 없다.

제539조(제삼자를 위한 계약)
①계약에 의하여 당사자 일방이 제삼자에게 이행할 것을 약정한 때에는 그 제삼자는 채무자에게 직접 그 이행을 청구할 수 있다.
②전항의 경우에 제삼자의 권리는 그 제삼자가 채무자에 대하여 계약의 이익을 받을 의사를 표시한 때에 생긴다.

중첩적 채무인수 — 수익의 의사표시는 효력요건이 아니다

대법원 2013. 9. 13. 선고 2011다56033 판결 물품대금등

최근 5년 기출 **2026** 가맹거래사 · 법무사 | **2025** 노무사 | **2024** 법원 승진시험 · 법원행시 | **2022** 변호사시험

사실 임대인 을은 임차인 병과 임대차를 끝내면서 2009. 7. 6. 합의서를 작성하고, 병에게 돌려줄 금원의 범위에서 병의 채무를 인수하기로 하였다. 병에게 물품대금채권을 가진 갑 등은 을로부터 중첩적 인수라는 취지를 듣지 못해, 인수를 승낙하면 병에 대한 채권을 잃는 것으로 알고 동의하지 않았다. 그 뒤 갑 등은 제1심 제1차 변론기일에 을에게 수익의 의사표시를 하였다. 을은 갑 등이 처음에 채무인수를 거절한 이상 채무인수의 효력이 생기지 않는다고 다투었다.

쟁점 **채무자와 인수인이 합의한 중첩적 채무인수는 채권자가 수익의 의사표시를 하여야 비로소 효력이 생길까?**

판단 채무자와 인수인의 합의에 의한 중첩적 채무인수는 일종의 제3자를 위한 계약이라고 할 것이므로, 채권자는 인수인에 대하여 채무이행을 청구하거나 기타 채권자로서의 권리를 행사하는 방법으로 수익의 의사표시를 함으로써 인수인에 대하여 직접 청구할 권리를 갖게 된다. 이러한 점에서 채무자에 대한 채권을 상실시키는 효과가 있는 면책적 채무인수의 경우 채권자의 승낙을 계약의 효력발생요건으로 보아야 하는 것과는 달리, 채무자와 인수인의 합의에 의한 중첩적 채무인수의 경우 채권자의 수익의 의사표시는 그 계약의 성립요건이나 효력발생요건이 아니라 채권자가 인수인에 대하여 채권을 취득하기 위한 요건이다. — 판결요지 [1]

해설 채무자와 인수인의 합의에 의한 중첩적 채무인수는 일종의 제3자를 위한 계약이다. 그래서 채권자는 민법 제539조의 제삼자처럼 수익의 의사표시를 하여 인수인에게 직접 청구할 권리를 얻는다. 채무자에 대한 채권을 잃게 하는 면책적 채무인수는 채권자의 승낙이 효력발생요건이지만, 중첩적 채무인수에서 수익의 의사표시는 채권 취득의 요건일 뿐이다. 면책적 인수인지 중첩적 인수인지 분명하지 않으면 중첩적 인수로 본다. 수익 거절 뒤에는 특별한 사정이 없는 한 번복할 수 없지만, 인수인이 중첩적 인수라는 취지를 알리지 않은 채 승낙 여부만 최고하여 채권자가 면책적 인수로 잘못 알고 승낙하지 않은 것은 수익 거절이 아니다. 이 사건에서 갑 등은 계약이 존속하는 동안 한 수익의 의사표시로 인수 범위 안에서 을에 대한 채권을 취득하였다.

확인 채무자와 인수인의 합의에 의한 중첩적 채무인수에서 채권자의 수익의 의사표시는 그 계약의 효력발생요건이다. **(O · X)**

핵심어 중첩적 채무인수·면책적 채무인수·제3자를 위한 계약·수익의 의사표시·채권자의 승낙
함께 읽기 1-251 · 1-253 · 3-085 · 2-107 · 특-424 · 4-057
확인 답 X — 수익의 의사표시는 계약의 성립요건이나 효력발생요건이 아니라 채권자가 인수인에 대하여 채권을 취득하기 위한 요건이다.

제548조(해제의 효과, 원상회복의무)
①당사자 일방이 계약을 해제한 때에는 각 당사자는 그 상대방에 대하여 원상회복의 의무가 있다. 그러나 제삼자의 권리를 해하지 못한다.

해제에 따른 원상회복 — 과실상계로 줄일 수 없다

대법원 2014. 3. 13. 선고 2013다34143 판결 매매대금반환

최근 5년 기출 **2026** 법원직 9급 | **2025** 국가직 7급 | **2024** 법무사 | **2023** 법원직 9급 | **2022** 법무사

사실 갑은 을로부터 택지 분양권을 1억 4,500만 원에 매수하였다. 그 뒤 을이 병에게 수분양자 명의변경을 마쳐 주어 갑 앞으로의 명의변경이 불가능해지자, 갑은 계약을 해제하고 매매대금의 반환을 구하였다. 원심은 갑이 분양권 서류를 스스로 관리하지 않고 정에게 맡겨 두어 을이 정에게 전매 권한이 있다고 믿게 된 점 등을 들어, 신의칙과 공평의 원칙에 따라 을의 반환책임을 매매대금의 40%로 제한하였다.

쟁점 **매매계약을 해제한 매수인에게도 해제에 이른 잘못이 있다면, 돌려받을 매매대금을 과실상계처럼 줄일 수 있을까?**

판단 계약 해제의 효과로서 원상회복의무를 규정하는 민법 제548조 제1항 본문은 부당이득에 관한 특별규정의 성격을 가지는 것으로서, 그 이익 반환의 범위는 이익의 현존 여부나 청구인의 선의·악의를 불문하고 특단의 사유가 없는 한 받은 이익의 전부이다. … 과실상계는 본래 채무불이행 또는 불법행위로 인한 손해배상책임에 대하여 인정되는 것이고, … 원상회복의무의 이행으로서 이미 지급한 매매대금 기타의 급부의 반환을 구하는 경우에는 적용되지 아니한다. … 계약의 해제로 인한 원상회복청구권에 대하여 해제자가 해제의 원인이 된 채무불이행에 관하여 '원인'의 일부를 제공하였다는 등의 사유를 내세워 신의칙 또는 공평의 원칙에 기하여 일반적으로 손해배상에 있어서의 과실상계에 준하여 권리의 내용이 제한될 수 있다고 하는 것은 허용되어서는 아니 된다. – 판결요지 [1]·[2]·[3]

해설 민법 제548조 제1항 본문에 따라 계약이 해제되면 각 당사자는 원상회복의무를 지고, 이미 이행된 급부는 부당이득으로 반환된다. 이 규정은 부당이득에 관한 특별규정이어서, 반환 범위는 이익의 현존 여부나 선의·악의를 묻지 않고 받은 이익의 전부이다. 과실상계는 채무불이행이나 불법행위로 인한 손해배상책임에 인정되는 것이므로, 계약이 없었던 재산상태로 되돌리는 원상회복에는 적용되지 않는다. 해제자가 채무불이행의 원인 일부를 제공하였다는 이유로 신의칙이나 공평의 원칙을 내세워 과실상계에 준하여 감액하는 것도 허용되지 않는다. 그러므로 매도인은 특단의 사유가 없는 한 받은 매매대금 전액을 반환하여야 한다.

확인 매매계약을 해제한 매수인에게도 해제에 이른 책임이 일부 있다면, 법원은 공평의 원칙에 따라 매도인이 반환할 매매대금을 감액할 수 있다. **(O · X)**

핵심어 해제의 효과·원상회복의무·부당이득·과실상계·신의칙
함께 읽기 특-433 · 특-432 · 4-058 · 2-112 · 3-086 · 2-111 · 특-431 · 2-113
확인 답 X — 원상회복청구권을 신의칙이나 공평의 원칙에 기하여 과실상계에 준하여 제한하는 것은 허용되지 않는다.

제565조(해약금)
①매매의 당사자 일방이 계약당시에 금전 기타 물건을 계약금, 보증금등의 명목으로 상대방에게 교부한 때에는 당사자간에 다른 약정이 없는 한 당사자의 일방이 이행에 착수할 때까지 교부자는 이를 포기하고 수령자는 그 배액을 상환하여 매매계약을 해제할 수 있다.

해약금과 이행의 착수 — 대금 청구 소송은 착수가 아니다

대법원 2008. 10. 23. 선고 2007다72274, 72281 판결 매매대금

최근 5년 기출 **2026** 가맹거래사 | **2025** 국가직 7급 · 노무사 | **2022** 법무사 · 변리사

사실 A회사는 B회사로부터 C회사 주식을 사기로 하고 계약금을 지급하였으나, 잔금은 지급기일이 지나도록 치르지 않았다. A회사가 계약의 취소 또는 해제를 이유로 계약금의 반환을 구하자, B회사는 반소로 잔대금의 지급을 구하였다. 제1심이 A회사의 본소를 기각하고 B회사의 반소를 인용하자, A회사는 그 판결 선고일에 계약금을 포기하고 계약을 해제한다는 의사표시를 하였다. 원심은 이 해제가 적법하다고 보아 반소를 기각하였다.

쟁점 **매도인이 잔대금의 지급을 구하는 소송을 냈다면, 매수인은 더 이상 계약금을 포기하고 계약을 해제할 수 없을까?**

판단 매수인은 민법 제565조 제1항에 따라 본인 또는 매도인이 이행에 착수할 때까지는 계약금을 포기하고 계약을 해제할 수 있는바, 여기에서 이행에 착수한다는 것은 객관적으로 외부에서 인식할 수 있는 정도로 채무의 이행행위의 일부를 하거나 또는 이행을 하기 위하여 필요한 전제행위를 하는 경우를 말하는 것으로서 단순히 이행의 준비를 하는 것만으로는 부족하고, 그렇다고 반드시 계약내용에 들어맞는 이행제공의 정도에까지 이르러야 하는 것은 아니지만, 매도인이 매수인에 대하여 매매계약의 이행을 최고하고 매매잔대금의 지급을 구하는 소송을 제기한 것만으로는 이행에 착수하였다고 볼 수 없다. — 판결요지 [1]

해설 매매에서 계약금이 교부되면 다른 약정이 없는 한 계약금에 의한 해제가 인정된다(민법 제565조 제1항). 당사자 일방이 이행에 착수할 때까지 교부자는 계약금을 포기하고, 수령자는 그 배액을 상환하여 계약을 해제할 수 있다. 이행의 착수는 채무의 이행행위의 일부를 하거나 이행에 필요한 전제행위를 하는 것이어서, 단순한 이행의 준비로는 부족하다. 이 사건에서 매도인이 반소로 잔대금의 지급을 구한 것만으로는 이행의 착수가 아니므로, 제1심에서 진 매수인도 계약금을 포기하고 해제할 수 있었다. 이러한 해제권 행사가 신의칙에 반하는 것도 아니다. 이 판결은 또 주권발행 전 주식의 매매에 관하여, 매수인은 스스로 이행에 착수하거나 매도인이 회사에 양도사실을 통지하거나 그 전제행위를 하기 전까지 해제할 수 있다고 하였다.

확인 매도인이 매수인에게 이행을 최고하고 잔대금의 지급을 구하는 소송을 제기하였다면 이행에 착수한 것이므로, 매수인은 계약금을 포기하고 계약을 해제할 수 없다. **(O · X)**

핵심어 해약금·계약금·이행의 착수·계약의 해제·주권발행 전 주식
함께 읽기 1-283 · 3-088 · 특-448 · 특-449 · 특-447
확인 답 X — 매매계약의 이행을 최고하고 매매잔대금의 지급을 구하는 소송을 제기한 것만으로는 이행에 착수하였다고 볼 수 없다.

제734조(사무관리의 내용)
①의무없이 타인을 위하여 사무를 관리하는 자는 그 사무의 성질에 좇아 가장 본인에게 이익되는 방법으로 이를 관리하여야 한다.
②관리자가 본인의 의사를 알거나 알 수 있는 때에는 그 의사에 적합하도록 관리하여야 한다.
③관리자가 전2항의 규정에 위반하여 사무를 관리한 경우에는 과실없는 때에도 이로 인한 손해를 배상할 책임이 있다. 그러나 그 관리행위가 공공의 이익에 적합한 때에는 중대한 과실이 없으면 배상할 책임이 없다.

사무관리의 성립 — 자기 이익이 섞여도 타인을 위한 의사

대법원 2013. 8. 22. 선고 2013다30882 판결 등기비용등

최근 5년 기출 **2024** 노무사 · 법무사 · 법원행시

사실 갑은 을에 대한 채권을 강제집행하려고, 을이 병 등과 공동으로 상속한 부동산에 관하여 을을 대위하여 상속등기를 신청하였다. 공동상속인 중 일부의 지분만 상속등기할 수는 없었으므로, 갑은 등기비용을 들여 공동상속인 전원 명의로 등기를 마쳤다. 갑은 병 등에게 그들 몫의 등기비용을 사무관리에 따라 상환하라고 청구하였으나, 원심은 갑이 타인을 위하여 사무를 관리한 것으로 볼 수 없다며 이를 배척하였다.

쟁점 **자기 채권을 집행하려고 한 일이라도, 그 이익이 다른 사람에게 돌아간다면 사무관리가 될 수 있을까?**

판단 사무관리가 성립하기 위하여는 우선 그 사무가 타인의 사무이고 타인을 위하여 사무를 처리하는 의사, 즉 관리의 사실상의 이익을 타인에게 귀속시키려는 의사가 있어야 하며, 나아가 그 사무의 처리가 본인에게 불리하거나 본인의 의사에 반한다는 것이 명백하지 아니할 것을 요한다. 여기에서 '타인을 위하여 사무를 처리하는 의사'는 관리자 자신의 이익을 위한 의사와 병존할 수 있고, 반드시 외부적으로 표시될 필요가 없으며, 사무를 관리할 당시에 확정되어 있을 필요가 없다. – 판결요지 [1]

해설 사무관리는 법률상 의무 없이 타인의 사무를 처리한 경우에 성립하는 법정채권이다. 판례는 그 요건을 타인의 사무, 타인을 위하여 처리하는 의사, 본인에게 불리하거나 본인의 의사에 반함이 명백하지 않을 것으로 정리하였다. 핵심은 둘째 요건인데, 관리의 사실상 이익을 타인에게 돌리려는 의사이면 충분하고 자기 이익을 위한 의사가 함께 있어도 부정되지 않는다. 그래서 채권자가 자기 채권을 보전하려고 공동상속등기를 대위신청한 경우에도, 등기에 따른 이익을 다른 공동상속인에게 귀속시키려는 의사가 인정되어 채무자 아닌 공동상속인에게 등기비용의 상환을 청구할 수 있다.

확인 관리자에게 자기 이익을 위한 의사가 함께 있으면 '타인을 위하여 사무를 처리하는 의사'는 부정되어 사무관리가 성립하지 않는다. **(O · X)**

핵심어 사무관리·타인을 위하여 사무를 처리하는 의사·비용상환청구권·채권자대위·공동상속등기
함께 읽기 3-096 · 특-492 · 4-062
확인 답 X — 타인을 위하여 사무를 처리하는 의사는 관리자 자신의 이익을 위한 의사와 병존할 수 있다.

제772조(양자와의 친계와 촌수)
①양자와 양부모 및 그 혈족, 인척사이의 친계와 촌수는 입양한 때로부터 혼인 중의 출생자와 동일한 것으로 본다.
②양자의 배우자, 직계비속과 그 배우자는 전항의 양자의 친계를 기준으로 하여 촌수를 정한다.

조부모의 손자녀 입양 — 복리에 맞으면 허가할 수 있다

대법원 2021. 12. 23. 자 2018스5 전원합의체 결정 미성년자입양허가

최근 5년 기출 **2024** 법원행시 | **2023** 법무사 · 변호사시험 | **2022** 법무사 · 법원직 9급

사실 갑 부부의 딸 을은 혼인 중 병을 낳은 뒤, 병이 생후 7개월 무렵일 때 병을 갑 부부의 집에 두고 갔다. 그때부터 갑 부부가 병을 길렀고, 을은 병의 친생부와 협의이혼하였다. 갑 부부는 병의 입양허가를 청구하였고, 친생부모는 입양에 동의하였다. 원심은 친생모가 살아 있어 갑 부부가 외조부모이자 부모가 되고 을은 병의 어머니이자 누나가 되는 등 친족관계에 중대한 혼란이 생긴다는 이유 등으로 청구를 기각한 제1심결정을 유지하였다.

쟁점 **친생부모가 살아 있는데도 조부모가 손자녀를 입양하여 부모가 될 수 있을까?**

판단 조부모와 손자녀 사이에는 이미 혈족관계가 존재하지만 부모·자녀 관계에 있는 것은 아니다. 민법은 입양의 요건으로 동의와 허가 등에 관하여 규정하고 있을 뿐이고 존속을 제외하고는 혈족의 입양을 금지하고 있지 않다(민법 제877조 참조). 따라서 조부모가 손자녀를 입양하여 부모·자녀 관계를 맺는 것이 입양의 의미와 본질에 부합하지 않거나 불가능하다고 볼 이유가 없다. 조부모가 자녀의 입양허가를 청구하는 경우에 입양의 요건을 갖추고 입양이 자녀의 복리에 부합한다면 이를 허가할 수 있다. 다만 조부모가 자녀를 입양하는 경우에는, 양부모가 될 사람과 자녀 사이에 이미 조손(祖孫)관계가 존재하고 있고 입양 후에도 양부모가 여전히 자녀의 친생부 또는 친생모에 대하여 부모의 지위에 있다는 특수성이 있으므로, 이러한 사정이 자녀의 복리에 미칠 영향에 관하여 세심하게 살필 필요가 있다. — 결정요지 (가) 다수의견

해설 입양은 법이 정한 절차에 따라 원래 부모·자녀가 아닌 사람 사이에 부모·자녀 관계를 만드는 제도이다. 입양되면 양자와 양부모 및 그 혈족·인척 사이의 친계와 촌수는 입양한 때부터 혼인 중의 출생자와 같아지고(민법 제772조), 입양 전의 친족관계도 그대로 남는다. 그래서 조부모가 입양하면 조부모가 손자녀의 법적인 부모의 지위를 겸하게 되고 친생모는 어머니이자 누나가 되지만, 민법은 존속을 제외하고는 혈족의 입양을 금지하지 않는다. 미성년자 입양허가에서는 자녀의 복리가 최우선 기준이어서, 친족관계에 혼란이 생길 수 있다는 사정만으로 막연히 불허할 것이 아니다. 법원은 입양의 실질적 의사와 주된 목적, 친생부모 동의의 자발성, 양육 상황 등을 심리하여 도움과 우려를 비교·형량하여야 한다. 반대의견은 친생부모가 생존한 경우 입양허가를 엄격하게 하여야 한다고 보았다.

범위 대법원은 입양을 허가한 것이 아니라, 자녀의 복리에 관한 심리를 다하지 않고 청구를 기각한 원심을 파기하였다.

확인 친생모가 생존하고 있다는 사정만으로는 조부모의 손자녀 입양을 불허할 이유가 되지 않는다. **(O · X)**

핵심어 입양·양자와의 친계와 촌수·조손관계·미성년자 입양허가·자녀의 복리

확인 답 O — 친생모가 생존하고 있더라도 입양의 요건을 갖추고 입양이 자녀의 복리에 부합하면 조부모의 입양을 허가할 수 있다.

제839조의2(재산분할청구권)
①협의상 이혼한 자의 일방은 다른 일방에 대하여 재산분할을 청구할 수 있다.
②제1항의 재산분할에 관하여 협의가 되지 아니하거나 협의할 수 없는 때에는 가정법원은 당사자의 청구에 의하여 당사자 쌍방의 협력으로 이룩한 재산의 액수 기타 사정을 참작하여 분할의 액수와 방법을 정한다.
③제1항의 재산분할청구권은 이혼한 날부터 2년을 경과한 때에는 소멸한다.

채무초과 부부의 재산분할 — 채무 분담도 정할 수 있다

대법원 2013. 6. 20. 선고 2010므4071, 4088 전원합의체 판결 이혼·이혼및재산분할등

최근 5년 기출 **2024** 법무사

사실 을이 이혼을 청구하자 갑은 반소로 이혼과 재산분할을 청구하였다. 을의 재산은 보험 해약환급금 예상액과 예금 합계 약 574만 원, 대출금채무 약 353만 원이었다. 갑의 재산은 시가 1억 8,500만 원의 아파트였으나, 임대차보증금반환채무와 대출금채무 등 약 2억 2,687만 원의 채무가 있었다. 원심은 부부의 총재산가액에서 채무액을 빼면 남는 금액이 없다는 이유로 갑의 재산분할 청구를 배척하였다.

쟁점 **부부의 빚이 재산보다 많아 재산분할이 결국 빚을 나누는 일이 되더라도, 재산분할을 청구할 수 있을까?**

판단 소극재산의 총액이 적극재산의 총액을 초과하여 재산분할을 한 결과가 결국 채무의 분담을 정하는 것이 되는 경우에도 법원은 채무의 성질, 채권자와의 관계, 물적 담보의 존부 등 일체의 사정을 참작하여 이를 분담하게 하는 것이 적합하다고 인정되면 구체적인 분담의 방법 등을 정하여 재산분할 청구를 받아들일 수 있다 할 것이다. 그것이 부부가 혼인 중 형성한 재산관계를 이혼에 즈음하여 청산하는 것을 본질로 하는 재산분할 제도의 취지에 맞고, 당사자 사이의 실질적 공평에도 부합한다. … 적극재산을 분할할 때처럼 재산형성에 대한 기여도 등을 중심으로 일률적인 비율을 정하여 당연히 분할 귀속되게 하여야 한다는 취지는 아니라는 점을 덧붙여 밝혀 둔다. – 판결요지 다수의견

해설 민법 제839조의2는 가정법원이 쌍방의 협력으로 이룩한 재산의 액수 기타 사정을 참작하여 분할의 액수와 방법을 정하도록 할 뿐, 분할대상을 적극재산으로 한정하지 않는다. 재산분할은 혼인 중 공동으로 형성한 재산을 청산·분배하는 제도여서, 공동재산의 형성이나 공동생활비용 조달에 따른 채무도 분할의 대상이 된다. 그래서 채무가 재산보다 많아 분할의 결과가 채무의 분담이 되더라도, 분담이 적합하다고 인정되면 청구를 받아들일 수 있다. 다만 부양적 요소도 고려하므로, 분담으로 채무초과가 생기거나 악화되면 채무의 경위와 용처, 경제적 활동능력 등을 종합하여 분담 여부와 방법을 정한다. 이 판결로 남는 금액이 없으면 청구를 받아들일 수 없다던 종전 판례가 변경되었고, 반대의견과 별개의견이 있다.

확인 부부의 소극재산 총액이 적극재산 총액을 넘어 나눌 재산이 남지 않는다면, 재산분할 청구는 당연히 배척된다. **(O · X)**

핵심어 재산분할청구권·소극재산·채무의 분담·재산관계의 청산·부양적 요소
함께 읽기 1-331 · 특-534 · 특-535 · 2-130 · 2-129 · 4-067 · 1-328
확인 답 X — 법원은 일체의 사정을 참작하여 채무를 분담하게 하는 것이 적합하다고 인정되면 분담의 방법을 정하여 재산분할 청구를 받아들일 수 있다.

제1028조(한정승인의 효과) 상속인은 상속으로 인하여 취득할 재산의 한도에서 피상속인의 채무와 유증을 변제할 것을 조건으로 상속을 승인할 수 있다.

한정승인자의 저당권 설정 — 상속채권자가 우선하지 못한다

대법원 2010. 3. 18. 선고 2007다77781 전원합의체 판결 배당이의

최근 5년 기출 **2026** 법원직 9급 | **2022** 법무사

사실 갑이 사망하자 자녀들은 상속을 포기하고 처 을이 한정승인신고를 하여 수리되었다. 을은 상속부동산에 상속등기를 마친 뒤 자신의 채권자 병에게 채권최고액 1천만 원의 근저당권을 설정해 주었다. 갑에게 돈을 빌려준 정은 을을 상대로 상속재산의 한도에서 지급하라는 판결을 받아 그 부동산에 강제경매를 신청하였다. 경매법원이 병에게 먼저 배당하자 정이 이의하였고, 원심은 상속채권자인 정에게 우선 배당하여야 한다고 보았다.

쟁점 **한정승인을 한 상속인이 상속재산에 자기 채권자를 위한 저당권을 설정했다면, 상속채권자가 그 저당권자보다 먼저 배당받을 수 있을까?**

판단 법원이 한정승인신고를 수리하게 되면 피상속인의 채무에 대한 상속인의 책임은 상속재산으로 한정되고, 그 결과 상속채권자는 특별한 사정이 없는 한 상속인의 고유재산에 대하여 강제집행을 할 수 없다. … 한정승인으로 발생하는 위와 같은 책임제한 효과로 인하여 한정승인자의 상속재산 처분행위가 당연히 제한된다고 할 수는 없다. … 민법 제1045조 이하의 재산분리 제도와 달리 한정승인이 이루어진 상속재산임을 등기하여 제3자에 대항할 수 있게 하는 규정도 마련하고 있지 않다. … 따라서 한정승인자로부터 상속재산에 관하여 저당권 등의 담보권을 취득한 사람과 상속채권자 사이의 우열관계는 민법상의 일반원칙에 따라야 하고, 상속채권자가 한정승인의 사유만으로 우선적 지위를 주장할 수는 없다. — 판결요지 다수의견

해설 상속인은 상속개시된 때부터 피상속인의 재산에 관한 포괄적 권리의무를 승계한다(민법 제1005조). 한정승인을 하여도 이 승계는 그대로이고, 상속채무에 대한 책임이 상속재산의 한도로 제한될 뿐이어서 상속채권자는 상속인의 고유재산에 강제집행하지 못한다. 민법은 한정승인자가 상속재산을 은닉하거나 부정소비하면 단순승인으로 볼 뿐 처분행위 자체를 제한하지 않고, 재산분리와 달리 한정승인 사실을 등기하여 제3자에게 대항하게 하는 규정도 두지 않았다. 따라서 한정승인자에게서 저당권을 취득한 사람과 상속채권자의 우열은 일반원칙에 따르고, 상속채권자는 한정승인만을 이유로 우선할 수 없다. 반대의견은 상속채권자의 우선적 권리를 인정하였다.

확인 한정승인자가 상속재산에 자기 채권자를 위한 근저당권을 설정하였더라도, 상속채권자는 한정승인을 이유로 그 근저당권자보다 우선하여 배당받는다. **(O · X)**

핵심어 한정승인·포괄적 권리의무의 승계·상속채권자·재산분리·배당이의의

함께 읽기 2-139

확인 답 X — 상속채권자는 한정승인의 사유만으로 우선적 지위를 주장할 수 없고, 둘 사이의 우열은 민법상의 일반원칙에 따른다.

제1조(범죄의 성립과 처벌)
① 범죄의 성립과 처벌은 행위 시의 법률에 따른다.

판례 변경과 처벌 — 형벌불소급의 원칙에 반하지 않는다

대법원 1999. 9. 17. 선고 97도3349 판결 특정경제범죄가중처벌등에관한법률위반(재산국외도피·업무상배임)·공문서변조·변조공문서행사

최근 5년 기출 **2026** 경찰 · 국가직 5급(헌법) · 국가직 7급(헌법) · 국가직 9급 · 군무원 · 법원직 9급 · 법원행시(헌법) · 외교관후보자 선발시험(헌법) · 지역인재 7급(헌법) | **2025** 군무원 | **2024** 경찰 · 경찰간부후보생 · 국가직 7급 · 법원행시(헌법) | **2023** 경찰 · 경찰 승진시험 · 경찰간부후보생 · 법원행시(헌법) | **2022** 경찰 승진시험(헌법) · 군무원(헌법)

사실 A회사의 대표이사인 피고인은 갑이나 B회사가 A회사에 현물출자한 기자재를 A회사가 수입한 것처럼 관계 서류를 변조하거나 허위로 작성하여 은행에 제출하였다. 이로써 은행으로 하여금 수입결제대금 명목으로 외화를 미국에 송금하게 하여 재산을 국외로 도피시키고, A회사에 같은 액수의 채무를 부담하게 하였다. 원심이 유죄를 인정하자 피고인이 상고하였고, 행위 당시의 판례에 의하면 처벌대상이 아니었던 행위를 판례의 변경에 따라 처벌할 수 있는지가 문제 되었다.

쟁점 **행위 당시의 판례로는 처벌되지 않던 행위를 뒤에 바뀐 판례에 따라 처벌할 수 있을까?**

판단 형사처벌의 근거가 되는 것은 법률이지 판례가 아니고, 형법 조항에 관한 판례의 변경은 그 법률조항의 내용을 확인하는 것에 지나지 아니하여 이로써 그 법률조항 자체가 변경된 것이라고 볼 수는 없으므로, 행위 당시의 판례에 의하면 처벌대상이 되지 아니하는 것으로 해석되었던 행위를 판례의 변경에 따라 확인된 내용의 형법 조항에 근거하여 처벌한다고 하여 그것이 헌법상 평등의 원칙과 형벌불소급의 원칙에 반한다고 할 수는 없다. — 판결요지

해설 형법 제1조 제1항은 범죄의 성립과 처벌은 행위 시의 법률에 따른다고 정하고, 헌법 제13조 제1항도 형벌불소급의 원칙을 둔다. 이 판결은 형사처벌의 근거가 되는 것은 법률이지 판례가 아니라는 데서 출발한다. 판례의 변경은 법률조항의 내용을 확인하는 것에 지나지 않고, 법률조항 자체를 바꾸는 것이 아니다. 그러므로 종전 판례로는 처벌대상이 아니라고 해석되던 행위라도 변경된 판례로 확인된 내용의 형법 조항에 근거하여 처벌할 수 있고, 이는 평등의 원칙에도 반하지 않는다.

확인 행위 당시의 판례에 따르면 처벌대상이 아니던 행위를 판례가 변경된 뒤 변경된 해석에 따라 처벌하는 것은 형벌불소급의 원칙에 반한다. **(O · X)**

핵심어 형벌불소급의 원칙·판례의 변경·행위시법주의·평등의 원칙

함께 읽기 특-561 · 1-355 · 1-357 · 1-356 · 특-562 · 1-354 · 1-353 · 3-106 · 특-564 · 특-563 · 1-351 · 1-352 외 3

확인 답 X — 형사처벌의 근거는 법률이지 판례가 아니고 판례의 변경은 법률조항의 내용을 확인하는 것에 지나지 않으므로 형벌불소급의 원칙에 반하지 않는다.

제25조(미수범)
①범죄의 실행에 착수하여 행위를 종료하지 못하였거나 결과가 발생하지 아니한 때에는 미수범으로 처벌한다.

준강도의 기수·미수 — 절도행위의 기수 여부로 가린다

대법원 2004. 11. 18. 선고 2004도5074 전원합의체 판결 준강도(인정된죄명:준강도미수)

최근 5년 기출 **2026** 경찰 승진시험 · 국가직 7급 · 군무원 · 해양경찰 승진시험 | **2025** 군무원 · 법원직 9급 | **2024** 경찰 | **2023** 경찰 승진시험 · 해양경찰 승진시험 | **2022** 군무원 · 해양경찰

사실 피고인은 갑과 합동하여 양주를 훔치기로 하고, 갑이 계단에서 망을 보는 사이 주점의 잠금장치를 뜯고 들어가 양주 45병을 바구니에 담던 중 종업원들이 돌아오려는 소리를 듣고 양주를 그대로 둔 채 나오다가 붙잡히자, 체포를 면탈할 목적으로 자신의 목을 잡고 있던 피해자의 손을 깨무는 등 폭행하였다. 원심은 피고인을 준강도미수죄로 처단하였다.

쟁점 **물건을 훔치지 못한 채 체포를 피하려고 폭행했다면 준강도의 기수가 될까?**

판단 형법 제335조에서 절도가 재물의 탈환을 항거하거나 체포를 면탈하거나 죄적을 인멸할 목적으로 폭행 또는 협박을 가한 때에 준강도로서 강도죄의 예에 따라 처벌하는 취지는, 강도죄와 준강도죄의 구성요건인 재물탈취와 폭행·협박 사이에 시간적 순서상 전후의 차이가 있을 뿐 실질적으로 위법성이 같다고 보기 때문이다. 그러므로 피해자에 대한 폭행·협박을 수단으로 하여 재물을 탈취하고자 하였으나 그 목적을 이루지 못한 자가 강도미수죄로 처벌되는 것과 마찬가지로, 절도미수범인 이 폭행·협박을 가한 경우에도 강도미수에 준하여 처벌하는 것이 합리적이라 할 것이다. … 위와 같은 준강도죄의 입법 취지, 강도죄와의 균형 등을 종합적으로 고려해 보면, 준강도죄의 기수 여부는 절도행위의 기수 여부를 기준으로 하여 판단하여야 한다고 봄이 상당하다. — 이유 1.

해설 형법 제25조 제1항은 범죄의 실행에 착수하여 행위를 종료하지 못하였거나 결과가 발생하지 아니한 때를 미수범으로 처벌한다. 다수의견은 준강도죄의 기수와 미수를 폭행·협박이 아니라 절도행위의 기수 여부로 가려야 한다고 보았다. 폭행·협박을 기준으로 하면 재물을 절취하지 못한 채 폭행·협박만 한 경우에도 준강도의 기수가 되어 강도미수죄와 균형이 맞지 않기 때문이다. 이 사건 피고인은 양주를 그대로 둔 채 나왔으므로 절도가 미수에 그쳐 준강도미수죄가 된다. 이 판결로 절도미수범의 폭행을 준강도미수로 볼 수 없다고 한 종전 판례가 변경되었다. 별개의견은 폭행·협박이나 절취 중 어느 하나라도 미수이면 준강도미수라고 보았고, 반대의견은 폭행·협박의 종료 여부로 가려야 한다고 보았다.

확인 절도가 미수에 그쳤더라도 체포를 면탈할 목적으로 폭행을 마쳤다면 준강도죄의 기수가 된다. **(O · X)**

핵심어 준강도·미수범·기수와 미수의 구별·절도미수·강도죄와의 균형
함께 읽기 1-477 · 특-595 · 2-147 · 4-071
확인 답 X — 다수의견에 따르면 준강도죄의 기수 여부는 절도행위의 기수 여부를 기준으로 판단하므로 준강도미수가 된다.

제27조(불능범) 실행의 수단 또는 대상의 착오로 인하여 결과의 발생이 불가능하더라도 위험성이 있는 때에는 처벌한다. 단, 형을 감경 또는 면제할 수 있다.

준강간의 불능미수 — 대상의 착오라도 위험성 있으면 처벌

대법원 2019. 3. 28. 선고 2018도16002 전원합의체 판결 강간(인정된죄명:준강간미수·변경된죄명:준강간)

최근 5년 기출 **2026** 국가직 7급 · 국가직 9급 · 군무원 · 법원직 9급 · 해양경찰 승진시험 | **2025** 경찰 · 경찰간부후보생 · 경찰대학 편입 · 국가직 7급 · 군무원 · 법원직 9급 | **2024** 경찰 · 국가직 7급 · 국가직 9급 · 군무원 · 변호사시험 | **2023** 경찰 · 경찰간부후보생 · 경찰대학 편입 · 변호사시험 · 해양경찰 · 해양경찰 승진시험 | **2022** 경찰 · 경찰 승진시험 · 국가직 9급 · 법원 승진시험 · 해양경찰

사실 피고인은 자신의 집에서 아내, 피해자와 함께 술을 마시다가, 피해자가 안방에 들어가 눕자 따라 들어가 피해자를 간음하였다. 강간으로 기소되었으나 폭행·협박도, 피해자가 심신상실 또는 항거불능의 상태에 있었다는 점도 증명되지 않았다. 원심은 준강간의 불능미수를 유죄로 인정하였고, 피고인은 준강간의 고의가 없었다는 등의 이유로 상고하였다.

쟁점 **피해자가 실제로는 항거불능 상태가 아니었는데 그렇다고 믿고 간음했다면, 준강간죄의 미수로 처벌할 수 있을까?**

판단 따라서 피고인이 피해자가 심신상실 또는 항거불능의 상태에 있다고 인식하고 그러한 상태를 이용하여 간음할 의사로 피해자를 간음하였으나 피해자가 실제로는 심신상실 또는 항거불능의 상태에 있지 않은 경우에는, 실행의 수단 또는 대상의 착오로 인하여 준강간죄에서 규정하고 있는 구성요건적 결과의 발생이 처음부터 불가능하였고 실제로 그러한 결과가 발생하였다고 할 수 없다. 피고인이 준강간의 실행에 착수하였으나 범죄가 기수에 이르지 못하였으므로 준강간죄의 미수범이 성립한다. 피고인이 행위 당시에 인식한 사정을 놓고 일반인이 객관적으로 판단하여 보았을 때 준강간의 결과가 발생할 위험성이 있었으므로 준강간죄의 불능미수가 성립한다. — 판결요지 [2] 다수의견

해설 형법 제27조의 불능미수는 범죄의사와 실행의 착수가 있지만 실행의 수단이나 대상의 착오로 처음부터 결과 발생이 불가능한 경우이다. 결과가 불가능하더라도 위험성이 있으면 미수범으로 처벌하되 형을 감경 또는 면제할 수 있고, 위험성이 없으면 처벌하지 않는 불능범이 된다. 다수의견은 위험성을 피고인이 행위 당시에 인식한 사정을 놓고 일반인이 객관적으로 판단하여 결과 발생의 가능성이 있는지로 따졌다. 피해자가 항거불능 상태에 있지 않았다면 준강간의 기수는 처음부터 불가능하지만, 피고인이 인식한 사정으로 보아 위험성이 있었으므로 불능미수가 성립한다. 처음부터 기수의 가능성이 객관적으로 없다는 점에서 장애미수·중지미수와 구별된다. 이 판결에는 반대의견이 있다.

확인 불능미수의 위험성은 피해자의 실제 상태를 기준으로 일반인이 객관적으로 판단한다. **(O · X)**

핵심어 불능미수·불능범·위험성·실행의 수단 또는 대상의 착오·준강간

함께 읽기 3-114 · 특-597

확인 답 X — 위험성은 피고인이 행위 당시에 인식한 사정을 놓고 일반인이 객관적으로 판단하여 결과 발생의 가능성이 있는지로 따진다.

제34조(간접정범, 특수한 교사, 방조에 대한 형의 가중)
①어느 행위로 인하여 처벌되지 아니하는 자 또는 과실범으로 처벌되는 자를 교사 또는 방조하여 범죄행위의 결과를 발생하게 한 자는 교사 또는 방조의 예에 의하여 처벌한다.
②자기의 지휘, 감독을 받는 자를 교사 또는 방조하여 전항의 결과를 발생하게 한 자는 교사인 때에는 정범에 정한 형의 장기 또는 다액에 그 2분의 1까지 가중하고 방조인 때에는 정범의 형으로 처벌한다.

공문서위조의 간접정범 — 공무원이 속아 작성했다면 불성립

대법원 2001. 3. 9. 선고 2000도938 판결 공문서위조·위조공문서행사·변조공문서행사

최근 5년 기출 **2026** 해양경찰 | **2025** 경찰 · 해양경찰 | **2024** 법원행시 · 해양경찰 | **2023** 경찰 승진시험 | **2022** 군무원

사실 A회사와 B회사의 대표이사인 피고인들은 두 회사 공동으로 도로 확장공사 입찰에 참가하였으나, 공사실적이 부족하여 탈락할 위기에 처하였다. 피고인들은 관할관청에 공사실적증명원을 약 10부씩 제출하면서 그중 1부에 사실과 다른 허위의 내용을 적었고, 이를 모르는 담당공무원은 관청의 직인을 찍어 공사실적증명서를 작성해 주었다. 검사는 공문서위조·위조공문서행사로 기소하였으나, 원심은 작성권한이 있는 공무원이 작성한 것이라며 무죄를 선고하였다.

쟁점 **공무원을 속여 허위 내용의 증명서를 발급받으면 공문서위조죄의 간접정범이 될까?**

판단 어느 문서의 작성권한을 갖는 공무원이 그 문서의 기재 사항을 인식하고 그 문서를 작성할 의사로써 이에 서명날인하였다면, 설령 그 서명날인이 타인의 기망으로 착오에 빠진 결과 그 문서의 기재사항이 진실에 반함을 알지 못한 데 기인한다고 하여도, 그 문서의 성립은 진정하며 여기에 하등 작성명의를 모용한 사실이 있다고 할 수는 없으므로, 공무원 아닌 자가 관공서에 허위 내용의 증명원을 제출하여 그 내용이 허위인 정을 모르는 담당공무원으로부터 그 증명원 내용과 같은 증명서를 발급받은 경우 공문서위조죄의 간접정범으로 의율할 수는 없다. – 판결요지

해설 형법 제34조 제1항은 어느 행위로 인하여 처벌되지 아니하는 자 등을 교사 또는 방조하여 범죄행위의 결과를 발생하게 한 자를 교사 또는 방조의 예에 의하여 처벌한다. 이 판결은 작성권한 있는 공무원이 기재사항을 인식하고 작성할 의사로 서명날인하였다면, 속아서 내용이 진실에 반함을 몰랐더라도 문서의 성립은 진정하고 작성명의를 모용한 것이 아니라고 보았다. 그러므로 공무원 아닌 자가 담당공무원을 속여 허위 내용의 증명서를 발급받았더라도 공문서위조죄의 간접정범으로 처벌할 수 없다. 공문서위조죄는 작성명의를 모용하는 범죄인데, 이 사건에서 거짓인 것은 명의가 아니라 문서의 내용이다. 위조공문서임을 전제로 하는 위조공문서행사죄도 성립하지 않는다.

확인 공무원 아닌 자가 허위 내용의 증명원을 제출하여 그 정을 모르는 담당공무원으로부터 증명서를 발급받았다면 공문서위조죄의 간접정범이 성립한다. **(O · X)**

핵심어 간접정범·공문서위조·작성명의의 모용·작성권한·위조공문서행사
함께 읽기 특-609 · 2-153
확인 답 X — 작성권한 있는 공무원이 기재사항을 인식하고 작성할 의사로 서명날인한 이상 문서의 성립은 진정하고 작성명의를 모용한 것이 아니다.

제52조(자수, 자복)
① 죄를 지은 후 수사기관에 자수한 경우에는 형을 감경하거나 면제할 수 있다.
② 피해자의 의사에 반하여 처벌할 수 없는 범죄의 경우에는 피해자에게 죄를 자복(自服)하였을 때에도 형을 감경하거나 면제할 수 있다.

자수의 시기 — 체포 전이면 지명수배 뒤에도 자수다

대법원 1997. 3. 20. 선고 96도1167 전원합의체 판결 공직선거및선거부정방지법위반

최근 5년 기출 **2026** 경찰 승진시험 · 국가직 9급 · 군무원 · 해양경찰 | **2025** 경찰간부후보생 | **2024** 군무원 · 해양경찰 · 해양경찰 승진시험 | **2023** 경찰간부후보생 · 군무원 · 해양경찰 · 해양경찰 승진시험 | **2022** 경찰 · 경찰 승진시험

사실 피고인은 시의원 선거에 출마한 갑을 당선되게 할 목적으로 갑의 선거사무장에게서 활동비 명목의 돈을 세 차례 받았다. 수사기관은 범행을 인지하여 피고인을 지명수배하고 구속영장도 발부받았으나, 피고인이 도피하자 기소중지하였다. 그 뒤 피고인은 검찰청에 자진 출두하여 범행을 자백하였다. 제1심은 자수한 금품 수령자의 형을 반드시 면제하도록 한 공직선거법 제262조에 따라 형을 면제하였으나, 원심은 범행이 발각된 뒤의 출두는 자수가 아니라며 형을 선고하였다.

쟁점 **범행이 발각되어 지명수배된 뒤에 스스로 출두해도 자수가 될 수 있을까?**

판단

> 형법 제52조는 자수를 임의적 감면사유로 규정하고 있는데 1953. 9. 18. 우리 형법 제정 이전의 구 형법(의용형법)에서는 자수는 "발각 전"이어야 한다는 시기적 제한을 두었으나, 현행 형법은 이런 제한을 삭제하였으므로 체포 전이라면 지명수배 후라도 자수에 해당한다(당원 1965. 10. 5. 선고 65도597 판결, 1994. 5. 10. 선고 94도659 판결, 1994. 9. 9. 선고 94도619 판결 참조)고 할 것이다. … 즉 발각 전의 자수와 발각 후의 자수를 같이 취급할 것인지 달리 취급할 것인지도 역시 범죄에 따라 논리필연적으로 정하여지는 것이 아니라 입법정책적인 문제임을 알 수 있는 것이다. – 이유 3. 나. (1)

해설 형법 제52조 제1항은 죄를 지은 후 수사기관에 자수한 경우 형을 감경하거나 면제할 수 있다고 정한다. 판례는 자수를 특별히 취급하는 까닭을 범인이 뉘우쳐 비난가능성이 약하다는 점과 수사를 쉽게 하여 형벌권을 정확하게 행사하게 한다는 점에서 찾고, 자수의 시기와 효과를 어떻게 정할지는 입법정책의 문제라고 보았다. 형법 제52조에는 시기 제한이 없으므로 범행이 발각되고 지명수배된 뒤라도 체포 전에 스스로 수사기관에 출두하여 범죄사실을 진술하면 자수가 된다. 다수의견은 공직선거법 제262조의 자수도 같은 뜻으로 보고, 이를 범행발각 전의 자수로 좁히는 해석은 형면제 사유를 제한적으로 유추하여 처벌범위를 넓히는 것이어서 유추해석금지의 원칙에 반한다고 하였다. 반대의견은 입법 취지에 비추어 범행발각 전의 자수로 좁히는 것은 목적론적 축소해석으로서 허용된다고 보았다.

범위 형법 제90조 제1항 단서처럼 법률이 '그 목적한 죄의 실행에 이르기 전' 등 자수의 시기를 따로 정한 경우에는 그 시기 안에 자수하여야 그 조항의 감면을 받는다.

확인 범행이 발각되어 지명수배된 뒤라도 체포 전에 스스로 수사기관에 출두하여 범죄사실을 진술하였다면 형법 제52조의 자수에 해당한다. **(O · X)**

핵심어 자수·임의적 감면·자수의 시기·형면제·유추해석금지
함께 읽기 1-391 · 특-622
확인 답 O — 현행 형법은 '발각 전'이라는 시기적 제한을 삭제하였으므로 체포 전이라면 지명수배 후라도 자수에 해당한다.

제152조(위증, 모해위증)
①법률에 의하여 선서한 증인이 허위의 진술을 한 때에는 5년 이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금에 처한다.

증언거부권 불고지와 위증 — 사실상 장애 있으면 불성립

대법원 2010. 1. 21. 선고 2008도942 전원합의체 판결 위증

최근 5년 기출 **2026** 경찰 승진시험 · 군무원 · 해양경찰 승진시험 | **2024** 국가직 7급 | **2023** 경찰 · 경찰간부후보생 · 변호사시험 | **2022** 경찰 · 경찰 승진시험

사실 피고인은 갑과의 쌍방 상해 사건으로 기소되어 갑과 함께 재판을 받으면서 자신은 폭행한 사실이 없다고 다투었다. 그 뒤 갑에 대한 상해 사건이 변론분리되자 피고인은 그 사건의 피해자인 증인으로 채택되어, 검사로부터 자신의 폭행 여부에 관하여 신문을 받게 되었다. 피고인은 증언거부사유가 생겼는데도 재판장으로부터 증언거부권을 고지받지 못한 채 종전 주장을 되풀이하여 거짓 진술을 하였다. 원심은 위증죄의 죄책을 물을 수 없다고 보았고, 검사가 상고하였다.

쟁점 **자기 범죄가 드러날 수 있어 증언을 거부할 수 있었는데 그 권리를 고지받지 못한 증인이 거짓 증언을 하면 위증죄가 될까?**

판단 재판장이 신문 전에 증인에게 증언거부권을 고지하지 않은 경우에도 당해 사건에서 증언 당시 증인이 처한 구체적인 상황, 증언거부사유의 내용, 증인이 증언거부사유 또는 증언거부권의 존재를 이미 알고 있었는지 여부, 증언거부권을 고지 받았더라도 허위진술을 하였을 것이라고 볼 만한 정황이 있는지 등을 전체적·종합적으로 고려하여 증인이 침묵하지 아니하고 진술한 것이 자신의 진정한 의사에 의한 것인지 여부를 기준으로 위증죄의 성립 여부를 판단하여야 한다. 그러므로 헌법 제12조 제2항에 정한 불이익 진술의 강요금지 원칙을 구체화한 자기부죄거부특권에 관한 것이거나 기타 증언거부사유가 있음에도 증인이 증언거부권을 고지받지 못함으로 인하여 그 증언거부권을 행사하는 데 사실상 장애가 초래되었다고 볼 수 있는 경우에는 위증죄의 성립을 부정하여야 할 것이다. — 판결요지 [3]

해설 위증죄의 '법률에 의하여 선서한 증인'은 법률이 정한 절차에 따라 유효한 선서를 하고 적법한 절차에 따라 신문받은 증인을 뜻한다. 그래서 증인 보호 규정이 지켜지지 않은 신문에서 한 허위진술은 원칙적으로 위증죄가 되지 않지만, 증인 보호에 사실상 장애가 없었다면 예외이다. 예컨대 선서 전에 위증의 벌을 경고하지 않았더라도 증인이 그 내용의 선서서를 낭독하고 기명날인 또는 서명하였다면 위증죄의 성립에 지장이 없다. 증언거부권 고지 제도는 증인에게 침묵할지 진술할지 심사숙고할 기회를 주어 침묵할 수 있는 권리를 보장하려는 것이므로, 고지가 없었던 경우에는 진술이 진정한 의사에 의한 것인지로 가린다. 고지 여부를 고려하지 않고 위증죄가 바로 성립한다고 한 대법원 1987. 7. 7. 선고 86도1724 전원합의체 판결은 이 판결에 저촉되는 범위에서 변경되었다.

범위 증언거부권을 고지하지 않았다고 하여 언제나 위증죄가 부정되는 것은 아니고, 증인이 증언거부권을 이미 알고 있었는지 등을 종합하여 진술이 진정한 의사에 의한 것인지를 따진다.

확인 선서한 증인이 허위의 진술을 한 이상, 증언거부사유가 있는데도 재판장이 증언거부권을 고지하지 않았다는 사정은 위증죄의 성립에 아무 영향이 없다. **(O · X)**

핵심어 위증·법률에 의하여 선서한 증인·증언거부권의 고지·자기부죄거부특권·판례변경
함께 읽기 4-084 · 특-658 · 3-125 · 특-657 · 특-656 · 1-415
확인 답 X — 증언거부권을 고지받지 못하여 그 권리를 행사하는 데 사실상 장애가 초래되었다고 볼 수 있는 경우에는 위증죄의 성립이 부정된다.

제156조(무고) 타인으로 하여금 형사처분 또는 징계처분을 받게 할 목적으로 공무소 또는 공무원에 대하여 허위의 사실을 신고한 자는 10년 이하의 징역 또는 1천500만원 이하의 벌금에 처한다.

피무고자의 승낙 — 무고죄 성립에 영향 없다

대법원 2005. 9. 30. 선고 2005도2712 판결 무고·변호사법위반

최근 5년 기출 **2026** 해양경찰 승진시험 | **2025** 경찰간부후보생 · 변호사시험 · 해양경찰 · 해양경찰 승진시험 | **2023** 국가직 7급 | **2022** 법원 승진시험 · 법원직 9급 · 법원행시

사실 피고인들은 갑에게 돈을 빌려준 적이 없는데도, 갑과 갑으로부터 피해를 당한 사람들 사이의 합의를 주선하려고 자신들도 피해자인 것처럼 행세하기로 하였다. 피고인들은 이 뜻을 갑에게 미리 알려 승낙을 받은 뒤, 갑에게 각 5,000만 원을 빌려주었으나 갚지 않으니 엄벌해 달라는 허위 내용의 고소장을 경찰서에 제출하였다. 그 뒤 피고인들은 수사기관의 출석요구에 응하지 않았고 고소사건은 각하로 끝났다. 원심은 무고의 목적이 없었다며 무죄로 보았고, 검사가 상고하였다.

쟁점 **고소당할 사람의 승낙을 받고, 그 사람의 처벌을 바라지도 않은 채 낸 허위 고소도 무고죄가 될까?**

판단 무고죄는 국가의 형사사법권 또는 징계권의 적정한 행사를 주된 보호법익으로 하고 다만, 개인의 부당하게 처벌 또는 징계받지 아니할 이익을 부수적으로 보호하는 죄이므로, 설사 무고에 있어서 피무고자의 승낙이 있었다고 하더라도 무고죄의 성립에는 영향을 미치지 못한다 할 것이고, 무고죄에 있어서 형사처분 또는 징계처분을 받게 할 목적은 허위신고를 함에 있어서 다른 사람이 그로 인하여 형사 또는 징계처분을 받게 될 것이라는 인식이 있으면 족한 것이고 그 결과발생을 희망하는 것까지를 요하는 것은 아니므로, 고소인이 고소장을 수사기관에 제출한 이상 그러한 인식은 있었다고 보아야 한다. — 판결요지 [1]

해설 무고죄는 국가의 형사사법권 또는 징계권의 적정한 행사를 주된 보호법익으로 하고, 부당하게 처벌받지 않을 개인의 이익은 부수적으로 보호할 뿐이다. 그래서 피무고자가 허위 신고를 승낙하였더라도 국가의 형사사법권 또는 징계권의 적정한 행사가 위태로워지는 것은 마찬가지이므로 무고죄의 성립에 영향이 없다. 또 '형사처분 또는 징계처분을 받게 할 목적'은 신고로 상대방이 그런 처분을 받게 될 것이라는 인식이면 족하고, 그 결과를 바랄 필요는 없다. 따라서 합의를 주선하려는 방편으로 고소하였더라도 고소장을 수사기관에 제출한 이상 적어도 미필적 인식은 있었다고 보아야 한다.

확인 피무고자가 자신에 대한 허위 고소를 미리 승낙하였다면 무고죄는 성립하지 않는다. **(O · X)**

핵심어 무고·피무고자의 승낙·국가의 형사사법권·형사처분을 받게 할 목적·미필적 인식

함께 읽기 2-166 · 3-126 · 1-419 · 특-663 · 특-661 · 특-662 · 특-664 · 2-165

확인 답 X — 무고죄는 국가의 형사사법권 또는 징계권의 적정한 행사를 주된 보호법익으로 하므로, 피무고자의 승낙은 무고죄의 성립에 영향을 미치지 못한다.

제231조(사문서등의 위조·변조) 행사할 목적으로 권리·의무 또는 사실증명에 관한 타인의 문서 또는 도화를 위조 또는 변조한 자는 5년 이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금에 처한다.

허무인·사망자 명의의 문서 — 사문서위조죄 성립

대법원 2005. 2. 24. 선고 2002도18 전원합의체 판결 사문서위조·위조사문서행사

최근 5년 기출 **2026** 경찰 · 해양경찰 | **2023** 경찰 | **2022** 법원행시

사실 피고인은 중국 중의사·침구사 시험 응시자를 모집하여 응시원서 제출을 대행하던 중 응시생의 임상경력증명서가 필요하게 되었다. 피고인은 중국 현지에서 받은 증명서 양식에 응시생의 이름·생년월일·학습기간 등을 적고, 원장과 한의원 이름을 생각나는 대로 임의로 적은 뒤 그 한의원 명의의 직인을 임의로 새겨 찍어 행사하였다. 원심은 사문서위조죄와 위조사문서행사죄를 유죄로 인정하였고, 피고인이 상고하였다.

쟁점 **문서에 적힌 명의인이 실제로 없는 사람이거나 이미 죽은 사람이어도 사문서위조죄가 될까?**

판단 문서위조죄는 문서의 진정에 대한 공공의 신용을 그 보호법익으로 하는 것이므로 행사할 목적으로 작성된 문서가 일반인으로 하여금 당해 명의인의 권한 내에서 작성된 문서라고 믿게 할 수 있는 정도의 형식과 외관을 갖추고 있으면 문서위조죄가 성립하는 것이고, 위와 같은 요건을 구비한 이상 그 명의인이 실재하지 않는 허무인이거나 또는 문서의 작성일자 전에 이미 사망하였다고 하더라도 그러한 문서 역시 공공의 신용을 해할 위험성이 있으므로 문서위조죄가 성립한다고 봄이 상당하며, 이는 공문서뿐만 아니라 사문서의 경우에도 마찬가지라고 보아야 한다. — 판결요지

해설 문서위조죄의 보호법익은 문서의 진정에 대한 공공의 신용이다. 그래서 판례는 행사할 목적으로 만든 문서가 일반인으로 하여금 명의인의 권한 내에서 작성된 문서라고 믿게 할 정도의 형식과 외관을 갖추었는지를 기준으로 위조죄의 성립을 가린다. 이 요건을 갖춘 이상 명의인이 실재하지 않는 허무인이거나 작성일자 전에 이미 사망한 사람이어도, 그 문서는 공공의 신용을 해할 위험이 있으므로 위조죄가 성립한다. 판결은 이 법리가 공문서뿐만 아니라 사문서에도 마찬가지라고 하면서, 허무인이나 사망자 명의의 사문서에 대하여 사문서위조죄의 성립을 부정한 종전 판례를 모두 변경하였다.

확인 명의인이 실재하지 않는 허무인이라면, 그 명의의 사문서를 만들어도 공공의 신용을 해할 위험이 없으므로 사문서위조죄가 성립하지 않는다. **(O · X)**

핵심어 사문서위조·허무인·사망자 명의·공공의 신용·형식과 외관·판례변경

함께 읽기 3-131 · 4-086 · 특-688 · 특-689 · 1-432 · 특-690

확인 답 X — 일반인이 명의인의 권한 내에서 작성된 문서라고 믿을 만한 형식과 외관을 갖추었다면, 명의인이 허무인이거나 사망자라도 사문서위조죄가 성립한다.

제232조의2(사전자기록위작·변작) 사무처리를 그르치게 할 목적으로 권리·의무 또는 사실증명에 관한 타인의 전자기록등 특수매체기록을 위작 또는 변작한 자는 5년 이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금에 처한다.

사전자기록 위작 — 권한을 남용한 허위 입력도 포함

대법원 2020. 8. 27. 선고 2019도11294 전원합의체 판결 사기·특정경제범죄가중처벌등에관한법률위반(횡령)·업무상횡령·업무상배임·사전자기록등위작·위작사전자기록등행사·범죄수익은닉의규제및처벌등에관한법률위반·공정증서원본불실기재·불실기재공정증서원본행사·상법위반

최근 5년 기출 **2026** 경찰 · 해양경찰 승진시험 | **2025** 국가직 9급 · 군무원 | **2024** 경찰 | **2023** 경찰대학 편입 · 군무원 · 변호사시험 | **2022** 경찰 · 법원행시

사실 가상화폐 거래소를 운영하는 A회사의 대표이사인 피고인 1과 사내이사인 피고인 2는 거래가 활발한 것처럼 꾸미려고, A회사가 구축한 거래시스템의 관리자 계정에 접속하여 차명계정 15개를 만들었다. 피고인들은 실제 입금이 없는데도 이 차명계정들에 원화 포인트와 가상화폐 포인트의 보유량 정보를 90회에 걸쳐 입력하고, 자동주문 프로그램으로 매매주문을 냈다. 원심은 사전자기록등위작죄 등을 유죄로 인정하였고, 피고인들이 상고하였다.

쟁점 **시스템에 정보를 입력할 권한이 있는 사람이 그 권한을 남용해 허위 정보를 입력해도 전자기록의 '위작'이 될까?**

판단 대법원은, … 위와 같은 시스템을 설치·운영하는 주체와의 관계에서 전자기록의 생성에 관여할 권한이 없는 사람이 전자기록을 작출하거나 전자기록의 생성에 필요한 단위정보의 입력을 하는 경우는 물론 시스템의 설치·운영 주체로부터 각자의 직무 범위에서 개개의 단위정보의 입력 권한을 부여받은 사람이 그 권한을 남용하여 허위의 정보를 입력함으로써 시스템 설치·운영 주체의 의사에 반하는 전자기록을 생성하는 경우도 형법 제227조의2에서 말하는 전자기록의 '위작'에 포함된다고 판시하였다. 위 법리는 형법 제232조의2의 사전자기록등위작죄에서 행위의 태양으로 규정한 '위작'에 대해서도 마찬가지로 적용된다. — 판결요지 [4] 다수의견

해설 형법에는 '위작'의 정의 규정이 없어, 입력 권한이 있는 사람이 허위의 정보를 입력한 경우도 위작인지가 문제 되었다. 다수의견은 권한을 남용하여 시스템 설치·운영 주체의 의사에 반하는 전자기록을 만든 경우도 위작에 포함된다고 하면서, 전자기록에는 문서와 같은 작성명의인을 상정하기 어려운 점, 같은 형법의 공전자기록 위작과 달리 새길 수 없는 점, 입법자의 의사 등을 이유로 들었다. 법인이 운영하는 시스템의 전자기록은 대표이사 등 임직원에게도 '타인'의 전자기록이고, 처벌 범위는 사무처리를 그르치게 할 목적 등 다른 요건으로 걸러진다. 사문서는 원칙적으로 작성권한 없는 사람의 위조만 처벌하는데, 반대의견은 사전자기록의 위작도 그와 같이 새겨야 한다고 보았다.

확인 입력 권한을 부여받은 사람이 그 권한을 남용하여 허위의 정보를 입력하였다면, 권한 없는 사람이 입력한 것이 아니므로 사전자기록등위작죄의 '위작'에 해당하지 않는다. **(O · X)**

핵심어 사전자기록등위작·위작의 의미·권한남용·허위의 정보·타인의 전자기록·사무처리를 그르치게 할 목적

함께 읽기 1-467

확인 답 X — 입력 권한을 부여받은 사람이 그 권한을 남용하여 허위의 정보를 입력함으로써 시스템 설치·운영 주체의 의사에 반하는 전자기록을 생성하는 경우도 '위작'에 포함된다.

제268조(업무상과실·중과실 치사상) 업무상과실 또는 중대한 과실로 사람을 사망이나 상해에 이르게 한 자는 5년 이하의 금고 또는 2천만원 이하의 벌금에 처한다.

업무상 과실 — 몰래 드나든 손님까지 통제할 의무는 없다

대법원 2010. 2. 11. 선고 2009도9807 판결 업무상과실치사·공중위생관리법위반

최근 5년 기출 **2026** 경찰 · 국가직 9급 | **2025** 경찰 · 국가직 9급 · 해양경찰 | **2024** 경찰 · 경찰 승진시험 · 군무원 · 법원행시 | **2023** 국가직 9급 · 해양경찰 승진시험 | **2022** 해양경찰 · 해양경찰 승진시험

사실 피해자는 술을 마신 뒤 찜질방에 들어가 요금을 내고 발한복을 빌렸다. 그 뒤 직원 몰래 후문으로 나가 술을 더 마시고 다시 후문으로 들어와 발한실에서 잠을 자다가 사망하였다. 야간에는 직원인 피고인 1 혼자 요금 수납과 발한복 대여 등을 맡고 있었다. 원심은 피해자가 처음 들어갈 때 이미 만취 상태였다고 보아, 피고인 1과 영업주인 피고인 2에게 출입 통제를 소홀히 한 업무상 주의의무 위반을 인정하였다.

쟁점 **손님이 직원 몰래 후문으로 나가 술을 더 마시고 들어오는 경우까지 막지 못했다면 업무상 주의의무 위반일까?**

판단 술을 마시고 찜질방에 들어온 甲이 찜질방 직원 몰래 후문으로 나가 술을 더 마신 다음 후문으로 다시 들어와 발한실(發汗室)에서 잠을 자다가 사망한 사안에서, 甲이 처음 찜질방에 들어갈 당시 술에 만취하여 목욕장의 정상적 이용이 곤란한 상태였다고 단정하기 어렵고, 찜질방 직원 및 영업주에게 손님이 몰래 후문으로 나가 술을 더 마시고 들어올 경우까지 예상하여 직원을 추가로 배치하거나 후문으로 출입하는 모든 자를 통제·관리하여야 할 업무상 주의의무가 있다고 보기 어렵다는 이유로, 위 찜질방 직원 및 영업주가 공중위생영업자로서의 업무상 주의의무를 위반하였다고 본 원심판단에 법리오해 및 심리미진의 위법이 있다고 한 사례. — 판결요지 [1]

해설 형법 제268조의 업무상과실치사죄는 업무상 주의의무를 위반하여 사람을 사망에 이르게 한 때 성립한다. 이 판결은 직원과 영업주의 주의의무가 손님이 몰래 후문으로 나가 술을 더 마시고 들어올 경우까지 예상하여 직원을 더 두거나 후문 출입자를 모두 통제할 정도에 이르지는 않는다고 보았다. 피해자가 처음 들어갈 때 만취 상태였다고 단정하기 어렵고, 후문으로 들어온 손님도 요금을 내고 발한복을 빌리는 과정에서 통제·관리가 이루어지고 있었다는 사정이 근거가 되었다. 같은 판결은 행정상의 단속을 주안으로 하는 법규라도 명문규정이 있거나 해석상 과실범도 벌할 뜻이 명확한 경우가 아니면 고의가 있어야 벌할 수 있다고 하였다. 그래서 음주 등으로 목욕장의 정상적인 이용이 곤란한 자를 출입시킨다는 고의가 없었던 직원은 물론 양벌조항으로 기소된 영업주에게도 공중위생관리법 위반의 책임을 물을 수 없다고 보았다.

범위 손님이 직원 몰래 드나든 사정에서 주의의무 위반을 부정한 사례일 뿐, 영업자에게 출입 통제에 관한 주의의무가 없다고 한 것은 아니다.

확인 찜질방 영업자에게는 손님이 직원 몰래 후문으로 나가 술을 더 마시고 들어올 경우까지 예상하여 후문 출입자를 모두 통제·관리할 업무상 주의의무가 있다. **(O · X)**

핵심어 업무상과실치사·업무상 주의의무·공중위생영업자·행정상 단속법규·과실범 처벌

함께 읽기 1-447 · 3-134 · 특-711 · 특-710 · 특-707 · 특-708 · 특-709 · 3-133

확인 답 X — 판례는 그러한 경우까지 예상하여 직원을 추가로 배치하거나 후문으로 출입하는 모든 자를 통제·관리할 업무상 주의의무가 있다고 보기 어렵다고 하였다.

제283조(협박, 존속협박)
①사람을 협박한 자는 3년 이하의 징역, 500만원 이하의 벌금, 구류 또는 과료에 처한다.

협박죄의 기수 — 상대방의 현실적 공포심은 필요 없다

대법원 2007. 9. 28. 선고 2007도606 전원합의체 판결 형의실효등에관한법률위반·협박

최근 5년 기출 **2026** 경찰 승진시험 · 군무원 · 해양경찰 승진시험 | **2025** 해양경찰 · 해양경찰 승진시험 | **2024** 경찰 · 군무원 | **2023** 경찰 · 경찰대학 편입 · 군무원 · 법원직 9급 | **2022** 해양경찰 승진시험

사실 경찰서 정보보안과 소속 경찰관인 피고인은 친구의 부탁으로 갑을 만나, 피해자가 갑에게서 받은 돈을 갚지 못하고 있다는 사정을 들었다. 피고인은 그 자리에서 피해자에게 전화를 걸어 자신이 정보과 형사라고 밝히고, 갑이 집안 동생이라고 거짓말을 하면서 돈을 빨리 안 해 주면 상부에 보고하여 문제를 삼겠다고 말하였다. 피해자는 원심 법정에서 전혀 두렵지 않았다고 증언하였으나, 원심은 협박죄의 기수를 인정하였다.

쟁점 **상대방이 해악의 뜻을 알아들었지만 실제로 두려워하지 않았다면 협박죄는 미수에 그칠까?**

판단 협박죄가 성립하려면 고지된 해악의 내용이 … 행위 전후의 여러 사정을 종합하여 볼 때에 일반적으로 사람으로 하여금 공포심을 일으키게 하기에 충분한 것이어야 하지만, 상대방이 그에 의하여 현실적으로 공포심을 일으킬 것까지 요구하는 것은 아니며, 그와 같은 정도의 해악을 고지함으로써 상대방이 그 의미를 인식한 이상, 상대방이 현실적으로 공포심을 일으켰는지 여부와 관계없이 그로써 구성요건은 충족되어 협박죄의 기수에 이르는 것으로 해석하여야 한다. … 결국, 협박죄는 사람의 의사결정의 자유를 보호법익으로 하는 위험범이라 봄이 상당하고, 협박죄의 미수범 처벌조항은 해악의 고지가 현실적으로 상대방에게 도달하지 아니한 경우나, 도달은 하였으나 상대방이 이를 지각하지 못하였거나 고지된 해악의 의미를 인식하지 못한 경우 등에 적용될 뿐이다. — 판결요지 [1] 다수의견

해설 형법 제283조 제1항의 협박은 일반적으로 보아 사람으로 하여금 공포심을 일으킬 수 있는 정도의 해악을 고지하는 것이다. 다수의견은 협박죄를 사람의 의사결정의 자유를 보호법익으로 하는 위험범으로 보아, 그러한 해악을 고지하여 상대방이 그 의미를 인식하면 실제로 공포심을 느꼈는지와 관계없이 기수가 된다고 하였다. 상대방의 정서적 반응을 객관적으로 심리·판단하기가 현실적으로 불가능에 가깝다는 것이 그 까닭이다. 형법 제286조의 미수범은 고지가 도달하지 않았거나 상대방이 지각하지 못하였거나 해악의 의미를 인식하지 못한 경우 등에 적용된다. 반대의견은 협박죄를 침해범으로 보아 현실적인 공포심이 있어야 기수라고 하였다. 피고인의 해악 고지는 정당한 직무집행으로 평가할 수 없고 목적 달성을 위한 상당한 수단도 아니어서 정당행위가 되지 않았다.

확인 일반적으로 공포심을 일으키기에 충분한 해악을 고지받은 피해자가 그 의미를 인식하였다면, 실제로는 두려워하지 않았더라도 협박죄는 기수에 이른다. **(O · X)**

핵심어 협박·해악의 고지·위험범·협박죄의 미수·정당행위
함께 읽기 3-137 · 4-089 · 특-718
확인 답 O — 그러한 해악을 고지하여 상대방이 그 의미를 인식한 이상 현실적으로 공포심을 일으켰는지와 관계없이 협박죄의 기수가 된다.

제298조(강제추행) 폭행 또는 협박으로 사람에 대하여 추행을 한 자는 10년 이하의 징역 또는 1천500만원 이하의 벌금에 처한다.

강제추행의 간접정범 — 피해자를 도구로 삼아도 성립

대법원 2018. 2. 8. 선고 2016도17733 판결 아동·청소년의성보호에관한법률위반(강제추행)(인정된죄명:강요)·성폭력범죄의처벌등에관한특례법위반(통신매체이용음란)·협박·강제추행(인정된죄명:강요)

최근 5년 기출 **2026** 국가직 9급 · 해양경찰 | **2025** 경찰 · 경찰 승진시험 · 국가직 7급 · 군무원 | **2024** 경찰 · 경찰간부후보생 · 군무원 · 법원행시 | **2023** 경찰 · 경찰대학 편입 · 국가직 7급 · 법원행시 · 해양경찰 | **2022** 경찰대학 편입 · 군무원 · 법원 승진시험 · 법원행시 · 변호사시험 · 해양경찰

사실 피고인은 스마트폰 채팅 애플리케이션으로 알게 된 피해자들로부터 은밀한 신체 부위가 드러난 사진을 전송받은 뒤, 시키는 대로 하지 않으면 그 사진과 개인정보 등을 유포하겠다고 협박하였다. 겁을 먹은 피해자들은 피고인의 요구대로 나체나 속옷만 입은 모습을 스스로 촬영하거나, 성기에 이물질을 삽입하거나 자위하는 모습을 동영상으로 찍어 피고인에게 전송하였다. 원심은 신체 접촉이 있는 경우와 동등한 정도로 성적 수치심을 주는 행위로 보기 어렵다며 강제추행 부분을 무죄로 보았고, 검사가 상고하였다.

쟁점 **협박으로 피해자가 스스로 자기 몸에 추행에 해당하는 행위를 하게 했다면, 몸에 손대지 않았어도 강제추행죄가 될까?**

판단 강제추행죄는 사람의 성적 자유 내지 성적 자기결정의 자유를 보호하기 위한 죄로서 정범 자신이 직접 범죄를 실행하여야 성립하는 자수범이라고 볼 수 없으므로, 처벌되지 아니하는 타인을 도구로 삼아 피해자를 강제로 추행하는 간접정범의 형태로도 범할 수 있다. 여기서 강제추행에 관한 간접정범의 의사를 실현하는 도구로서의 타인에는 피해자도 포함될 수 있으므로, 피해자를 도구로 삼아 피해자의 신체를 이용하여 추행행위를 한 경우에도 강제추행죄의 간접정범에 해당할 수 있다. … 피고인이 직접 위와 같은 행위들을 하지 않았다거나 피해자들의 신체에 대한 직접적인 접촉이 없었다고 하더라도 달리 볼 것은 아니다. — 판결요지 [2], 이유 3. 다.

해설 강제추행죄의 보호법익은 사람의 성적 자유 내지 성적 자기결정의 자유이다. 판례는 이 죄를 정범 자신이 직접 실행하여야 성립하는 자수범으로 보지 않으므로, 처벌되지 않는 타인을 도구로 삼는 간접정범(형법 제34조 제1항)의 형태로도 범할 수 있다. 그 도구가 되는 타인에는 피해자도 포함되므로, 협박으로 겁을 먹은 피해자에게 스스로 나체를 촬영하게 하거나 자위 등을 하게 한 행위도 강제추행이 될 수 있다. 피고인이 직접 행위하지 않았다거나 피해자의 신체에 접촉하지 않았다는 사정은 결론을 바꾸지 못한다. 추행에 해당하는지는 피해자의 의사, 구체적 행위태양, 그 시대의 성적 도덕관념 등을 종합하여 판단한다.

확인 강제추행죄는 자수범이므로, 협박으로 피해자가 스스로 자기 신체에 추행행위를 하게 한 사람은 강제추행죄의 간접정범이 될 수 없다. **(O · X)**

핵심어 강제추행·추행의 의미·자수범·간접정범·피해자를 도구로 이용

함께 읽기 4-090 · 2-182 · 특-722 · 2-181

확인 답 X — 강제추행죄는 자수범이 아니어서 간접정범의 형태로도 범할 수 있고, 그 도구가 되는 타인에는 피해자도 포함될 수 있다.

제319조(주거침입, 퇴거불응)
①사람의 주거, 관리하는 건조물, 선박이나 항공기 또는 점유하는 방실에 침입한 자는 3년 이하의 징역 또는 500만원 이하의 벌금에 처한다.

공동거주자 승낙 출입 — 부재자 의사에 반해도 침입 아님

대법원 2021. 9. 9. 선고 2020도12630 전원합의체 판결 주거침입

최근 5년 기출 **2026** 국가직 7급 · 법원직 9급 · 해양경찰 승진시험 | **2025** 경찰대학 편입 | **2024** 경찰간부후보생 · 군무원 · 법원직 9급 | **2023** 경찰대학 편입 · 국가직 9급 · 군무원 · 법원 승진시험 | **2022** 경찰 · 경찰 승진시험 · 군무원

사실 피고인은 피해자의 처와 교제하던 중, 피해자가 집에 없는 사이 피해자의 처와 혼외 성관계를 가질 목적으로 피해자 부부가 함께 사는 아파트에 3회에 걸쳐 들어갔다. 피고인은 피해자의 처가 열어 준 현관 출입문을 통하여 들어갔는데, 이 출입이 피해자의 주거에 침입한 것이라는 공소사실로 기소되었다. 제1심은 유죄로 보았으나, 원심은 피해자의 처의 승낙을 받고 들어갔으므로 침입이 아니라며 무죄를 선고하였고 검사가 상고하였다.

쟁점 **집 안에 있던 거주자가 문을 열어 주어 들어갔어도, 집에 없던 다른 거주자의 의사에 반한다면 주거침입이 될까?**

판단 외부인이 공동거주자의 일부가 부재중에 주거 내에 현재하는 거주자의 현실적인 승낙을 받아 통상적인 출입방법에 따라 공동주거에 들어간 경우라면 그것이 부재중인 다른 거주자의 추정적 의사에 반하는 경우에도 주거침입죄가 성립하지 않는다고 보아야 한다. … 침입이란 '거주자가 주거에서 누리는 사실상의 평온상태를 해치는 행위태양으로 주거에 들어가는 것'을 의미하고, 침입에 해당하는지 여부는 출입 당시 객관적·외형적으로 드러난 행위태양을 기준으로 판단함이 원칙이다. 사실상의 평온상태를 해치는 행위태양으로 주거에 들어가는 것이라면 대체로 거주자의 의사에 반하는 것이겠지만, 단순히 주거에 들어가는 행위 자체가 거주자의 의사에 반한다는 거주자의 주관적 사정만으로 바로 침입에 해당한다고 볼 수는 없다. — 판결요지 [1] 다수의견

해설 주거침입죄의 보호법익은 거주자가 사실상 누리는 주거의 평온이다. 종전 판례(대법원 1984. 6. 26. 선고 83도685 판결)는 공동거주자 한 사람의 승낙이 다른 거주자의 의사에 반하면 그의 주거의 평온을 해친다고 보아, 남편이 부재중일 때 혼외 성관계를 가질 목적으로 처의 승낙을 얻어 들어간 경우에도 주거침입죄를 인정하였다. 이 판결의 다수의견은 침입을 사실상의 평온상태를 해치는 행위태양으로 들어가는 것으로 새기고, 출입 당시 겉으로 드러난 행위태양을 기준으로 판단하여 종전 판례를 변경하였다. 부재자의 추정적 의사로 범죄 성립을 가르면 평온의 침해가 주관화되고 가벌성이 지나치게 넓어진다는 것이다. 반대의견은 부재중인 거주자가 그 자리에 있었다면 출입을 거부하였을 것이 명백한 경우에는 주거침입죄가 성립한다고 보았다.

범위 부재중인 거주자라도 사실상의 평온상태를 해치는 행위태양으로 들어가거나 그 거주자가 독자적으로 사용하는 공간에 들어간 경우에는 그 거주자의 주거의 평온을 침해할 수 있다.

확인 공동거주자 중 집 안에 있던 사람의 현실적인 승낙을 받아 통상적인 출입방법으로 들어갔더라도, 부재중인 다른 거주자의 의사에 반하는 것으로 추정되면 주거침입죄가 성립한다. **(O · X)**

핵심어 주거침입·사실상 주거의 평온·침입의 의미·공동거주자의 승낙·추정적 의사·판례변경
함께 읽기 3-142 · 4-094 · 특-746 · 특-747 · 특-748 · 2-188 · 2-187
확인 답 X — 이 경우 사실상의 평온상태를 해치는 행위태양으로 들어간 것이 아니므로, 부재중인 거주자의 추정적 의사에 반하더라도 주거침입죄가 성립하지 않는다.

제329조(절도) 타인의 재물을 절취한 자는 6년 이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금에 처한다.

불법영득의사 — 소유자에게 이익이 되어도 부정되지 않는다

대법원 2014. 2. 21. 선고 2013도14139 판결 마약류관리에관한법률위반(향정)·재물손괴·범인도피교사·절도

최근 5년 기출 **2026** 해양경찰 승진시험 | **2025** 경찰 · 경찰간부후보생 | **2024** 경찰 승진시험 | **2023** 경찰 · 해양경찰 · 해양경찰 승진시험 | **2022** 경찰 · 경찰 승진시험

사실 피고인은 A회사 소유의 승용차를 리스하여 운행하다가 사채업자에게서 1,300만 원을 빌리면서 승용차를 넘겨주었다. 피고인이 돈을 갚지 못하자 사채업자는 승용차를 팔았고, 결국 피해자가 이를 사서 점유하였다. 피고인은 승용차를 되찾으려고 피해자와 만나기로 약속한 뒤, 약속장소에 주차된 승용차를 미리 가지고 있던 보조열쇠로 임의로 가져갔다. 승용차는 약 한 달 뒤 A회사에 반납되었고, 원심은 반납하려는 의도였다는 등의 이유로 절도를 무죄로 보았다.

쟁점 **가져간 물건이 결과적으로 소유자에게 돌아가더라도 절도의 불법영득의사가 인정될까?**

판단 그리고 절도죄의 성립에 필요한 불법영득의 의사란 타인의 물건을 그 권리자를 배제하고 자기의 소유물과 같이 그 경제적 용법에 따라 이용·처분하고자 하는 의사를 말하는 것으로서, 단순히 타인의 점유만을 침해하였다고 하여 그로써 곧 절도죄가 성립하는 것은 아니나, 재물의 소유권 또는 이에 준하는 본권을 침해하는 의사가 있으면 되고 반드시 영구적으로 보유할 의사가 필요한 것은 아니며, 그것이 물건 자체를 영득할 의사인지 물건의 가치만을 영득할 의사인지를 불문한다. 따라서 어떠한 물건을 점유자의 의사에 반하여 취거하는 행위가 결과적으로 소유자의 이익으로 된다는 사정 또는 소유자의 추정적 승낙이 있다고 볼 만한 사정이 있다고 하더라도, 다른 특별한 사정이 없는 한 그러한 사유만으로 불법영득의 의사가 없다고 할 수는 없다. — 판결요지

해설 절도죄는 타인이 점유하는 타인의 재물을 점유자의 의사에 반하여 자기 또는 제3자의 점유로 옮기는 절취와 불법영득의 의사가 있어야 성립한다. 이 사건 승용차의 소유자는 A회사였지만, 피고인이 점유자인 피해자의 의사에 반하여 점유를 옮겼으므로 절취에 해당한다. 불법영득의 의사는 단순히 타인의 점유만을 침해하는 것으로는 부족하지만, 소유권 또는 이에 준하는 본권을 침해하는 의사이면 되고 영구히 보유할 의사까지는 필요 없다. 그래서 가져간 행위가 결과적으로 소유자에게 이익이 되거나 소유자의 추정적 승낙이 있다고 볼 사정이 있어도, 다른 특별한 사정이 없으면 그것만으로 불법영득의 의사가 부정되지 않는다. 이 법리에 따라 대법원은 반납하려는 의도였다는 등의 이유만으로 절도를 무죄로 본 원심을 파기하였다.

확인 점유자의 의사에 반하여 물건을 가져갔더라도 그 행위가 결과적으로 소유자의 이익이 되었다면 불법영득의 의사가 없어 절도죄가 성립하지 않는다. **(O · X)**

핵심어 절취·불법영득의 의사·점유·본권·추정적 승낙

함께 읽기 1-475 · 1-474 · 3-144 · 특-760 · 특-758 · 특-759 · 특-756 · 2-190 · 특-755 · 특-757

확인 답 X — 그러한 사정이 있더라도 다른 특별한 사정이 없는 한 그것만으로 불법영득의 의사가 없다고 할 수 없다.

제355조(횡령, 배임)
②타인의 사무를 처리하는 자가 그 임무에 위배하는 행위로써 재산상의 이익을 취득하거나 제삼자로 하여금 이를 취득하게 하여 본인에게 손해를 가한 때에도 전항의 형과 같다.

법인이 진 사무와 배임 — 대표기관이 배임죄의 주체

대법원 1984. 10. 10. 선고 82도2595 전원합의체 판결 배임

최근 5년 기출 **2024** 군무원 | **2022** 군무원 · 법원행시

사실 A회사는 1974년 회사 소유의 대지와 그 지상 점포를 피해자들에게 팔고 대금을 모두 받았다. 1976년 A회사의 대표이사로 취임하여 이 사실을 알게 된 피고인 1은 피고인 2와 공모하여 같은 대지와 점포를 이중으로 분양하고, 피고인 2 등 앞으로 소유권이전등기와 소유권보존등기를 마쳐 주어 피해자들에게 매매대금 상당의 손해를 입혔다. 원심은 등기의무의 주체는 회사이고 피고인 1은 그 대표기관에 불과하다며 무죄를 선고하였고, 검사가 상고하였다.

쟁점 **회사가 진 등기의무를 대표이사가 저버렸다면, 의무를 진 회사가 아닌 대표이사를 배임죄로 처벌할 수 있을까?**

판단 형법 제355조 제2항의 배임죄에 있어서 타인의 사무를 처리할 의무의 주체가 법인이 되는 경우라도 법인은 다만 사법상의 의무주체가 될 뿐 범죄능력이 없는 것이며 그 타인의 사무는 법인을 대표하는 자연인인 대표기관의 의사결정에 따른 대표행위에 의하여 실현될 수 밖에 없어 그 대표기관은 마땅히 법인이 타인에 대하여 부담하고 있는 의무내용 대로 사무를 처리할 임무가 있다 할 것이므로 법인이 처리할 의무를 지는 타인의 사무에 관하여는 법인이 배임죄의 주체가 될 수 없고 그 법인을 대표하여 사무를 처리하는 자연인인 대표기관이 바로 타인의 사무를 처리하는 자 즉 배임죄의 주체가 된다. — 판결요지 다수의견

해설 배임죄는 타인의 사무를 처리하는 지위에 있는 자만 범할 수 있다. 이 사건에서 매수인들에게 소유권이전등기를 해 줄 사법상 의무를 진 것은 회사였으므로, 원심은 대표이사를 타인의 사무를 처리하는 자로 볼 수 없다고 하였다. 다수의견은 법인은 사법상 의무의 주체일 뿐 범죄능력이 없고, 법인의 사무는 대표기관의 대표행위로 실현될 수밖에 없으므로 그 대표기관이 곧 배임죄의 주체가 된다고 보았다. 이로써 반대 취지의 대법원 1982. 2. 9. 선고 80도1796 판결 등이 변경되었다. 반대의견은 대표기관의 임무는 법인에 대하여 지는 것이지 타인에 대하여 지는 것이 아니라고 하였다.

확인 타인의 사무를 처리할 사법상 의무의 주체가 법인이면, 그 법인의 대표기관은 타인에 대한 관계에서 배임죄의 주체가 될 수 없다. **(O · X)**

핵심어 배임·타인의 사무를 처리하는 자·법인의 범죄능력·대표기관·이중매매·판례변경
함께 읽기 2-196 · 1-496 · 2-197 · 특-788 · 특-787 · 3-149 · 특-790 · 4-099 · 3-150 · 특-789 · 2-193 · 특-783 외 11
확인 답 X — 법인은 범죄능력이 없으므로, 법인을 대표하여 사무를 처리하는 자연인인 대표기관이 타인의 사무를 처리하는 자로서 배임죄의 주체가 된다.

사건번호 찾아보기 — 5급

헌법재판소

96헌바35	**5-005**
98헌마363	**5-003**
99헌마139	**5-010**
2000헌바67	**5-006**
2002헌마328	**5-007**
2004헌마554	**5-009**
2005헌마346	**5-002**
2012헌마431	**5-001**

대법원

82도2595	**5-050**
91다43107	**5-028**
95다49554	**5-015**
96도1167	**5-040**
97다37661	**5-018**
97다50985	**5-013**
97도3349	**5-036**
98다43601	**5-022**
2000도938	**5-039**
2002다1178	**5-011**
2002다21509	**5-026**
2002도18	**5-043**
2004도5074	**5-037**
2005다34711	**5-012**
2005다41818	**5-016**
2005도2712	**5-042**
2006다9408	**5-023**
2006다23312	**5-020**
2007다15172	**5-019**
2007다72274	**5-031**
2007다77781	**5-035**
2007도606	**5-046**
2008도942	**5-041**
2009다40684	**5-021**
2009도9807	**5-045**
2009도14442	**5-008**
2010다51192	**5-025**
2010므4071	**5-034**
2011다56033	**5-029**
2012다49933	**5-004**
2013다7936	**5-024**
2013다8250	**5-027**
2013다30882	**5-032**
2013다34143	**5-030**
2013도14139	**5-049**
2015다52978	**5-017**
2015다78703	**5-014**
2016도17733	**5-047**
2018도16002	**5-038**
2018스5	**5-033**
2019도11294	**5-044**
2020도12630	**5-048**

핵심어 찾아보기 — 5급

기타

2차 취득시효 **5-019**

ㄱ

가장매매 **5-013**
간접정범 **5-039** · **5-047**
강도죄와의 균형 **5-037**
강제추행 **5-047**
개인정보 **5-004**
개인정보자기결정권 **5-004**
건물의 재축 **5-022**
경성헌법 **5-009**
계약금 **5-031**
계약의 해제 **5-028** · **5-031**
고권적 작용 **5-010**
공공의 신용 **5-043**
공권력의 행사 **5-010**
공동거주자의 승낙 **5-048**
공동상속등기 **5-032**
공동저당 **5-022**
공무담임권 **5-003**
공문서위조 **5-039**
공소기각 **5-008**
공유지분의 포기 **5-017**
공중위생영업자 **5-045**
과실범 처벌 **5-045**
과실상계 **5-015** · **5-030**
관습법 **5-011**
관습헌법 **5-009**
교인총회의 결의 **5-020**
교회 재산 **5-020**
국가의 보호의무 **5-002**
국가의 형사사법권 **5-042**
국민투표권 **5-009**
국회의원 **5-008**
권한남용 **5-044**
권한을 넘은 표현대리 **5-015**
귀책사유 **5-023**
기본권 주체성 **5-002**
기산점 **5-019**
기수와 미수의 구별 **5-037**

ㄴ

나대지의 교환가치 **5-022**

ㄷ

대표기관 **5-050**
대항요건 **5-016**
동시이행의 항변권 **5-028**
등기 **5-017**

ㅁ

매매잔대금 **5-028**
면책적 채무인수 **5-029**
면책특권 **5-008**
무고 **5-042**
무단점유 **5-018**
물상보증인 **5-027**
물적 담보 **5-027**
미성년자 입양허가 **5-033**
미수범 **5-037**
미필적 인식 **5-042**

ㅂ

배당이의 **5-035**
배아생성자의 결정권 **5-002**
배임 **5-050**
법률에 의하여 선서한 증인 **5-041**
법률행위 내용의 중요부분 **5-014**
법원(法源) **5-011**
법인의 범죄능력 **5-050**
법인의 불법행위능력 **5-012**
법적 확신 **5-011**
법정변제충당 **5-027**
법정지상권 **5-022**
변제이익 **5-027**
보존에 필요한 사용 **5-021**
보증채권의 양도 **5-026**
보증채무의 부종성 **5-025** · **5-026**
복수정당제 **5-001**
본권 **5-049**
부당이득 **5-030**
부동산물권변동 **5-017**
부양적 요소 **5-034**
불고지죄 **5-005**
불능미수 **5-038**
불능범 **5-038**
불법영득의 의사 **5-049**
비례성원칙 **5-003**
비법인사단 **5-012** · **5-020**
비용상환청구권 **5-032**

ㅅ

사망자 명의 **5-043**
사무관리 **5-032**
사무처리를 그르치게 할 목적 **5-044**
사문서위조 **5-043**
사생활의 비밀과 자유 **5-004**
사실상 주거의 평온 **5-048**
사전자기록등위작 **5-044**
사해행위 **5-013** · **5-024**
사회적 기본권 **5-007**
상대방 있는 단독행위 **5-017**
상속채권자 **5-035**
선량한 관리자의 주의 **5-021**
소극재산 **5-034**
소멸시효의 중단 **5-016**
소유권이전등기청구권 **5-017**
소유의 의사 **5-018**
손해배상액의 예정 **5-023**
수도 **5-009**
수반성 **5-026**
수익의 의사표시 **5-029**
시효이익의 포기 **5-025**
시효중단 **5-019**
신의칙 **5-030**
실행의 수단 또는 대상의 착오 **5-038**

ㅇ

양심실현의 자유 **5-005**
양심의 자유 **5-005**
양자와의 친계와 촌수 **5-033**
엄격한 비례심사 **5-001**
엄격한 심사척도 **5-003**
업무상과실치사 **5-045**
업무상 주의의무 **5-045**
연대보증 **5-025** · **5-027**
영토권 **5-010**
예외조항 **5-006**
예정액의 감액 **5-023**
옥외집회 금지장소 **5-006**
원상회복의무 **5-030**
위작의 의미 **5-044**
위조공문서행사 **5-039**
위증 **5-041**
위험범 **5-046**
위험성 **5-038**
유추적용 **5-012** · **5-015**
유추해석금지 **5-040**
유치권 **5-021**
유치권 소멸청구 **5-021**
의사해석 **5-023**
이익형량 **5-004**
이중매매 **5-050**
이행의 착수 **5-031**
이행제공 **5-028**
인간다운 생활을 할 권리 **5-007**
일반적 인격권 **5-004**
일부취소 **5-026**
임의적 감면 **5-040**
입법재량 **5-007**
입양 **5-033**

ㅈ

자기부죄거부특권 **5-041**
자녀의 복리 **5-033**
자수 **5-040**
자수범 **5-047**
자수의 시기 **5-040**
자주점유의 추정 **5-018**
작성권한 **5-039**
작성명의의 모용 **5-039**
재산관계의 청산 **5-034**
재산분리 **5-035**
재산분할청구권 **5-024** · **5-034**
재판상의 청구 **5-016**
전체 법질서 **5-011**
절도미수 **5-037**
절취 **5-049**
점유 **5-049**
점유취득시효 **5-018** · **5-019**
정당등록취소 **5-001**
정당설립의 자유 **5-001**
정당존속의 자유 **5-001**
정당한 이유 **5-015**

정당행위 **5-046**
제3자를 위한 계약 **5-029**
제대군인 가산점 **5-003**
조손관계 **5-033**
조약 **5-010**
종중 구성원 **5-011**
주거침입 **5-048**
주권발행 전 주식 **5-031**
주채무의 소멸시효 **5-025**
준강간 **5-038**
준강도 **5-037**
중대한 과실 **5-012**
중도금 **5-028**
중첩적 채무인수 **5-029**
증명책임 **5-023**
증언거부권의 고지 **5-041**
직무부수행위 **5-008**
직무에 관한 행위 **5-012**
진술거부권 **5-005**
집회의 자유 **5-006**
집회장소 **5-006**

ㅊ

차임 상당 이득 **5-021**
착오에 의한 의사표시 **5-014**
착오취소 **5-014**
채권양도 **5-016**
채권양도의 대항요건 **5-026**
채권자대위 **5-032**
채권자의 승낙 **5-029**
채권자취소권 **5-013** · **5-024**
채무의 분담 **5-034**
책임재산 **5-024**
청구인적격 **5-002**
초기배아 **5-002**
총유 **5-020**
최소침해의 원칙 **5-006**
최저생계비 **5-007**
추정적 승낙 **5-049**
추정적 의사 **5-048**
추행의 의미 **5-047**
침묵의 자유 **5-005**
침입의 의미 **5-048**

ㅌ

타인을 위하여 사무를 처리하는 의사 **5-032**
타인의 사무를 처리하는 자 **5-050**
타인의 전자기록 **5-044**
타인 토지의 매매 **5-018**
통정허위표시 **5-013**

ㅍ

판례변경 **5-019** · **5-022** · **5-041** · **5-043** · **5-048** · **5-050**
판례의 변경 **5-036**
평등권 **5-003**
평등의 원칙 **5-036**
포괄적 권리의무의 승계 **5-035**
포기 **5-024**
표현대리 **5-020**
피무고자의 승낙 **5-042**
피해자를 도구로 이용 **5-047**

ㅎ

하자담보책임 **5-014**
한정승인 **5-035**
해악의 고지 **5-046**
해약금 **5-031**
해제의 효과 **5-030**
행위규범과 통제규범 **5-007**
행위시법주의 **5-036**
행정상 단속법규 **5-045**
허무인 **5-043**
허위의 정보 **5-044**
헌법개정절차 **5-009**
헌법소원의 대상 **5-010**
협박 **5-046**
협박죄의 미수 **5-046**
형면제 **5-040**
형벌불소급의 원칙 **5-036**
형사처분을 받게 할 목적 **5-042**
형식과 외관 **5-043**

대한민국 표준판례

5급편

초판 인쇄	2026. 9. 30.
초판 발행	2026. 9. 30.
지은이	김민규
감수	김미현, 신현하, 박상영, 한정현, 이규한, 박준한, 정헌욱, 김영진, 박병재, 박서경, 최성완
발행인	김장미
주소	서울시 금천구 가산디지털1로 5, 406호
전화	02)6959-7511
팩스	02)6008-0117
발행처	도서출판 서리풀
출판등록	2024년 8월 16일 제2024-000078

저작권자와 맺은 특약에 따라 검인을 생략합니다.

ISBN 979-11-988910-9-9

▶ 이 책은 저작권법에 따라 보호받는 저작물이므로 무단 전재와 무단 복제를 금지하며, 이 책 내용의 전부 또는 일부를 이용하려면 반드시 저작권자와 도서출판 서리풀의 동의를 받아야만 합니다.

▶ 잘못된 책은 구입하신 곳에서 바꾸어 드립니다.

법학도 ‘불 화, 물 수’부터

한자를 ‘불 화(火)’, ‘물 수(水)’부터 배우듯, 법학도 여러 문제에 되풀이하여 쓰이는 기본 개념과 법리부터 배워야 한다. 『대한민국 표준판례』는 헌법·민법·형법의 판례를 급수로 쌓는다. 5급 50판례에서 시작하여 4급까지 150판례, 3급까지 300판례, 2급까지 500판례, 1급까지 1,000판례로 학습범위를 넓히고, 안쪽 급수의 판례는 바깥 급수에 그대로 들어간다.

5급편은 그 첫 단계다. 가장 먼저 익힐 50판례를 헌법·민법·형법 차례로, 법전의 조문 순서에 따라 실었다. 판례마다 조문과 사실·쟁점·판단·해설을 함께 읽고 확인 문항으로 이해를 점검한다. 2022년부터 2026년까지 그 판단을 물은 시험의 이름과 연도도 적었다.

처음에는 사건과 결론을, 다음에는 판단의 근거와 요건을, 다시 읽을 때에는 ‘함께 읽기’의 판례와 견주어 예외와 적용 범위를 살핀다. 읽은 횟수보다 스스로 설명하고 적용할 수 있는 내용을 늘려 가는 공부를 권한다.

대한민국 표준판례



도서출판 서리풀